Universidad de Costa Rica

Facultad de Derecho

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho

"El Control Jurisdiccional de los Actos de Gobierno"

Jose Carlos Solano Salas

Carné: B66945

2023

1 de marzo de 2023.

Msc. Thomás Federico Arias Castro

Director, Área de Investigación

Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Estimado profesor:

En mi condición de Lector del Trabajo Final de Graduación (modalidad tesis) titulado *"El control jurisdiccional del acto de gobierno"* que sustenta el estudiante Jose Carlos Solano Salas, carné B66945, manifiesto:

Que he realizado una lectura integral al documento final aportado por el postulante y según mi criterio, la tesis cumple a cabalidad con los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa universitaria, por lo que otorgo mi aprobación y solicito su admisión para la defensa oral y pública.

Muy atentamente,

OSCAR EDUARDO GONZALEZ CAMACHO (FIRMA)

Firmado digitalmente por OSCAR EDUARDO GONZALEZ CAMACHO (FIRMA)
Fecha: 2023.03.01 10:13:54 -06'00'

Dr. Óscar Eduardo González Camacho.

Profesor de la línea curricular de Derecho Administrativo y Constitucional.

Facultad de Derecho.

8 de febrero de 2023.

Msc. Thomás Federico Arias Castro

Director, Área de Investigación

Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Estimado profesor:

En mi condición de Lector del Trabajo Final de Graduación (modalidad tesis) titulado "*El control jurisdiccional del acto de gobierno"* que sustenta el estudiante Jose Carlos Solano salas, carnet B66945, manifiesto:

Que he realizado una lectura integral al documento final aportado por el postulante y según mi criterio, la tesis cumple a cabalidad con los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa universitaria, por lo que otorgo mi aprobación y solicito su admisión para la defensa oral y pública.

Muy atentamente,

JOSE ROBERTO GARITA NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOSE ROBERTO GARITA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2023.02.14 07:03:12 -06'00'

Dr. Jose Roberto Garita Navarro.

Profesor de la línea curricular de Derecho Administrativo

Facultad de Derecho

Gonzalo Monge Núñez

Montes de Oca, 26 de setiembre del 2022

Señor
MSc. Tomás Federico Arias Castro
Director- Área de Investigación
FACULTAD DE DERECHO
Universidad de Costa Rica
Presente

De mi atenta consideración:

He fungido como lector del trabajo final de graduación titulado: *"El Control Jurisdiccional de los Actos de Gobierno"* del estudiante José Carlos Solano Salas, carné B66945.

Se trata de una investigación relevante, sobre un tema técnico, interesante y actual. Por reunir los requisitos de forma y de fondo exigidos, la apruebo.

Aprovecho la ocasión para saludar al señor Director muy atentamente:

GONZALO DE LOS ANGELES MONGE NUÑEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por GONZALO DE LOS ANGELES MONGE NUÑEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.09.26 04:51:30 -06'00'

San José, 03 de marzo del 2023.

Universidad de Costa Rica

Facultad de Derecho

Estimado Dr. Tomás Federico Arias Castro

Director del Área de Investigación

El estudiante Jose Carlos Solano Salas, portador de la cédula de identidad n.° 5-0419-0563, me ha presentado, en mi calidad de profesional graduada en Filología, el proyecto de graduación denominado "El Control Jurisdiccional del Acto de Gobierno", el cual ha elaborado para optar por el grado de Licenciatura en Derecho.

He revisado el documento, de acuerdo con los lineamientos de corrección de estilo, los aspectos de estructura gramatical, acentuación, ortografía, puntuación y vicios de dicción que se trasladan al escrito, y he verificado que se han realizado todas las correcciones necesarias en él.

Por consiguiente, se encuentra listo para ser presentado oficialmente a la Universidad.

Atentamente,

Carmen Pinto Murillo

M. C. Carmen Pinto Murillo

Carné Colypro: 3939

Dedicatoria:

A mi madre, cuya tenacidad me sostuvo ante la penuria y me impulsó en la contrariedad.

A mi padre, cuya sabiduría me orientó en la confusión y me reconfortó ante el desasosiego.

A mis hermanos, mis mejores amigos en la vida.

Agradecimientos:

A Óscar Eduardo González Camacho, mi maestro en el Derecho.

*"**Del nuevo Ídolo.** En algún lugar existen todavía pueblos y rebaños, pero no entre nosotros, hermanos míos: aquí hay Estados. ¿Estado? ¿Qué es eso? ¡Bien! Abridme ahora los oídos, pues voy a deciros mi palabra sobre la muerte de los pueblos. Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y ésta es la mentira que se desliza de su boca: «Yo, el Estado, soy el pueblo.»"*

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. 1885.

Índice

Tabla de abreviaturas……..……vii

Resumen……..viii-ix

Ficha bibliográfica…….....x

Introducción…….....1

Justificación……..…...1

Hipótesis…….….2

Objetivos…….……3

Metodología……4

Título I: Generalidades del Acto de Gobierno……5

Capítulo 1. Historia del Acto de Gobierno……..6

Sección Primera: Origen en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés…….……...6

Sección Segunda: Evolución en el Derecho español…….....13

Sección Tercera: Evolución en el Derecho costarricense……..28

Capítulo 2. Aspectos generales del Acto de Gobierno……..33

Sección Primera: Principales elementos del Acto Administrativo……33

Sección Segunda: Conceptos fundamentales relacionados con el Acto de Gobierno…….....46

Sección Tercera: Características principales del Acto de Gobierno……..53

Capítulo 3. Teoría contemporánea del Acto de Gobierno……....57

Sección Primera: Situación actual del Acto de Gobierno en derecho comparado (España).....57

Sección Segunda: El Acto de Gobierno en Costa Rica……..74

Título II: Control jurisdiccional de los Actos Administrativos……87

Capítulo 1. Evolución de la jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda...88

Sección Primera: Origen en el Derecho francés……..88

Sección Segunda: Desarrollo histórico en Costa Rica…….....100

Capítulo 2. Control jurisdiccional de los Actos Administrativos……..109

Sección Primera: Principios rectores……109

Sección Segunda: Mecanismos de control en la normativa costarricense……118

Título III: Control jurisdiccional de los Actos de Gobierno……122

Capítulo 1. Elementos y su impugnabilidad……123

Sección Primera: Control de legalidad…….123

Sección Segunda: Daños y perjuicios patrimoniales……131

Capítulo 2. Marco normativo y jurisprudencial……..140

Sección Primera: Regulación normativa del Acto de Gobierno en Costa Rica……140

Sección Segunda: Análisis de antecedentes jurisprudenciales……..143

Capítulo 3. El Acto de Gobierno frente a los principios garantistas del Derecho Público….149

Sección Primera: El Acto de Gobierno y el principio de acceso a la justicia……...149

Sección Segunda: El Acto de Gobierno y el principio de reparación integral del daño……154

Sección Tercera: Propuesta de un modelo garantista de control jurisdiccional del Acto de Gobierno……..158

Conclusiones……...161

Bibliografía…….166

Tabla de abreviaturas:

Sigla	**Significado**
LJCA	Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
CPCA	Código Procesal Contencioso Administrativo
LRJCA	Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
LGAP	Ley General de la Administración Pública
CP	Constitución Política

Resumen

Esta investigación se centra en el Acto de Gobierno, instituto que es especie adscrita al género de los actos administrativos. Dicho concepto, nacido en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés durante el siglo XVIII, en su formulación clásica, se postula como una excepción al control plenario del accionar de las Administraciones Públicas, por parte del contralor jurisdiccional. Se estudia su origen en el derecho francés, su evolución en el derecho español (en tanto escala necesaria) y finalmente, la acogida y posterior desarrollo en el derecho costarricense de la segunda mitad del siglo XX, así como su aparición, con claridad, a partir de la LRJCA.

En tanto especie del Acto Administrativo, el ahondamiento en el Acto de Gobierno implica el estudio de la teoría general del Acto Administrativo, así como de sus elementos particulares. Por ser su nota distintiva una presunta exclusión de control jurisdiccional, también acarrea el estudio del contralor de legalidad, a través del establecimiento de la jurisdicción contencioso administrativa y civil de Hacienda.

El estudio de análisis jurisprudenciales es sumamente complicado, en tanto, por su propia naturaleza aludida, son muy escasos los antecedentes donde se desarrolla el Acto de Gobierno y, más aún, donde se impugna un Acto Administrativo y se postula la excepción de acto no susceptible de impugnación por considerarse el objeto del proceso un Acto de Gobierno. Ello, combinado con el también escaso desarrollo doctrinal del instituto, ha propiciado que exista un enorme vacío en el derecho costarricense con respecto a esta tipología de Acto Administrativo.

El no sometimiento, de una parcela del accionar de las Administraciones Públicas, al contralor judicial de legalidad o constitucionalidad es una premisa que debe ser estudiada a la luz de los principios que informan el marco teórico contemporáneo de la Justicia Administrativa, dentro de los cuales destacan: el principio de tutela judicial efectiva, de responsabilidad del Estado y reparación integral del daño.

La hipótesis de trabajo planteada sostiene que no es viable la exclusión de una especie específica de Acto Administrativo de todo contralor jurisdiccional. Dicho posicionamiento clásico del Acto de Gobierno genera reminiscencias del régimen monárquico, que es diametralmente opuesto al Estado Social y Democrático de Derecho, que sin duda es el parámetro deontológico al que apuntan las Administraciones Públicas contemporáneas. También roza con la tendencia garantista de la

Justicia Administrativa que, sin duda, propone como indispensable la defensa efectiva de los derechos de los administrados, que tienen como contrapunto el desbordado poder de las Administraciones Públicas, en ejercicio de sus potestades de imperio otorgadas por el propio ordenamiento jurídico.

De esta forma, la discusión planteada alrededor de la impugnabilidad de una especie específica de Acto Administrativo, trasciende el ámbito del derecho procesal contencioso y se adscribe a variados y amplios campos temáticos, como el derecho constitucional, la teoría general del derecho y hasta la propia división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos mediante el cual se materializa.

Ficha bibliográfica

Solano Salas, Jose Carlos. El control jurisdiccional del Acto de Gobierno. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2023. x y 168.

Director: Dr. Óscar Eduardo González Camacho.

Palabras clave: Acto de Gobierno, Acto Administrativo, derecho procesal contencioso, control de legalidad, daños y perjuicios.

Introducción

Justificación

El presente proyecto de investigación se debe a la pugna que genera la figura del, llamado por la doctrina, acto de «gobierno», «institucional» o «político» (que tiene como característica principal su inimpugnabilidad) con el precepto constitucional de tutela judicial efectiva (artículo 41 de la Constitución Política), así como con el establecimiento de la jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, como contralor pleno de la legalidad y resguardo de los derechos subjetivos e intereses de los administrados frente a la Administración y sus manifestaciones de voluntad (artículo 49 de la Constitución Política).

El Acto de Gobierno es un instituto poco desarrollado por la doctrina nacional, así como por la jurisprudencia, debido, principalmente, a la escasez de casos prácticos donde se dilucide la aplicación concreta de la figura en Tribunales de Justicia. Adicional a ello, la regulación normativa (al menos directa) es prácticamente inexistente, el único atisbo de una regulación directa existente es la exclusión realizada en el artículo 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo de las pretensiones:

> *"concernientes a los actos de relación entre los Poderes del Estado o con motivo de las relaciones internacionales, sin perjuicio de las indemnizaciones procedentes, cuya determinación corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."*

Por su poco desarrollo dogmático, la vaga regulación a la que está sujeto, la escasez de antecedentes jurisprudenciales y el claro contrapunto que genera su inimpugnabilidad, de cara al Derecho de la Constitución y aspectos concretos del bloque de legalidad (principalmente principios generales del derecho público), resulta indispensable efectuar un desarrollo amplio y coherente del Acto de Gobierno en Costa Rica. Lo propuesto, ya sea para armonizar las fuentes que actualmente informan y delimitan el instituto como para proponer una modificación, e incluso una nueva regulación, que contemple el Acto de Gobierno, de modo consecuente con el resguardo de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados.

Hipótesis

La inimpugnabilidad del Acto de Gobierno es contraria al bloque de juridicidad, en la medida en que incida en los derechos subjetivos de las personas.

Objetivos

General:

1- Determinar si la inimpugnabilidad jurisdiccional del Acto de Gobierno resulta contraria al bloque de juridicidad existente en Costa Rica.

Específicos:

1- Identificar los principales elementos normativos, conceptuales y jurisprudenciales que conforman el Acto Administrativo de Gobierno, desde su origen en el derecho francés post napoleónico hasta su situación actual en el derecho público costarricense.
2- Establecer los alcances y límites de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda en Costa Rica, con respecto al control jurisdiccional de los Actos Administrativos de Gobierno.
3- Proponer un modelo de control jurisdiccional a partir del cual la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda costarricense garantice los derechos fundamentales de reparación integral del daño y acceso a la justicia, de cara a la emisión de Actos Administrativos de Gobierno por parte del Estado.

Metodología

Método deductivo: Se empleará este método, debido a que se van a analizar nociones generales y abstractas, como lo son los principios generales de derecho de acceso a la justicia y reparación integral del daño, con el objetivo de posteriormente verificar si se están cumpliendo en casos concretos, los cuales estarán vinculados con la determinación de actos políticos por parte de la Administración Pública costarricense. Para ello se debe:

a. Analizar el concepto de acto de gobierno, en su nacimiento y evolución histórica en Europa, así como en el posterior desarrollo dogmático y práctico, para determinar los rasgos distintivos de tal concepto de otros tipos de actos administrativos.

b. Realizar un análisis hermenéutico de los principios de acceso a la justicia y reparación integral del daño. Ello, para lograr de una manera acabada comprender sus alcances conceptuales y sus implicaciones concretas en la impartición de justicia contenciosa administrativa.

Título I: Generalidades del Acto de Gobierno

Contenido:

Capítulo 1. Historia del Acto de Gobierno

Sección Primera: Origen en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés

Sección Segunda: Evolución en el Derecho español

Sección Tercera: Evolución en el Derecho costarricense

Capítulo 2. Aspectos generales del Acto de Gobierno

Sección Primera: Principales elementos del Acto Administrativo

Sección Segunda: Conceptos fundamentales relacionados con el Acto de Gobierno

Sección Tercera: Características principales del Acto de Gobierno

Capítulo 3. Teoría contemporánea del Acto de Gobierno

Sección Primera: Situación actual del Acto de Gobierno en derecho comparado (España)

Sección Segunda: El Acto de Gobierno en la doctrina y normativa costarricense

Capítulo 1. Historia del Acto de Gobierno

Sección Primera: Origen en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés

Para poder entender la figura del Acto de Gobierno, se debe iniciar con un desarrollo de su origen que, como muchos institutos propios del Derecho Administrativo, tuvo lugar en las reformas Estatales que sucedieron en la Francia post revolucionaria, de finales del siglo XVIII y durante la mayor parte del XIX. Posteriormente, en esta investigación, se retomará el tema del origen de la jurisdicción francesa que, a su vez, es un hito remoto de control de legalidad sobre las potestades de imperio de quien detenta el poder político. Lo cierto es que, ni este proyecto tiene como eje orientador la historia del derecho (sino el derecho positivo, procesal y sustantivo) ni versa, al menos no de manera prioritaria, sobre el origen de las instituciones jurisdiccionales. Por lo anterior, incluso antes que determinar la procedencia de tales instituciones, aspecto de alguna manera tangencial, se prioriza conocer el origen del Acto de Gobierno.

El auge de la revolución en Francia, en los últimos años del siglo XVIII, trajo consigo muchas reformas importantes al aparato Estatal hasta entonces absolutista, monárquico. Se impuso el control de legalidad a la actividad Estatal, tema que, tal y como se mencionó anteriormente, se desarrollará en otro momento. Lo cierto es que la naciente organización francesa contaba con una motivación histórica, desarrollada por la doctrina filosófica y política imperante, tendiente a distribuir el poder en una nueva forma de organización que no concentrara todo el poder en la figura de una sola persona (el monarca), tal y como había sido el manejo de la cosa pública en Europa (con pocas excepciones en el tiempo y el espacio), desde la Baja Edad Media y hasta ese momento. El siglo XVIII atestiguó esta tendencia:

> *"El siglo XVIII – también conocido como Siglo de las Luces – se caracterizó por la Ilustración, Immanuel Kant: "movimiento intelectual en el cual los grandes pensadores sembraron las bases del pensamiento moderno en distintas esferas tanto política como cultural.". Al poner en relieve y centro de ello la razón, para contrarrestar la ignorancia, las creencias y el despotismo*

predominante en la época. La misma que tuvo grandes precursores y mentores de entre los cuales se puede destacar a: John Locke, Charles Louis de Secondat o Baron de Montesquieu, Jean-Jackes Rousseau, David Hume, François-Marie Arouet también conocido como Voltaire, entre otros.

En Europa Occidental durante los siglos XVI y XVII y XVIII el poder estaba detentado por una sola persona conocido como "monarca". Dicha forma de administrar el poder se la conoce como: "absolutismo". Las monarquías absolutas como forma de administrar del poder se determinaban por justificar su poder en el mandato divino (encarnado en el monarca); oprimir a sus gobernados con impuestos excesivos y leyes injustas; además, no poseer límites a su ejercicio del poder, no presentar ni rendir cuentas e ir en atropello y menoscabo de los Derechos fundamentales y libertades de los individuos."[1]

Centurias de monarquía y absolutismo empezaban a presenciar su ocaso. Los filósofos políticos ilustrados, principalmente las figuras de John Locke y Charles Louis de Secondat, varón de Montesquieu, encabezaron un movimiento emancipatorio que se apoderó de la conciencia colectiva europea, cuyo origen y principal sede tuvo lugar en Francia. Los principios que informan esta tendencia intelectual están relacionados con el problema de la legitimación del poder, de la legalidad en el actuar de los individuos y la Administración Pública, así como de la disgregación del poder en diferentes entes ficticios, cuya función sea, a su vez, ejercida bajo la rigurosidad de ciertos parámetros preestablecidos (legalidad). Dicha legitimación del poder remite a su origen, el cual *"debe emanar de la voluntad popular más no divina."*[2]. La legalidad, a su vez, arroja a un concepto de libertad individual, que únicamente puede existir bajo el imperio de las leyes, en palabras del propio Montesquieu:

> *"La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad."*[3]

---

[1] González Pogo, David Israel. *El Principio de los "Pesos y Contrapesos" en el Constitucionalismo Ecuatoriano Contemporáneo.* Quito, Ecuador. Revista de la Facultad de Jurisprudencia. Vol. 1, no 2. P 2.
[2] *Ibid.* P 3.
[3] Montesquieu. *El espíritu de las leyes.* España: Orbis. 1984. P142.

Lo anterior conlleva, necesariamente, a la separación de poderes comentada, cuya propuesta y eje es que *"Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder."*[4] Bajo esa línea de pensamiento, la propuesta orgánica planteada por Montesquieu y, de alguna manera adoptada por las democracias representativas cuyo auge tuvo lugar en el siglo XVIII, es la siguiente:

> *"Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil.*
>
> *Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado."*[5]

Si bien, ya con la estructura descrita se denotan atisbos de frenos y contrapesos, sobre todo en cuanto a la división orgánica del poder, ciertamente no se observa en la propuesta de Montesquieu un contralor de legalidad activo, que sería la propuesta finalmente prevaleciente en el Estado francés y el resto de los ordenamientos jurídicos continentales europeos. Claro está, eso sí, que estos parámetros fueron los que permitieron el auge de tal figura, desarrollada igualmente en las décadas posteriores a la Revolución francesa, no necesariamente concordante con el modelo actual prevaleciente hispano y, por tanto, costarricense, de un órgano del poder judicial con potestades revisoras, pero sí de un contralor de legalidad:

> *"Es así como, en Francia, durante el transcurso del Siglo XIX, nace el Consejo de Estado o Conseil d'Etat, creado por Napoleón Bonaparte mediante el artículo 52 de la Constitución del 22 frimario del año VIII (15 diciembre 1799), la cual sustituyó así al antiguo Consejo del Rey y al sistema creado por las constituciones de los años 1791 y 1795, que reservaba el control de la legalidad de la actuación administrativa a la propia administración activa. El precepto establecía:< sous la direction des Consuls, un Conseil*

[4] *Ibidem.*
[5] *Ibid.* P 143.

d'Etat est chargé de rediger les projets de lois et les réglements d' administration publique et résoudre les difficultés qui s'elévent en matiére administrative>. Es decir, que el Consejo de Estado serviría como órgano de consulta del Ejecutivo, además se encargaría de preparar los proyectos de decisiones que debía tomar el Jefe de Estado, y conocería además de los asuntos contencioso-administrativos, aunque la decisión última de aquella materia correspondería al Jefe del Ejecutivo."[6]

La creación del Consejo de Estado en Francia y su posterior desarrollo y fortalecimiento de potestades, fueron temas sumamente controvertidos, al igual que lo fue la mayoría de las reformas tendientes a limitar el poder del soberano mediante la imposición de controles cruzados, de cara la neófita división de poderes y el control de la actividad de la Administración Pública. En suma, gestado en el recién creado Consejo de Estado, la concepción de Acto de Gobierno comenzó a erigirse:

"La noción de acto político o Acto de Gobierno, es una creación de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y se refiere a un tipo o conjunto de actos realizados por el Poder Ejecutivo que por su naturaleza no se sometían al control de la jurisdicción contenciosa administrativa.[7]

Como ya se mencionó, el naciente control sobre la potestad de quien detentó el poder ejecutivo, encontró serios reparos por razones evidentes. El absolutismo se aferró por todos su medios en la reciente República Francesa, entre otras razones por el resurgimiento de movimientos monárquicos dentro del país, tras el derrocamiento de Napoleón. También es cierto que tal resurgimiento tuvo lugar, en parte, motivado por las presiones externas generadas por las monarquías vecinas que vieron en el naciente movimiento francés una seria amenaza para su estabilidad y el prolongamiento de ese modelo en sus respectivos países. En ese sentido:

"El origen histórico de esta categoría, según la formulación de Duez y que mayoritariamente ha seguido la doctrina, coincide con la época que siguió a la caída del imperio napoleónico y la restauración borbónica en la que el Consejo de Estado, ante los

[6] Mariana Garay Sims y Boris Castro Fuenzalida. Los actos de gobierno/políticos y su control jurisdiccional en el Derecho Público Chileno. Trabajo Final de Graduación (Santiago, Chile: 2018). P 36.

[7] Marcheno Acuña, B. El control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno en el derecho español. Madrid, España. Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje. Vol. 2, no 2. Pp 4.

temores de su desaparición, comienza a autolimitar sus competencias jurisdiccionales, restringiéndolas muchas veces en favor de los tribunales ordinarios y rechazando el conocimiento de aquellas controversias derivadas de las cuestiones políticas dejándolas a la disponibilidad de la Administración activa."[8]

Tal y como se expuso, la creación del Acto de Gobierno como instituto jurídico no fue otra cosa que una autolimitación que se impuso el Consejo de Estado, en aras de no molestar en exceso a los poderes públicos absolutistas. Es claro que el recién creado Consejo de Estado rehusó de conocer ciertas acciones de la Administración Estatal por motivos variados; destacan la lucha por retomar el poder de las monarquías hasta antes imperantes, la presión extranjera que de forma directa injirió sobre la nueva forma de gobierno republicana y, hasta la misma iniciativa de las autoridades contraloras que conformaron el Consejo de Estado de no desaparecer frente a estas presiones, teniendo que ceder terreno en pro de ello. Para esto último, según explicó Agustín Gordillo:

"En cumplimiento de este propósito, primero giró a los tribunales judiciales algunas materias que antes eran de su competencia y después a otras cuestiones las consideró "irrecevables," es decir, no revisibles y ni siquiera receptibles por su parte: La acción o recurso era directamente rechazada mediante la interposición por parte de la administración de algo que se designó como "fin de non recevoir." Estas materias que el Consejo de Estado se negaba a considerar y que tampoco enviaba a los tribunales judiciales, quedaban por tal causa huérfanas de todo control jurisdiccional, produciéndose así una denegación de justicia que con distintas variantes se prolonga hasta nuestros días; éstos son los actos de gobierno."[9]

Esta denegación de justicia, mencionada por el autor, no es otra cosa que la exclusión de una parcela del accionar de la Administración Pública al contralor fijado para, precisamente, verificar tal accionar. La generación en los fallos del Consejo de Estado francés, hacia el siglo posterior a la Revolución francesa, de ese espacio libre en el que las determinaciones de la Administración Pública no son revisables, es lo que finalmente se acuñó bajo el término de Acto de Gobierno.

---

[8] *Ibid.* P5.

9 Gordillo, A. Tratado de Derecho Administrativo, tomo 8. Buenos Aires, Argentina: FDA. 2013. P 419.

Esta creación jurisprudencial fue, en definitiva, una necesidad que surgió para el recién creado Consejo de Estado, cuyas opciones eran sumamente limitadas en el ejercicio de su tambaleante control de la legalidad de las potestades administrativas. La generación del Acto de Gobierno como instituto jurídico ya había tenido lugar desde la primera mitad del siglo XIX:

> *"nace en el Derecho francés durante la etapa de la Restauración Borbónica, como un mecanismo defensivo del Consejo de Estado que tenía que hacerse perdonar sus orígenes napoleónicos y luchar por su pervivencia. Ese concepto grato a los nuevos gobernantes le permite excluir del recurso por exceso de poder los actos de la Administración y fundamentalmente del Gobierno, que aparecieran inspirados en un «móvil político», calificándolos como actos judicialmente inatacables.*[10]

Pese a lo anterior, su delimitación precisa se da con un precedente jurisprudencial concreto, como lo fue el Arret Prince Napoleón, de 1875, sobre ello:

> *"En un rasgo de prudencia, el Consejo de Estado acordó declararse incompetente para juzgar todos aquellos actos del Gobierno que tuviera un inequívoco móvil político (Arret Prince Napoleón, de 19 de febrero de 1875, en recurso contra un acto ministerial que denegaba restablecer en el listado de generales del ejército al recurrente, por su vinculación familiar con el destronado Emperador Napoleón III). Desde entonces, esta categoría se ha mantenido en el Derecho francés."*[11]

Puede observarse que el Acto de Gobierno, entendido como una excepción del sometimiento plenario de la actividad de la Administración Pública a un contralor de legalidad, se generó a raíz de la pugna entre las instituciones encargadas de realizar tal control y los poderes políticos que se rehusaban a perder su estatus monárquico (absolutista, concentrado, irrevisable). De ello se denota que, desde su propio génesis, el Acto de Gobierno nace como una justificación para perpetuar el absolutismo en ciertos ámbitos específicos del actuar de la Administración Pública, no porque ello fuese conveniente para el ejercicio de un control de legalidad plenario y garantista, empero, porque

[10] Parada, R. *Derecho Administrativo*. Madrid, España: Marcial Pons. 1997. P 98.

11 Sánchez Morón, M. Derecho Administrativo Parte General. España: Tecnos. 2006. P 522.

era indispensable para que los nuevos poderes políticos, del todo, tolerasen un contralor de legalidad.

Sección Segunda: Evolución en el Derecho español

Del derecho español derivan la inmensa mayoría de nuestras instituciones jurídicas, ya sea porque se generaron en el seno de esa tradición o porque allí se realizaron las adaptaciones desde otras latitudes (Alemania, Francia, Italia, entre otras) que, finalmente, arribaron a suelo costarricense y se transformaron en doctrina o en derecho positivo. Ello ha sido así casi sin excepción, y particularmente en el derecho administrativo existe una fuerte influencia de la doctrina, jurisprudencia y normativa española.

El enlace y la influencia expuesta anteriormente se pueden explicar desde varias aristas. De arranque pareciera más que evidente que un factor determinante es el antiquísimo vínculo geopolítico e institucional que se tiene con España, debido al hecho de haber sido una colonia bajo el yugo español por centurias, lo cual acarreó la subyugación e imposición violenta (por la fuerza) de todas las instituciones y costumbres de ese país. Tal práctica fue común a todo el colonialismo europeo transatlántico, iniciado en el siglo XVI. Otra razón de peso, estrechamente vinculada con la anterior, es el compartir la lengua (la castellana), lo que permite que con mayor facilidad la doctrina científica, el bloque de juridicidad y los antecedentes jurisprudenciales de relevancia estén inmersos en un trasiego directo y constante entre ambos países.

De lo anterior se justifica la importancia de entender el desarrollo de un instituto jurídico en el derecho español, incluso de previo a analizar ese mismo trayecto dentro del derecho costarricense. En relación con el Acto de Gobierno en específico, se inició con su contexto de origen, que tal y como se expuso anteriormente, se halla indudablemente en el derecho francés; no obstante, por ser el derecho español el vínculo natural o la conexión entre el origen franco del instituto, hasta la llegada del concepto al derecho costarricense, inevitablemente se debe conocer el paso del Acto de Gobierno por la doctrina, jurisprudencia y normativa española.

Un último punto a tener en cuenta, de previo a verificar los principales hitos del Acto de Gobierno y su desarrollo en la historia del derecho español, son las diferencias que existieron entre esa tradición jurídica y la francesa. Lo anterior, en tanto que en Francia se estaban gestando los movimientos culturales y políticos desarrollados en la sección anterior, todos ideales revolucionarios y contrarios al absolutismo monárquico que regía en todo el resto de Europa. Lo

cierto es que tal auge revolucionario no tuvo el mismo fervor en todos los países de ese continente, durante las décadas que siguieron a la Francia post revolucionaria. España es uno de los tantos ejemplos, donde el modelo monárquico continuó ininterrumpidamente y, si hubo algún efecto del eco de la revolución iniciada en Francia, se desarrolló de manera gradual y sin la misma vertiginosidad que tuvo lugar en su país vecino del norte.

Lo que se quiere recalcar es que tomó muchas décadas más en España para que la justicia administrativa alcanzara el grado de plenitud y articulación que tuvo en Francia durante las décadas que siguieron a la Revolución. Muchos institutos garantistas (y algunos no tanto, como lo podría ser el propio Acto de Gobierno), tardaron mucho más tiempo en asentarse en España de lo que tardaron en Francia, no solamente debido a la vanguardia doctrinaria que encabezó durante décadas el país galo, sino también por la resistencia mucho más férrea y difícil de vencer que plantó la monarquía española después de la caída del imperio francés y la dominación napoleónica, monarquía que (si bien, actualmente parlamentaria) se mantiene hasta nuestros días.

Recapitulando el punto al que arribó el instituto en Francia, durante la primera mitad del siglo XIX (periodo en el que se desarrolló en la jurisprudencia del Consejo de Estado) y la segunda mitad de ese mismo siglo (periodo en el que se consolidó la figura y se asentó en el derecho francés), se tiene que:

> *"a partir de 1875 el Consejo de Estado reducirá al máximo este concepto, ciñéndolo a los actos dictados en ejercicio de la función gubernamental como distinta de la función administrativa. Propios de aquélla se consideran ya únicamente las funciones de relación del Gobierno con el Parlamento y otros poderes públicos, los actos relativos a las relaciones internacionales y las medidas referentes a la conducción de la guerra; por consiguiente, los actos que se dictan sobre estas materias no se consideran actos administrativos o afectos de su fiscalización jurisdiccional, pero sí todas las demás disposiciones y resoluciones del Gobierno."*[12]

No obstante lo anterior, en España, de acuerdo con las causas mencionadas, el desarrollo del derecho administrativo, particularmente en lo relativo al establecimiento de un contralor de

[12] Parada, R. *Derecho Administrativo*. Madrid, España: Marcial Pons. 1997. Pp 98-99.

legalidad del accionar de la Administración, tardó mucho más en desarrollarse. El propio Ramón Parada detalló que:

> *"En nuestros primeros textos sobre la Justicia administrativa (Ley de Organización y Atribuciones del Consejo Real de 6 de julio de 1845 y Reglamento de 30 de diciembre de 1846, sobre el modo de proceder en los negocios contenciosos de la Administración que se ventilan en el Consejo Real) no ha lugar el concepto de Acto de Gobierno, porque ni si quiera existe un recurso por exceso de poder circunscribiéndose el de plena jurisdicción a los recursos originados por el cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los remates y contratos celebrados por los distintos ramos de la Administración. Todos los demás recursos, es decir, los originados por las demandas contenciosas a que daban lugar las resoluciones de los Ministros, sólo podían ser enjuiciados cuando el propio Ministro, previa audiencia del Consejo de Ministros, así lo aceptase".*[13]

Se puede notar una justicia administrativa sumamente limitada, lo dicho se plasma en el hito más remoto de control de legalidad sobre el poder ejecutivo en el derecho español, como lo es la mencionada Ley de Organización y Atribuciones del Consejo Real del 6 de julio de 1845, así como el Reglamento del 30 de diciembre de 1846. El autor detalla que, dado que del todo no existían recursos contra las ilegalidades o nulidades que se pudieran generar en el actuar de la Administración Pública o, en caso de existir, su trámite era no solamente complicado sino que además dependía para efectos de su admisión de la propia Administración, en ese caso, del Ministro de ramo, de ahí que no tuviera sentido (por tanto no se contempló) el Acto de Gobierno, entendido como la exclusión de una parte del accionar de la Administración Pública del contralor de legalidad. No tendría sentido en el tanto el control de legalidad sobre el accionar de la Administración era prácticamente inexistente. Sobre esta complejidad para controlar el accionar de la Administración resalta el artículo 52 del citado Real Decreto del 30 de diciembre de 1846, que estipuló:

> *"Si en vista de la demanda estimare desde luego el Ministro de la Corona que procede la vía contenciosa, remitirá el expediente al Consejo para el curso correspondiente. Si el*

[13] *Ibid.* P99

Ministro de la Corona no lo estimare así desde luego, oirá gubernativamente al Consejo sobre esta cuestión previa y la resolverá en vista de la consulta, sin ulterior recurso."[14]

En ese claro panorama, en donde a todas luces imperó la irrecurribilidad de prácticamente todas las actuaciones y resoluciones de la Administración central del Estado, o lo que se conoce actualmente como poder ejecutivo, no tendría ningún sentido el planteamiento de una exclusión, como lo es el Acto de Gobierno. Entonces es claro que, si nos remontamos al primer hito de justicia administrativa en España, no se encontrarán vestigios del Acto de Gobierno; de cara a las razones expuestas y, como se desarrolló en el apartado anterior, el instituto ya existía en Francia y había sido delimitado por la jurisprudencia del consejo de Estado. Con razón de lo expuesto, entonces cabe preguntarse ¿cuándo apareció por primera vez la figura en el derecho español?

"El concepto aparece precisamente cuando la materia contenciosa se amplía y define por la técnica de la cláusula general con determinadas excepciones, que es lo que tiene lugar con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Santamaría de Paredes de 1888. Justamente entonces se configuran los actos políticos o de gobierno como una clase o suerte de actos que, por entenderse referidos a materias «que pertenecen señaladamente a la potestad discrecional», se excluyen del control jurisdiccional."[15]

Como se puede observar de la cita, el criterio para tener por no justiciables estos Actos Administrativos estuvo estrechamente vinculado con la potestad discrecional, por considerarse que los actos que se ejercieran dentro de ese marco no debían estar sujetos al control de legalidad. Ello estrechamente vinculado con la doctrina del móvil político, desarrollada en Francia durante el siglo XIX (que se estudiará a fondo en apartados posteriores), que establecía un criterio teleológico, es decir, enfocado en la finalidad de los actos, para efectos de determinar la naturaleza de estos, en este caso en concreto (actos con móviles políticos, Actos de Gobierno), su sometimiento al contralor de legalidad. Mediante la teoría del móvil político, se trató de excluir decisiones consideradas meramente políticas (por tanto no vinculadas con la función administrativa del Estado), las cuales serían inmunes al control judicial en su totalidad, por lo cual quedarían a la exclusiva voluntad de la Administración actuante, en este caso el Gobierno.

[14] *Ibidem.*
[15] *Ibidem.*

"La recepción de esa doctrina, como se sabe, tendrá una primera plasmación en el reglamento de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 13 de septiembre de 1888, al integrar esos actos entre los que conforman la potestad discrecional, expresamente excluida por el art. 4 del ámbito de conocimiento de esos tribunales y de cualesquiera otros. Esta integración será, sin embargo, suprimida por aquella LJCA, que al justificar el sentido de dicha jurisdicción explicitará cómo, creada para conocer de las cuestiones que se susciten respecto de los actos sujetos al derecho administrativo, sus límites están determinados normalmente por la esencia de esta rama del derecho, en cuanto parte del ordenamiento jurídico, y con este criterio se «definen, por exclusión, las cuestiones ajenas a esta Jurisdicción». Entre ellas se incluyen «las relativas a los actos políticos, que no constituyen una especie del género de los actos administrativos discrecionales, caracterizada por un grado máximo de la discrecionalidad, sino actos esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, confiada únicamente a los supremos órganos estatales»."[16]

Si bien se esboza un vestigio de lo que posteriormente pasaría a conocerse como Acto de Gobierno, este incipiente instituto se adscribió al acto discrecional, nutriéndose de ese instituto para delimitar sus características y, finalmente, determinar lo relativo a su impugnabilidad ante el contralor de legalidad contencioso. Ciertamente, tal planteamiento presentó los problemas descritos, que finalmente arrojaron a la conclusión ineludible, de que la discrecionalidad existente en los elementos de algunos actos no era suficiente ni consistente para justificar la existencia de los actos políticos o de Gobierno. De lo anterior se colige que la integración de los actos políticos dentro de la especie de los actos discrecionales no fructificó y, por el contrario, fue cambiada casi de inmediato, dentro del derecho español. Con lo cual se generó un espacio vacío en el que no era posible controlar las resoluciones de la Administración.

"el extraordinario avance que supone la ratificación del control judicial de los actos discrecionales en esa ley quedaba claramente mermado con la exclusión que en la parte dispositiva concretaba aquel precepto de «las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno, como son los que afecten a la defensa del territorio

16 Díez Sánchez, J. R. El Control Jurisdiccional de los actos del gobierno y de los consejos de gobierno. Revista Jurídica de Castilla y León. N.° 26. P 52.

nacional, las relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar», aunque se atribuyera a dicha jurisdicción conocer y determinar las indemnizaciones que fueran procedentes."[17]

La distinción entre acto de orden político o de Gobierno nació con este reglamento y esta ley, siendo los primeros hitos históricos en el derecho español donde se consolidaron. Tuvo lugar la concreción normativa de:

"*un concepto que ya había estado desde antes en el pensamiento del legislador – manifestado en los debates parlamentarios y en los proyectos que precedieron a la ley de 1888 – y que había sido incorporado por la jurisprudencia en virtud de la interpretación y aplicación del art. 4 de la Ley.*[18]

En la jurisprudencia subsecuente a la promulgación de la Ley Santamaría Paredes de 1888 se reforzó la diferenciación expuesta, en tanto se estableció de manera tajante la diferencia entre los actos propios de la función administrativa de unos diferenciados, como podrían ser los que tenían un móvil evidentemente político, sobre ello en auto de 16-11-1889. Gaceta de Madrid- 12/10/1890 y, en los mismos términos SSTS 1-10, de diciembre de 1889 Gaceta de Madrid 27-11-1891, se contempló:

«se hallan fuera de la competencia de los tribunales contencioso- administrativos, las resoluciones que se refieren a la potestad discrecional de la Administración, a la cual pertenecen todas las que en sí contengan no a un acto de administración, sino de gobierno a cuyo orden corresponden las determinaciones sobre las competencias de la Administración activa»[19]

Para este punto se nota claramente la diferenciación o disgregación completa del Acto de Gobierno como instituto jurídico, no solamente porque se menciona directamente, en el antecedente transcrito, sino porque se determinan sus consecuencias prácticas; la más característica, sin duda, el estar por completo excluido de la recién generada Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Queda entonces definido como una manifestación de la potestad discrecional de la Administración,

[17] *Ibidem.*
[18] Marcheno Acuña, B. El control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno en el derecho español. Madrid, España. Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje. Vol 2, no 2. Pp 8.
[19] *Ibidem.*

empero, no como un Acto Administrativo (o como le denomina el precedente, de administración) sino como una actuación de otra índole.

Se determinó la excepción de incompetencia de jurisdicción para los casos en que se trate de impugnar Actos de Gobierno dentro del régimen jurídico español de la época. Este deslinde que se genera no solamente atañe a un tipo de acto específico, y sus consecuencias materiales en el derecho procesal imperante, sino que también se da una desvinculación más profunda, en tanto tiene lugar (acaso, de manera tácita) la separación entre función gubernativa y función administrativa, tema que se desarrollará más adelante, por lo pronto, cabe advertir que:

> *"Es de notar que, en esta primera jurisprudencia, aparece un atisbo de conceptualización del acto de gobierno mediante la distinción entre función administrativa y de gobierno. Para el tribunal, el acto de gobierno constituía una manifestación la potestad discrecional de la Administración, pero era distinto del acto «de administración», también discrecional. Es decir, acto administrativo y acto de gobierno eran conceptos distintos y separados, expresión de dos funciones también diferenciables – la mera administración y el gobierno –, aunque estas se manifestasen a través del mismo poder discrecional."*[20]

Se asentó la principal característica del Acto de Gobierno, que a todas luces fue su inimpugnabilidad ante la sede jurisdiccional contenciosa administrativa, ello se mantuvo así durante todo el periodo que abarcó la vigencia de la Ley de Santamaría Paredes, manteniendo en todo momento intacto su núcleo distintivo, la mencionada inimpugnabilidad. Como lo mencionó el autor recién citado, ambos institutos (acto discrecional y Acto de Gobierno) se concibieron como provenientes de una misma fuente (la potestad discrecional) pero ahora, diferenciados entre sí. Ello cambió de alguna manera con el advenimiento de la Guerra Civil de 1939 y las posteriores reformas estatales que acaecieron con la toma de poder de la dictadura franquista.

> *"Con posterioridad a 1894 y hasta 1956 se produjeron otros cambios legislativos importantes que afectaron el régimen jurídico del Acto de Gobierno configurado en la legislación anterior –que continúo vigente –, pero que en ningún caso cambiaron su esencia, como acto discrecional no fiscalizable en sede judicial. En 1944, la Ley de la Jefatura del Estado restaura, con algunas modificaciones, el sistema contencioso-*

[20] *Ibid.* P 9.

administrativo de la Ley de Santamaría de Paredes, suspendido al culminar la guerra civil en 1939. En su artículo segundo dispuso que «quedan excluidas, como pertenecientes al orden político o de gobierno las resoluciones que la Administración dictare en aplicación y ejecución de las leyes y disposiciones referentes a depuración, responsabilidades políticas, desbloqueo, prensa y propaganda y abastecimientos.»"[21]

Tal y como se pudo observar del texto transcrito, el advenimiento de la Guerra Civil y la posterior implantación de una dictadura militar, así como la conmoción y quebranto del orden constitucional imperante que ello significó, se generaron algunos cambios en la estructura contenciosa administrativa y para efectos de lo que interesa, del Acto de Gobierno, que contrastó con lo imperante hasta el momento, es decir, lo determinado a raíz de la ley Santamaría Paredes de 1888. Tales cambios tendieron al absolutismo que recién ocupaba el poder. Una vez tomado el poder político por las armas, la dictadura debía preservarse en el tiempo mediante la promulgación de leyes, e incluso reformas constitucionales (totales o parciales) que así lo asegurasen.

El principio es evidente, una vez tomado el poder y despejados los nublados del día (despachada la oposición) las dictaduras implantan regímenes absolutos y herméticos que, sobre la base pseudo técnica y dorada del derecho, afianzan su poder disfrazado de coherencia, para así tener legitimidad. En este caso específico, se amplió la gama de temas que encajaban en la categoría de móviles políticos, como prensa y propaganda, para deslindar el mayor espacio posible en el actuar administrativo del contralor de legalidad. Existe una clara correlación entre la toma del poder político por parte de una organización absolutista y el fortalecimiento de la figura del Acto de Gobierno dentro del derecho público. En suma, de acuerdo con la propia jurisprudencia posterior a estas reformas post Guerra Civil:

"«completar la puntualización de las mismas con la mención de las materias relacionadas con la depuración, responsabilidades políticas, desbloqueo, prensa y propaganda y abastecimientos; y es claro que la circunstancia de figurar en la enumeración asuntos que pudieran ser dudosos conceptuar desde luego como de orden económico o monetario, junto con las restantes, lo que patentiza es que, sin eliminar del concepto de acto político los que tradicionalmente se estimaban como tales, lo único que se ha efectuado es una adición

[21] *Ibidem.*

legal que en ningún modo puede juzgarse limitativa, sino ampliación de lo ya vigente» (STS 21 de mayo de 1952. Ar. 949)"[22]

Esta nueva disposición normativa y el posterior pronunciamiento jurisprudencial guardan una diferencia relevante con respecto a la anterior norma, en tanto como se enuncia en el antecedente de 1952 transcrito, se amplía la gama de actos administrativos que encajan dentro del concepto de Acto de Gobierno y, por lo cual, quedan exentos de control jurisdiccional. Con la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (LJCA) de 1956, en España se determina el Acto de Gobierno como uno propio y diferenciado del discrecional, deslindándose con ello por completo una categoría de la otra, hito que permanecía incierto desde la anterior regulación de 1888, pero que finalmente se consolidó por completo a partir de esta nueva regulación.

"al margen de otros antecedentes, con la ljca de 1956 se acuña pues la categoría del acto político como acto distinto al Acto Administrativo discrecional por derivar de la función política. La búsqueda de criterios delimitadores entre ambos pasará a ser, desde entonces, una constante en la labor jurisprudencial que en todo momento admitirá esa diferenciación en relación al control judicial y, en consecuencia, no negará ni cuestionará la existencia del acto político. En tanto doctrinalmente en unos casos se convendrá en esa misma tesis e incluso en las tesis más influyentes que rechazan el concepto y la categoría de actos políticos, se admitirá la infiscalización judicial de ciertas actuaciones gubernativas. En la evolución de ambas doctrinas jurisprudencial y científica a propósito del acto político y su control judicial tendrá una influencia decisiva la aprobación de la constitución y más tarde, consecuencia de las derivaciones extraídas de ella, la nueva ljca de 1998."[23]

Resulta claro entonces que la estrecha relación que el Acto Administrativo discrecional y el Acto de Gobierno venían manteniendo desde la segunda mitad del siglo XIX, se disgrega por completo con la normativa de 1956. El criterio más importante para realizar este deslinde, fue el asumir por completo la diferencia entre la función política y la función administrativa, si bien podía coexistir elementos de la potestad discrecional en uno y otro tipo de actos (e incluso en otras categorías no mencionadas), lo cierto es que el acto político o de Gobierno no encajaba dentro de la función

[22] *Ibid.* P10.
[23] Díez Sánchez, J. R. El Control Jurisdiccional de los actos del gobierno y de los consejos de gobierno. Revista Jurídica de Castilla y León. N.° 26. P 53.

administrativa, sino que proviene de una diferenciada denominada función política o de Gobierno y, por ello, se justifica su diferenciación con el Acto Administrativo discrecional, proveniente de la función administrativa.

Ya en la segunda mitad del siglo XX, el derecho administrativo español, específicamente en lo relativo al acto político o de Gobierno sufrió modificaciones importantes en pro de una fiscalización y un control más estrecho. Lo anterior debido a diferentes circunstancias, por un lado científicas, en tanto la doctrina contemporánea y más aceptada del derecho administrativo de la época apuntó hacia el garantismo y el control estrecho de las acciones y resoluciones de la Administración Pública, por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa adscrita al poder judicial. También, debido a razones políticas, por el debilitamiento del absolutismo militar en España, en beneficio de la instalación de una monarquía parlamentaria, menos autoritaria y tendiente a la democratización de las instituciones, y por tanto, del derecho. Ya consolidada la sustracción del Acto de Gobierno, como parte de los actos administrativos discrecionales de la Administración, se trató de establecer taxativamente los escenarios donde la inimpugnabilidad del Acto de Gobierno operaba.

> *"Con un cambio de perspectiva, abandonando la idea de la configuración del Acto de Gobierno como parte de la potestad discrecional – la que, muy acertadamente no se reconoce que exista de forma absoluta – y asumiendo el criterio de la separación entre función política y función administrativa, el Acto de Gobierno es retomado en la Ley de la Jurisdicción contenciosa de 1956 exceptuándose también de la revisión judicial. Así, lo refleja claramente la Exposición de Motivos: «Con este criterio (el del sometimiento al Derecho administrativo) se definen, por exclusión, las cuestiones ajenas a esta Jurisdicción. Entre ellas se incluyen las relativas a los actos políticos, que no constituyen una especie del género de los actos administrativos discrecionales, caracterizada por un grado máximo de discrecionalidad, sino actos esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, confiada únicamente a los supremos órganos estatales.»"*[24]

[24] Marcheno Acuña, B. El control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno en el derecho español. Madrid, España. Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje. Vol. 2, no 2. Pp 11.

Un primer atisbo de mejoramiento en el control jurisdiccional del Acto de Gobierno fue la separación completa del Acto de Gobierno de la teoría de las potestades discrecionales, en parte, porque se acuñó la idea del hecho de que una potestad fuese discrecional no alcanzaba para justificar que estuviera exenta de la fiscalización contenciosa administrativa. En todo caso, con la LJCA de 1956, se estableció la potestad del contralor contencioso administrativo para revisar también las potestades discrecionales de la Administración Pública activa. El artículo 2b de la propia LJCA de 1956, en lo concerniente, contempló:

> *«las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno, como son los que afecten a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueran procedentes, cuya determinación sí corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa.»*[25]

Ya para este punto (segunda mitad del siglo XX, a raíz de la promulgación de la LJCA) el Acto de Gobierno era un instituto plenamente reconocido que, además, se encontraba definido de manera clara. En las décadas posteriores a la LJCA de 1956, se inició un debate doctrinal en España, a raíz de la figura del Acto de Gobierno. Algún sector de la doctrina lo observó como un vestigio autoritario e incluso, más atrás en el tiempo, un instituto monárquico-absolutista, que no tenía cabida en una democracia, como lo sería una Monarquía Parlamentaria. Otros, sin embargo, sacrificando el control plenario que tiene el juez contencioso sobre el accionar de la Administración, abogaron por el sostenimiento de la figura bajo ciertos parámetros determinados. Sobre ello, se destaca la posición del más importante tratadista de la segunda mitad del siglo XX en el derecho administrativo español, Eduardo García de Enterría, en el primero de los sentidos reseñados:

> *"se exacerbará especialmente ese antagonismo a propósito de la tramitación del Proyecto de ley de 1995 de la jurisdicción contencioso-administrativa, teniendo en cuenta la significativa jurisprudencia del tc y sobre todo del ts dictada poco antes de esa fecha y dado el intento que por vía legal se pretendía reintroducir: en palabras de García de Enterría, el viejo concepto de Acto de Gobierno como «acto de dirección política» y aun*

[25] *Ibidem.*

extenderlo a autoridades inferiores. Las acerbas críticas que ese texto mereció y la vivísima polémica doctrinal que se puso de manifiesto con ese motivo son de sobra conocidas y no es ahora necesario reproducirlas, si acaso recordar que son consecuencia directa de ellas: de una parte, que dicho proyecto es rectificado y con retraso el posterior sería el que nos suministra la redacción que acabaría transformándose en la ley actual; y de otra, que en general las diferentes posiciones doctrinales coincidirían en que la idea del estado de derecho impide la ausencia de todo control de algunas decisiones del poder público y en el abandono de la teoría del móvil político para justificar la exención de ese control, sustituida por la consideración de que esas actuaciones son el producto de determinadas actuaciones del Gobierno, manifestaciones de su posición como órgano constitucional, que no están sometidas al derecho administrativo."[26]

Tal y como se puede observar, con la ley de finales del siglo XX (la cual no será objeto de mayor desarrollo en esta sección, por ser la posición contemporánea del instituto), se adopta una posición ya no teleológica para justificar el Acto de Gobierno (tener un fin político o de gobierno), ni siquiera funcional (estar enmarcado dentro de los actos discrecionales o cumplir una función política o gubernativa), sino que su injusticiabilidad se sostiene sobre una base, podría decirse, positivista; es decir, por estar así dispuesto en la Constitución Política. Esta posición es la que, precisamente, atacó algún sector importante de la doctrina, como lo expuesto por Eduardo García de Enterría (cuya doctrina sobre este instituto ocupará sendos desarrollos posteriormente en esta labor investigativa), aunque también tuvieron lugar voces que propugnaban, en sentido contrario, por el mantenimiento de la figura. Por contracara, otras posiciones en relación con el tema y que fueron base para la discusión descrita *supra*, es la de Cosculluela Montaner:

"Lo que en sentido contrario, conforme sintetiza Cosculluela Montaner supone admitir que es correcta la doctrina que afirma que tras la constitución existen actos del Gobierno insusceptibles de recurso contencioso-administrativo, en tanto que actuaciones del Poder ejecutivo no regidas por el derecho administrativo y que no encajan por tanto en el presupuesto necesario para el conocimiento de un asunto en sede jurisdiccional, como también aquella línea de discurso que sostiene la inexistencia de actos políticos pero

[26] Díez Sánchez, J. R. El Control Jurisdiccional de los actos del gobierno y de los consejos de gobierno. Revista Jurídica de Castilla y León. N.° 26. Pp 54-55.

reconoce la falta de competencia de esa jurisdicción para enjuiciar todas las actuaciones del Gobierno en cuanto Poder ejecutivo que se ordenan directamente por la constitución. En tanto regidas por el derecho constitucional o el parlamentario, correspondería al tc la competencia exclusiva para conocer de las cuestiones que se susciten en relación con esos actos del Gobierno, en los términos que establece la lotc, o únicamente serían objeto de control por el Parlamento"[27]

Esta disyuntiva conllevó también una serie de fallos jurisprudenciales en uno y otro sentido, lo cual se desarrolló por décadas. La discusión giró principalmente alrededor de dos aristas específicas del Acto de Gobierno. La primera de ellas, el aspecto orgánico, es decir, la definición competencial del dictado de los mismos, en tanto en la multiplicidad de Administraciones Públicas que conviven en el derecho español era menester determinar cuáles de ellas podían emitir actos políticos o de Gobierno. En cuanto a un segundo aspecto, esta vez sustancial, es decir, la revisión de los elementos del Acto de Gobierno y cuáles de ellos podrían ser justiciables, se arribó a la conclusión de que lo eran los reglados. De lo anterior se colige que la inadmisibilidad estuvo estrechamente vinculada con la existencia de estos elementos específicos y la forma en la que estuvieron dispuestos en el acto en cuestión que se pretendiese impugnar. Sobre ello:

"en definitiva, cabe resumir esta transformación, señalando que se mantiene y reafirma la categoría del acto político pero despojada definitivamente de su connotación originaria. En el plano orgánico, reafirmado queda que sólo alcanza a la función política del Gobierno como consejo de Ministros, y en lo sustancial que el concepto de acto político no impedía sino al contrario imponía a los órganos judiciales rechazar la inadmisibilidad de los recursos, aunque esto resultaba procedente para algunas de las decisiones enmarcadas como propias del título v de la ce."[28]

Ciertamente, a raíz de estos aportes doctrinarios y normativos al instituto del Acto de Gobierno, en las décadas posteriores a la ley de 1956 tiene lugar también un cambio en el mecanismo procesal con el que se asumen. No es que el recurso interpuesto contra un acto político es del todo

[27] *Ibid.,* p 55.
[28] *Ibid.,* pp 59-60.

inadmisible, *a priori*, como lo venía siendo desde el siglo XIX, sino que dado que solamente ciertos elementos del mismo son justiciables, se debe entrar a revisar esos elementos específicos:

> *"Los conceptos judicialmente asequibles, entendidos como elementos reglados y como requisitos objetivos, deparan una justiciabilidad parcial de los actos políticos, por lo que procede no la inadmisión del recurso directo contra ellos (como pretenden habitualmente los abogados del estado o los letrados autonómicos), sino su admisión para verificar si tales elementos reglados existen y han sido respetados. ahora bien, no se queda exclusivamente en esa aparentemente clara previsión de límites o requisitos normativamente establecidos ese control, pues obvio resulta que la casuística expuesta demuestra que alcanza asimismo la valoración de la decisión gubernamental en tanto afecte a otros derechos o valores constitucionales. Ciertamente, sobre ellos el control judicial no es pleno, sólo tendrán posibilidad de controlar algunos aspectos de estos actos y no otros, sin que sea fácil apreciar la línea divisoria para saber con exactitud cuándo la decisión judicial supera o no el límite de lo jurisdiccionalmente posible, y sin que como veremos más adelante resulte sin más plausible despachar el asunto por la presencia o ausencia de elementos reglados en una acepción más o menos amplia o indeterminada."*[29]

Entonces, el Acto de Gobierno inició su trayecto en el derecho español como una importación de lo desarrollado por el Consejo de Estado francés, cuya jurisprudencia desde la primera mitad del siglo XIX empezó a delimitar el instituto a nivel conceptual y sus implicaciones procesales, dentro de la incipiente jurisdicción contenciosa administrativa. Posteriormente, la legislación española de segunda mitad del siglo XIX, particularmente reflejada en la Ley Santamaría Paredes de 1888 y sus decretos conexos, contempló la figura, empero, la confundía con el ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración Pública.

Entrado el siglo XX y bajo la vigencia de la propia Ley Santamaría Paredes, el advenimiento del absolutismo y la dictadura militar española, ampliaron de sobremanera el concepto de acto político o de Gobierno, en aras, claro está, de extender la esfera donde el actuar y las resoluciones del ejecutivo no fueran susceptibles de revisión ante el contralor de legalidad. Por lo dicho, en lo que respecta al Acto de Gobierno, se ampliaron de gran manera los supuestos a actividades como la

[29] *Ibidem.*

propaganda, de acuerdo al absolutismo imperante y los fines descritos. Aún durante este periodo de dictadura, se introdujo la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1956, en la cual se disgregó el Acto Administrativo discrecional del de Gobierno, principalmente por un criterio funcional, pese a que ambos estaban vinculados con la potestad discrecional de la Administración, obedecían a funciones diferenciadas (gubernativa en un caso y administrativa en otro).

En las décadas posteriores a la promulgación de la Ley de 1956, algunas de las voces doctrinarias más relevantes establecieron una discusión sobre la justiciabilidad de los actos de gobierno, particularmente de cara a las previsiones constitucionales (de inargumentable jeraquía normativa) que existen sobre el tema, así como la revisión de al menos algunos elementos (particularmente los reglados) del Acto de Gobierno, por parte del contralor de legalidad. A partir de la base ofrecida por esta discusión, se han asentado la normativa y la doctrina contemporánea del Acto de Gobierno, la cual ocupará la mayor parte de la presente investigación.

Sección Tercera: Evolución en el Derecho costarricense

En Costa Rica, la doctrina del Acto de Gobierno, así como la de otros muchos institutos dentro del derecho administrativo, fue desarrollada en muy reciente data. Podría desde ya adelantarse que no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que tuvo lugar algún desarrollo legal, con respecto a la justicia contenciosa administrativa en nuestro país:

> *"Antes de noviembre de 1950, por falta de legislación no había posibilidad de impugnar las actuaciones de la Administración Pública. No fue sino hasta el 15 de noviembre de ese año en que se dictó la primera ley (#1226) que regulaba la jurisdicción contenciosa administrativa, y por ende, la posibilidad de controlar y fiscalizar la actividad de la Administración."*[30]

Si bien hubo algunos precedentes, dignos de mención, con respecto al ordenamiento contencioso administrativo y la impugnación de conductas de la Administración, fue con la Ley de 1950 que se generó el primer *corpus* medianamente ordenado, coherente y respetuoso de algunos de los principios vectores de la justicia administrativa. Esta Ley, como es de preverse, obedeció a su vez a la disposición constitucional, producto de la Guerra Civil y posterior golpe de Estado producido en 1948, que quebrantó el orden constitucional y se cristalizó en la nueva constitución de 1949, norma que, en su artículo 49, estableció la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, cuyo texto actualmente prescribe lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 49.- Establécese la jurisdicción contencioso – administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.*
>
> *La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.*
>
> *La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados."*

30 Calvo García Jorge Iván. Régimen de nulidades en la legislación administrativa costarricense. Análisis a la luz del nuevo código procesal contencioso administrativo. Trabajo final de graduación (San José, Costa Rica: p 108). 2009. P109. .

A raíz de la disposición constitucional transcrita, se confeccionó una escueta ley dirigida a regular el nuevo proceso contencioso. Ciertamente, esta Ley de 1950 dejaba de lado muchísimos aspectos importantes para el establecimiento de un fuero contencioso administrativo y civil de Hacienda, pleno y respetuoso de los derechos que orientan la justicia administrativa eficiente y garantista. Esa Ley de 1950, es decir, la Ley 1226, estableció un pequeño espacio de exclusión de conductas administrativas, que no estarían sujetas a la recién creada revisión Jurisdiccional Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda. Lo anterior, sin ninguna mención explícita del Acto de Gobierno, aunque se debe hacer la precisión de que sí estableció que, incluso en esos escenarios de excepción, los administrados que se viesen afectados directamente por esas actuaciones tendrían derecho a que se indemnice tal daño. Lo dicho se puede ubicar en el artículo 2 mencionado, que en lo concerniente estipuló:

> *"Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, no serán materia del juicio contencioso-administrativo:*
>
> *a) Las disposiciones de carácter general que dicte la Administración Pública en ejercicio de sus facultades discrecionales, sin sujeción a leyes, reglamentos u otro precepto administrativo, a los cuales deba acomodar sus actos. Sin embargo, cabrá el recurso contra las resoluciones que se tomaren como consecuencia de una disposición de carácter general emanada de la potestad discrecional, si con ella se lesionaran derechos particulares establecidos por una ley o reglamento u otro precepto administrativo;"*

Tal y como se ha mencionado reiteradamente, esta primera regulación fue sumamente escueta, no solo en lo atinente al Acto de Gobierno sino en su totalidad. La competencia material de la nueva jurisdicción, las actuaciones revisables, entre otros temas de suma importancia, fueron regulados a lo sumo, vagamente. De lo dicho se comprende por qué no hay mención explícita del Acto de Gobierno, por la vaguedad con la que la normativa fue elaborada. Esta insuficiencia normativa con respecto a la jurisdicción contenciosa se mantuvo cuando menos hasta 1966, año en el que se promulga a Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aunque, ciertamente, no fue sino hasta 1978, con la vigencia de la Ley General de la Administración Pública, que se alcanzó cierto grado de uniformidad en el derecho público costarricense. En el ínterin, entre la

promulgación de la primera regulación de 1950, la Ley reguladora de 1966 e incluso la Ley General de 1978, hubo una enorme confusión en el derecho administrativo costarricense, dado que no existían disposiciones uniformes y herméticas, ni en lo atinente al proceso ni en las disposiciones de fondo.

> *"Anótese que, durante el período de 1950 hasta la creación de la Ley General de la Administración Pública en 1978, el desarrollo y aplicación de doctrina en derecho público se realizaba vía jurisprudencia, situación que generó mucha confusión e inseguridad jurídica. Por tal motivo, la necesidad de la Ley General de Administración Pública, que no hacía otra cosa más que normativizar las doctrinas mayoritarias y modernas de la época, que se materializaban vía jurisprudencial como ya se dijo, significando esto, en primera instancia, un enorme paso para la seguridad jurídica, al menos en algo."*[31]

De lo anterior se desprende que antes de la normativa actual, es decir, la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, hubo dos periodos de regulación procesal en este país. La ya revisada Ley de 1950 y hasta la promulgación de la Ley Reguladora de 1966 y, posteriormente, el periodo comprendido entre la Ley Reguladora y el Código Procesal Contencioso de 2008. Para efectos de esta sección no conviene detallar lo relativo a la etapa contemporánea del Acto de Gobierno en la legislación nacional, entiéndase, desde 2008 y hasta la fecha, dado que ello es objeto de análisis posterior, cuando se verifique el estado actual del instituto en el país. Ciertamente, sí resulta indispensable revisar lo acontecido desde 1950 hasta las vísperas del Código Procesal Contencioso de 2008.

Ya descrita la situación que imperó desde 1950 y hasta 1966, conviene recapitular lo relativo a la promulgación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en el año 1966, con la cual se derogó la legislación anterior, es decir, la Ley 1226 de 1950, además de modificar todas las leyes que se opusieran a ella.

> *"Esta Ley, consciente de que la jurisdicción contenciosa administrativa, no es más que una especie de la genérica función jurisdiccional, se limita a regular las que son*

[31] *Ibid.* P110.

verdaderas especialidades de los procesos que la misma conoce, remitiéndose en lo demás a las leyes comunes."[32]

La Ley Reguladora de 1966 fue un cuerpo normativo mucho más robusto, coherente y acorde con los parámetros, para entonces contemporáneos de la justicia administrativa, lo que debía ser un proceso contencioso garantista. Significó un gran paso en la tramitación de procesos de esta especialidad, sobre todo, dado que su antecesora, es decir, la legislación anterior de 1950, fue un escueto compendio de 11 artículos que apenas si abarcaba algunos de los institutos y nociones básicas del proceso contencioso. Del análisis histórico efectuado, sobre la evolución del Acto de Gobierno en Francia y España, se desprende con claridad que para 1950 ya existía en esas latitudes un concepto bastante acabado del Acto de Gobierno, que si bien no ha parado de evolucionar hasta el momento, para entonces ya estaba dotado de robustez doctrinal, normativa y jurisprudencial. En Costa Rica, empero, en 1950, tal y como se pudo ver, no hubo vestigio de mención sobre el Acto de Gobierno, no obstante, ello cambió con la promulgación de la Ley Reguladora de 1966, en donde en su artículo 4 se estableció una cláusula que, desde ya debe decirse, es prácticamente idéntica a la actualmente contemplada por el artículo 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Dicho artículo estipuló:

"Artículo 4º.- No corresponderán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

b) Las cuestiones que se susciten sobre los actos de relación entre los Poderes del Estado o con motivo de las relaciones internacionales de la República, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación sí corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Desde la promulgación de la Ley Reguladora en 1966 hasta la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la situación del Acto de Gobierno y la cláusula de exclusión en la legislación procesal, que determinaba su inimpugnabilidad, se mantuvo prácticamente incólume. El análisis del estado actual del instituto, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, en el derecho costarricense será un tema a revisar posteriormente. Por lo pronto,

[32] *Ibid.* P116.

estos dos antecedentes normativos (tanto la Ley de 1950 como la de 1966), conforman la trayectoria que tuvo tal instituto hasta nuestros días.

Capítulo 2. Aspectos generales del Acto de Gobierno

Sección Primera: Principales elementos del Acto Administrativo

El Acto Administrativo es uno de los pilares dogmáticos del Derecho Administrativo, una aproximación preliminar sería declarar que es el mecanismo de actuación de las Administraciones públicas y

> *"la más simple y tradicional definición del Derecho Administrativo lo considera como el Derecho de la Administración Pública."*[33]

De lo expuesto se colige que el Acto Administrativo sea un instituto de fundamental importancia, dentro del derecho público y, particularmente, el administrativo. Si el derecho administrativo, en palabras de García Enterría y Ramón Fernández, es el derecho de las Administraciones Públicas, la base de este sería la creación de esa ficción, precisamente la de la Administración Pública como persona jurídica. En palabras de los propios autores:

> *"Hacia mediados del siglo XIX, los esfuerzos dirigidos a garantizar la autonomía del nuevo Derecho Público, con la necesidad de abandonar las explicaciones personalistas y místicas del feudalismo y el absolutismo, cristalizan en Alemania en una aportación capital, sin duda tomada en préstamo del pandectismo iusprivatista: el reconocimiento del Estado como una persona Jurídica."*[34]

Ahora bien, García de Enterría y Ramón Fernández, así como el resto de la doctrina contemporánea más calificada, destacan que la dotación de personalidad jurídica del Estado y, más claramente, de las Administraciones Públicas, es la nota generadora del derecho administrativo y la base ficcional sobre la cual se sustenta, abandonando con ello explicaciones funcionales, de servicio público u

33 García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. España: Civitas. 1980. P21.

[34] *Ibid.* P22.

otras teorías que quisieron asentarse durante la generación de esta nueva rama del derecho, particularmente desarrolladas por las escuelas dogmáticas francesas del siglo XIX.

Tal y como se mencionó al inicio, el Acto Administrativo es, a su vez, el mecanismo que les permite a estas Administraciones Públicas manifestar su voluntad, en su condición de personas jurídicas y, por tanto, centros de imputación de responsabilidades y derechos:

> *"De la misma manera que la función legislativa se manifiesta y concreta en la elaboración de normas generales y la judicial en las sentencias, la Administración formaliza su función gestora con repercusión directa o indirecta en los intereses, derechos y libertades de los ciudadanos a través de los actos administrativos."*[35]

Es claro entonces que el Acto Administrativo tiene como primera nota diferenciadora o constitutiva el ser una manifestación de voluntad de las Administraciones Públicas.

> *"el Acto Administrativo es una declaración formalizada, distinta por esencia de la mera actuación material de la Administración y de ciertas actuaciones informales (negocios, intercambio de información, etc)."*[36]

Esta manifestación de voluntad de la Administración también tiene otras funciones muy importantes dentro del derecho administrativo, se está hablando de implicaciones ya no funcionales (que les permiten actuar a las Administraciones Públicas), sino procesales, es decir, que sirven como objeto para accionar la jurisdicción contenciosa, cuando la Administración, en ejercicio de sus potestades, pudiere infringir el bloque de juridicidad, sobre ello:

> *"Precisamente porque el Acto Administrativo concreta y mide el alcance de esa incidencia, la teoría de éste se ha construido para delimitar el objeto de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, facilitando de esta manera el control judicial de la actividad administrativa jurídicamente relevante."*[37]

De lo anterior se colige entonces que, de manera clara, otra de las notas diferenciadoras del Acto Administrativo que para este punto destacan, que aunque pudiese parecer obvia resulta de

35 Parada, R. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons. 1997. P92.

36 Sánchez Morón, M. Derecho Administrativo Parte General. España: Tecnos. 2006. P516.

[37] Parada, R. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons. 1997. P92

indispensable mención, es que está sometido al denominado imperio de las leyes, es decir, al bloque de juridicidad, el cual puede servir como baremo para su revisión jurisdiccional ante el contralor contencioso administrativo. Además de ello, se debe dejar claro que este no tiene una vocación normativa.

> *"En segundo lugar, el Acto Administrativo está sometido a Derecho administrativo, lo que lo diferencia de cualquier otra manifestación de la voluntad administrativa que se sujete a Derecho privado (un contrato de compraventa, el despido de un contrato laboral, por ejemplo).*
>
> *En tercer lugar, el Acto Administrativo no tiene carácter normativo y ésta es su diferencia sustancia con el reglamento, que ya estudiamos en su momento."*[38]

Según lo señala el propio Ramón Parada, la conceptualización más aceptada en el derecho ibero del Acto Administrativo, es la aportada por Guido Zanobini, que expuso que es:

> *"toda manifestación de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa".*[39]

Esta definición, según expuso el autor, puede ser problemática, teniendo como principal rasgo pernicioso el ser extremadamente general. Se hace una referencia a la actividad formal de la Administración, con el problema de que pareciera darse a entender que se incluyen muchas manifestaciones formales de voluntad no definitivas y, por lo tanto, no enjuiciables. Esto último encarna, precisamente, el problema que señala Ramón Parada, que destaca la importancia de determinar la enjuiciabilidad de los actos administrativos. Se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español que únicamente abroga a manifestaciones creadoras de situaciones jurídicas el carácter de Acto Administrativo, al menos ello es así con efecto de su revisión jurisdiccional, según expone el autor:

> *"Rechaza por ello que sea Acto Administrativo «cualquier otra declaración o manifestación que, aunque provenga de órganos administrativos, no sea por sí misma creadora o modificadora de situaciones jurídicas, es decir, carezca de efectos imperativos o decisorios, y así no pueden merecer el calificativo de actos impugnables los dictámenes*

[38] Sánchez Morón, M. Derecho Administrativo Parte General. España: Tecnos. 2006. P516.
[39] Parada, R. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons. 1997. P92.

e informes, manifestaciones de juicios, que siendo meros actos de trámite provienen de órganos consultivos, ni tampoco las contestaciones a las consultas de los administrados» (Sentencia de 30 de abril de 1984).[40]

Dicha enjuiciabilidad es vital para entender los Actos Administrativos dentro del contexto específico que se intenta desarrollar en la presente investigación, dado que no es objeto de análisis el Acto Administrativo en general, ni siquiera algunas clases específicas de este, sino que lo es exclusivamente el Acto de Gobierno; de allí que interese destacar únicamente lo relativo a la doctrina general del Acto Administrativo que guarde vinculación con el Acto de Gobierno, que propenda a la comprensión de este. La enjuiciabilidad de los actos de la Administración es uno de los rasgos principales que importa destacar dentro de esta doctrina y de cara al análisis del Acto de Gobierno. Si bien se mencionó que para efectos de su justiciabilidad el Acto Administrativo debe ser "final", empero, el autor aclara que:

No obstante, tratándose de manifestaciones de voluntad no es siempre necesario que el acto sea definitivo, es decir, que ponga fin a un procedimiento o impida su continuación, pues el Tribunal Supremo admite también la impugnación separada e independiente de los actos decisorios que inciden en situaciones jurídico-privadas o imponen obligaciones durante la sustanciación del procedimiento"[41]

Esta regla también tiene cabida en el derecho costarricense, en tanto el Código Procesal Contencioso Administrativo prevé la impugnación de Actos Administrativos de trámite con efecto propio, es decir, aquellos que no son actos finales, pero que aun así tienen efectos directos e inmediatos en las esferas jurídicas subjetivas de los administrados. Con estas precisiones, el autor se permite sugerir la siguiente definición de Acto Administrativo:

"Aquel dictado por una Administración Pública u otro poder público en el ejercicio de potestades administrativas y mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados, bajo el control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa."[42]

---

[40] *Ibid.* P93.
[41] *Ibidem.*
[42] *Ibid.* P95.

En cuanto al concepto de Acto Administrativo dado por Ramón Parada, a partir de las consideraciones expuestas, están presentes los elementos más importantes de este instituto, sin ser este el lugar (tal y como se mencionó *supra*) para cavilar en demasía sobre ellos de manera pormenorizada, o con un alto nivel de detalle, por ahora, baste con describirlos. Ahora bien, sobre las clasificaciones de los actos, este mismo autor expone:

> *"En cuanto a la clasificación de los actos administrativos, ha merecido doctrinalmente respuestas muy distintas. Así, hay quien la considera merecedora de un tratamiento minucioso (GARRIDO FALLA) y quien, más desdeñosamente, entiende que no tiene interés intentar agotar las distintas especies de actos en un cuadro más o menos grandioso, partiendo de las categorías pandectísticas civiles o bien ofreciendo cuadros descriptivos sobre bases psicológicas o materiales más o menos convencionales, como hace la doctrina alemana e italiana (GARCÍA DE ENTERRÍA).*[43]

La presente investigación se adhiere a la segunda posición expuesta, la sostenida por el sector de la doctrina encabezado por Eduardo García de Enterría, que estima que las clasificaciones, no pocas veces pretensiosas, sobre bases más o menos materiales, son innecesarias. Lo dicho, en el tanto solamente algunas distinciones se sostienen sobre las diferencias normativas contempladas por el ordenamiento, sobre las necesidades materiales de los administrados y las Administraciones, o sobre verdaderas diferencias sustanciales (dogmáticas) que mantienen algunos actos respecto de otros. Allende de las distinciones entre actos generales y concretos; discrecionales y reglados; por los sujetos que intervienen; simples o complejos; unilaterales y bilaterales; en razón de contenido o efecto, o cualquier otra distinción de este tipo que se podría realizar, realmente para efecto de esta investigación solamente interesa distinguir entre actos impugnables y no impugnables.

Ahora bien, de los elementos que conforman los Actos Administrativos, se debe realizar una explicación, dado que todo acto de esta naturaleza debe reunir una serie de requisitos de cuya concurrencia depende su validez y que son a su vez regulados por ley, en nuestro caso, por la Ley General de la Administración Pública.

> *"Los elementos del Acto Administrativo son los presupuestos, o bien, requisitos que darán existencia, como acto de voluntad o como conducta externa de la Administración de*

[43] *Ibidem.*

conformidad con la ley. Como se expresa en el modo clásico, todo acto de voluntad de la Administración debe obedecer a un esquema típico que exige presencia ordenada y relacionada de varios objetos necesarios para que aquella conducta se pueda estimar como plenamente exteriorizada (Ortiz, 2000, pág 311).[44]

Ahora bien, con efecto de especificar los elementos del Acto Administrativo, se debe entender que estos se clasifican en formales y materiales. Los primeros no forman parte del acto en sí, sino que orbitan en torno de éste y su conformación, revisten de formalidad la generación del mismo. Estos son el procedimiento, la forma de la manifestación del acto en cuestión, así como la competencia.

"En palabras de Ortiz, son formales los elementos que se refieren al ejercicio de la potestad que autoriza el acto para lograr la realización de éste. (Ortiz, 2000, pág 315)."[45]

El procedimiento refiere al modo de producción del Acto Administrativo concreto, la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento debe propender a asegurar el cumplimiento de los fines públicos prefijados, así como garantizar los derechos e intereses de los administrados. Este está fijado por el libro segundo de la Ley General, que en su artículo 216 establece:

"Artículo 216.-

1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquél.

2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes, circulares e instrucciones del superior jerárquico, dentro de los límites de esta Ley."

44 Calvo García Jorge Iván. Régimen de nulidades en la legislación administrativa costarricense. Análisis a la luz del nuevo código procesal contencioso administrativo. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2009. P15.

45 *Ibid.* P 16.

Ahora bien, la forma refiere precisamente al medio o formato a través del cual se debe consignar el Acto Administrativo, lo cual debe ser por escrito con arreglo a la disposición contenida en el artículo 134 de la propia Ley General:

> *"Artículo 134.-*
>
> *1. El Acto Administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa.*
> *2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho aplicable, la disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor."*

Por último, dentro de los elementos formales del Acto Administrativo, debe destacarse el de la competencia. Este elemento puede determinarse en función de variedad de criterios, establecidos a nivel normativo, así como de amplio desarrollo jurisprudencial. Pueden ser: territorio, tiempo, grado, personas, entre otros.

Por otro lado, existen dentro de los elementos que conforman el Acto Administrativo los denominados materiales, que son los que dotan de contenido el acto y condicionan este contenido en aras de realizar el fin público prefijado por ley.

> *"son los que adecuan –en palabras de Ortiz- la conducta administrativa a la necesidad que satisface y determinan lo que la Administración manda, autoriza o prohíbe. Se trata del motivo, del contenido y del fin mismo. (Ortiz, 2000, pág 315).*[46]

Estos elementos, esenciales o materiales, según la doctrina y jurisprudencia son básicamente tres. El primero de ellos es el motivo, que constriñe al acto a estar fundado en una verdad palpable o real, para decirlo de otra forma, en hechos ciertos. Remite, de manera evidente, al elenco de hechos que generan la necesaria adopción del acto. Es un presupuesto fáctico propuesto por la norma habilitante como fundamento de la adopción y, eventualmente, de la aplicación del acto en concreto. Este supuesto de hecho debe estar tipificado por la norma jurídica que corresponda.

> *"El motivo del acto es el antecedente jurídico que hace posible o necesaria la emisión del acto, de conformidad con la Ley. Permite ejercer la competencia en el caso concreto (a*

[46] *Ibid.* P16.

diferencia de la competencia que es la legitimación genérica) y su ausencia determina la imposibilidad de ese ejercicio exclusivamente en ese caso, no en los otros que puedan sobrevenir."[47]

Por su parte, el contenido:

"se suele distinguir doctrinalmente en tres formas. a) contenido esencial o necesario, es el que da nombre al acto y lo individualiza dentro de uno de los tipos regulados por el Derecho Administrativo.

(...)

b) El contenido implícito y natural es el que se da normalmente y por virtud de ley y aunque el acto nada diga al respecto, pero a condición de que el mismo no regule el caso en forma diversa.

(...)

c) El contenido accidental del acto, porque puede o no darse, según la voluntad del agente. Para que este contenido pueda darse, es necesario que sea discrecional el motivo del acto, que indica, si y cuando, este se realiza y, además que su contenido no esté regulado por la ley en términos taxativos."[48]

No menos importante, se encuentra el elemento material del Acto Administrativo denominado fin. El cual:

"Es el resultado último, de índole no jurídica (metajurídico, dice Jinesta), que persigue el acto en relación con el motivo realizado. (Ortiz, 2000, Pág. 332).

No debe confundirse el fin con el objeto, pues el último es el resultado inmediato del acto en relación con su efecto."[49]

[47] *Ibid.* P28.
[48] *Ibid.* P27.
[49] *Ibid.* P29.

Existe un sector de la doctrina que, por su porte, propone una división de los elementos del Acto Administrativo en subjetivos y objetivos. Sobre este aspecto, el tratadista español, Miguel Sánchez Morón señala que:

> *"Todo Acto Administrativo debe ser dictado por órgano competente para ello (art. 53.1 LRJPAC). La competencia es, pues, el primer elemento subjetivo del acto."*[50]

Este órgano puede ser unipersonal o colegiado, en cuyo caso debería contar con todos los requisitos normativos que determinan su composición y la debida conformación de su voluntad. También es indispensable que no concurran vicios de voluntad en los funcionarios que conformen dichos órganos.

El mismo autor determina por contracara la existencia de ciertos elementos objetivos del Acto Administrativo, derivados de la raíz normativa de estos, que en cada caso los regulan. Hay una vinculación del contenido del acto con las disposiciones normativas que lo habilitan.

> *"En este sentido podríamos hablar de un principio de tipicidad de los actos administrativos, que contrasta con la libertad de pactos propia de los negocios jurídicos bilaterales o multilaterales, reconocida también aunque con límites, en el Derecho administrativo."*[51]

Ciertamente, si bien existe un apego evidente de los Actos Administrativos a la normativa legal y reglamentaria existente, no todas las actuaciones de la Administración deben estar directamente vinculadas por la ley. Existe la posibilidad, así prevista en el ordenamiento, de que las Administraciones actúan de formas no previstas legalmente, siempre que ello propenda al beneficio de los intereses públicos imperantes, teniendo como parámetro evidente el respeto de los derechos e intereses de terceros.

> *"En consecuencia, la obligación de ajustarse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídica no significa que el contenido del acto esté siempre definido de antemano por las normas jurídicas. Así sucederá en el caso de los actos reglados, mediante los que la Administración*

[50] Sánchez Morón, M. Derecho Administrativo Parte General. España: Tecnos. 2006. P525.
[51] *Ibidem.*

se limita a comprobar la subsanación de unos hechos en el presupuesto fáctico de la norma y a aplicar la consecuencia jurídica en ella prevista."[52]

Un último tema que debe desarrollarse en relación con los Actos Administrativos es el de la eficacia de estos. Con motivo de hablar de la eficacia de los actos, se debe hablar de dos características fundamentales de estos, la ejecutividad y la ejecutoriedad. De previo a entrar de lleno en ellas, es necesario hacer mención del tema de la validez de los actos, la cual se constata con la necesaria adecuación del acto a las disposiciones normativas vigentes. Lo dicho se respalda en el artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública, que expone:

"Artículo 128.-Será válido el Acto Administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta."

Se debe agregar que dicha adecuación al ordenamiento debe darse tanto en lo relativo a los presupuestos materiales o de fondo del acto, elementos ya descritos anteriormente, así como en los elementos formales de conformación, tal y como la competencia de quien los dicta (sujeto) así como de que se siga el procedimiento adecuado. Sobre ello, el artículo 129 de la Ley General establece:

"Artículo 129.-El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia."

Por su parte, el artículo 130 de la misma Ley prevé:

"Artículo 130.-

1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento.

2. El error no será vicio del Acto Administrativo pero cuando recaiga sobre otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta ley.

[52] *Ibid.* P526.

3. El dolo y la violencia viciarán el acto únicamente cuando constituyan desviación de poder."

Del punto dos del artículo recién transcrito se desprende la consideración de que los vicios de voluntad no inciden en la validez del acto como tal, con la excepción de que aparezcan como desviación de poder o defectos en otros elementos, entonces:

> *"Por consiguiente, la validez se presume como regla general. Esta presunción de validez o legitimidad constituye un privilegio sustancial de las administraciones públicas, la cual, determina que la anulabilidad (nulidad relativa) sea la regla. La finalidad de esta presunción es velar por la continuidad, regularidad, eficacia y eficiencia de la función pública."*[53]

Entonces, de lo dicho se colige que existe una presunción de validez de los Actos Administrativos, aunque se debe entender en todo momento que dicha presunción es de naturaleza *iuris tantum*, o lo que es lo mismo, admite prueba en contrario. Se quiere decir que, pese a que el acto generado a la vida jurídica se presume válido, se puede impugnar en cualquier momento por cualquier administrado que alegue lesión de sus derechos subjetivos o intereses legítimos. El principio de ejecutividad, antes mencionado, se desprende de esta presunta validez.

> *"Las decisiones administrativas unilaterales y, típicamente, los actos administrativos, obligan a su cumplimiento puesto que son decisiones de un poder público, adoptadas por razones de interés general. De manera semejante a las disposiciones de una Ley o una sentencia judicial, el acto del Poder Ejecutivo debe ser cumplido por todos, por la propia Administración que lo dicta, pero también por los ciudadanos a los que va dirigido."*[54]

Una vez comunicado formalmente el acto, requisito para su eficacia, nace de inmediato una obligación sobre aquellos a quienes está dirigido cumplir con lo dispuesto por este, así como una concomitante capacidad de la Administración para exigir su cumplimiento. Esta potestad de exigir su cumplimiento no es exactamente lo mismo que ejecutar forzosamente el acto, diferenciación que marca la pauta con la característica de ejecutoriedad. Dicha ejecutividad es una cualidad sustancial del Acto Administrativo, que a la vez explica el carácter obligatorio del Acto

[53] Calvo García Jorge Iván. Régimen de nulidades en la legislación administrativa costarricense. Análisis a la luz del nuevo código procesal contencioso administrativo. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2009. P42.

[54] Sánchez Morón, M. Derecho Administrativo Parte General. España: Tecnos. 2006. P531.

Administrativo, en tanto que en el ejercicio de potestades de imperio la Administración puede exigir el cumplimiento de actos válidos o presuntamente válidos.

Ahora bien, de cara a determinar la segunda característica mencionada, es decir, la ejecutoriedad de los actos administrativos, se debe recordar que la Administración tiene potestades de imperio, que le han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico. A raíz de dichas potestades, encomendadas a su vez para el cumplimiento de ciertos fines públicos determinados, se abroga ciertas prerrogativas cuya nota diferenciadora es ser exorbitantes, en comparación con las posibilidades con las que cuentan los administrados. Para hacer cumplir actos administrativos válidos y eficaces, la Administración puede desempeñar la ejecución forzosa de los mismos, aún en contra de la voluntad de los administrados. El artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública prevé esa posibilidad, en tanto expone:

> *"Artículo 146.-*
>
> *1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar.*
>
> *2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las otras responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía.*
>
> *3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.*
>
> *4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de poder."*

Sobre este concepto, la doctrina más autorizada ha expuesto:

> *"Los actos administrativos no son sólo ejecutivos, es decir, de obligado cumplimiento, sino que están dotados también de ejecutoriedad, lo que significa en realidad (aunque la LRJPAC confunde los conceptos), que pueden ser ejecutados forzosamente por la propia Administración en caso de que no se cumplan voluntariamente por sus destinatarios. Los actos administrativos son un título de ejecución forzosa, al igual que las sentencias judiciales, privilegio del que carecen (normalmente) los títulos o documentos de carácter*

privado y que se reserva a las decisiones de los Poderes Públicos, para la prosecución eficaz de los intereses públicos a los que sirven."[55]

Con esto se notan las características de la eficacia de los Actos Administrativos, a partir de cuya presunción de validez se disgregan las características de ejecutividad y ejecutoriedad en los términos descritos y que revisten a este instituto de una fuerza particular, exorbitante, se podría decir.

[55] *Ibid.* P539.

Sección Segunda: Conceptos fundamentales relacionados con el Acto de Gobierno

El entender los elementos generales del Acto Administrativo, desarrollados en la sección anterior, resulta indispensable para comprender el instituto del Acto de Gobierno, por existir una clara relación de género-especie entre ambos constructos. Ciertamente, ello no basta para comprender el Acto de Gobierno con todas sus particularidades, dado que este instituto contiene algunos elementos no solamente específicos sino únicos, dentro de la inmensa variedad de Actos Administrativos existentes en la actividad formal de la Administración Pública. Es así que los elementos que componen el Acto Administrativo se manifiestan de una manera particular en el Acto de Gobierno, así como nuevos factores cobran una particular relevancia.

El lugar en la doctrina, jurisprudencia y normativa contemporánea que ocupa el Acto de Gobierno será objeto de desarrollos ulteriores, para este punto se tratarán esos elementos de manera introductoria, para otorgar con eso un panorama de la forma en que se manifiestan los principales elementos del Acto Administrativo dentro del Acto de Gobierno. Lo que se pretende establecer es que en el presente acápite se desarrollarán los conceptos que aproximan a la concepción clásica del Acto de Gobierno, en otras palabras, los puntos que han caracterizado el instituto a través de la historia, de manera más o menos generalizada.

De arranque, el concepto de gobernanza es fundamental de dilucidar. Fernando Garrido Falla, en su "Tratado de Derecho Administrativo"[56] (1976), efectuó una puntualización sumamente importante en torno al acto político. Expuso la necesidad de adentrarse en el concepto de gobernanza, previo a siquiera intentar el establecimiento de un concepto sólido de Acto de Gobierno. Tal necesidad se justifica a partir de que el autor aseveró que, si no se puede entender las implicaciones de gobernar, es decir, los alcances y el significado de tal término, no se puede, por consiguiente, entender el Acto de Gobierno.

Sostuvo este autor que existe una denominada función política y de Gobierno, que es la matriz del acto político, expuso que tal función encarna un momento de la actividad estatal, que antecede el encasillamiento en poderes (división tripartita post Revolución francesa). Esta función se distancia

56 Garrido, F. Tratado de Derecho Administrativo, volumen I. Madrid, España: Instituto de Estudios Públicos. 1976

de la típica función administrativa, dentro de la que se configuran prácticamente la totalidad de los Actos Administrativos, de la actividad formal de la Administración. Describió que tal función se constituye en un momento previo a tal división de las funciones por otros criterios.

La llamada función de Gobierno es, entonces, un elemento cuya dilucidación resulta indispensable de cara al estudio del Acto de Gobierno, tal función consta, en su aspecto primigenio, del ejercicio de la gobernanza por parte de un sujeto específico (el Estado, en este caso, dada la imposibilidad de las demás Administraciones de dictar actos de Gobierno). Sobre ese tanto, Roberto Dromi, en su *"Tratado de Derecho Administrativo"*, propuso una estructura propedéutica para analizar las diferentes funciones estatales, así como para diferenciarlas entre sí:

> *"La diferencia específica de las funciones del poder, por las que se canaliza y exterioriza el ejercicio del mismo, se logra teniendo en cuenta aspectos "sustantivos", "orgánicos" y "procesales" a saber: - Aspectos sustantivos (qué), por los que se define la "naturaleza" o "contenido esencial" de la actividad pública comprendida en la función del poder de que se trate. - Aspectos orgánicos (quién), por los que se determina el "sujeto" u "órgano" que cumple la función. Interesa la individualización del "sujeto orgánico", fundamentalmente en la conceptualización de la jurisdicción y de la legislación, que son funciones cuyo ejercicio corresponde monopólicamente al Estado. - Aspectos procesales (cómo), por los que se especifican el "continente" o "modo" de preparación (procedimientos) y exteriorización (actos). Comprende los procedimientos de formación (legislativos, judiciales y administrativos) y manifestación (ley, sentencia, decreto) de los actos del poder"*[57]

Como se adelantó, esta es una estructura propedéutica, tendiente a garantizar los mecanismos a partir de los cuales se puede analizar una función específica de la Administración Pública, en este caso, del Estado, para determinar una caracterización más o menos uniforme que la explica y que se pueda, con ello, adscribir a una categoría conceptual específica. El autor no se queda allí, sino

[57] Dromi, Roberto. *Tratado de Derecho Administrativo*. Argentina: Ediciones Ciudad Argentina. 1998. P101

que analiza cada una de las funciones estatales a partir de los parámetros ofrecidos, sobre lo cual expuso:

> *"Aspecto sustancial. La función gubernativa o política es la actividad estatal discrecional sin límites jurídicos. Es realizada en ejecución de una directa atribución constitucional por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia, fundados en razones de seguridad, orden y defensa de la propia comunidad política (art. 99, inc. 1, CN). Consiste, precisamente, en fijar las grandes directrices de la orientación política, mediante la gestión de asuntos que afectan los intereses vitales de la comunidad, respecto de su seguridad interna, relaciones internacionales y relaciones interorgánicas o entre poderes. Dentro de la actividad de los órganos legislativo y ejecutivo hay actos superiores de dirección e iniciativa que reflejan una especial y primordial intensidad del poder estatal. Integran una función gubernativa que es distinta de la función administrativa, por cuanto ésta supone actos subordinados o derivados, de mediatez constitucional. En cambio, la función gubernativa tiene directa inmediatez constitucional, con rango supremo de jerarquía. Es decir que no tiene, en principio, legislación intermedia."*[58]

De acá se pueden entrever diferencias varias con la función administrativa, parangón inevitable de cara a determinar cualquier función realizada por el Ejecutivo, en tanto esta representa su labor más habitual y frecuente. Se parte de que es una atribución otorgada directamente por la constitución, lo cual se deslinda de la legalidad que rige la función administrativa, en tanto son normas de este rango las que generalmente la habilitan. Adicional, tal vez el principal aporte es el indicar que está estrechamente vinculada con potestades vitales para la organización más elemental del Estado, como son las decisiones vinculadas con la interacción de los poderes políticos, la seguridad nacional o la orientación político-filosófica del Estado en cuestión. También se puede analizar desde el nivel organizativo del Estado, en tanto:

> *"Aspecto orgánico. La función gubernativa no requiere de un órgano específico de realización. Puede ser ejecutada tanto por el ejecutivo como por el legislativo. Es competencia exclusiva de ellos o concurrente entre la voluntad de ambos órganos, según los casos. Pero, desde el punto de vista orgánico, es una actividad indelegable, que está*

[58] *Ibid.* P 102.

vedada en todos los supuestos al órgano jurisdiccional. Sin embargo, adquiere su verdadero carácter en el ámbito y actuación del órgano ejecutivo, típicamente gubernativo. El Poder Ejecutivo no se limita a la administración, sino que tiene la máxima responsabilidad en la dirección superior del desarrollo nacional, determinando los objetivos políticos y las estrategias."[59]

Este desarrollo, efectuado por Roberto Dromi, encuentra sus bases en la normativa (particularmente constitucional) vigente en su país (Argentina), en el caso costarricense podría ser cuestionable la emisión de un Acto de Gobierno por un órgano estatal diferente del Ejecutivo, aunque ello será motivo de examen posterior en esta investigación. Por lo pronto, conviene destacar que en el aspecto orgánico del Acto de Gobierno se vislumbran los elementos subjetivos del acto, es decir, quién es competente por delegación normativa para la emisión válida de tales manifestaciones formales de voluntad. También es importante destacar, de cara al examen de los elementos del Acto Administrativo descritos en la sección anterior, que en el aspecto sustancial mencionado *supra*, se reflejan los elementos del contenido y motivo del Acto de Gobierno. Ahora bien, en cuanto a los elementos formales del acto, es decir, el procedimiento y la forma mediante la cual éste puede manifestarse, el autor expone:

"Aspecto procesal. La función gubernativa se exterioriza a través de una de las modalidades de actos del poder: "actos políticos", " de gobierno" o "institucionales". Estos actos sólo pueden emitirse en los casos constitucionales, expresa o razonablemente conferidos a los órganos estatales de legislación y ejecución y dictarse con efectos jurídicos generales. Todo Acto de Gobierno, político o institucional, trasunta una directiva de carácter superior vinculada a la propia organización y subsistencia del Estado. Los derechos de los administrados podrán verse afectados directa e inmediatamente a raíz de actos emitidos a consecuencia de los actos políticos, de gobierno o institucionales, y en estos casos cabe la impugnación judicial contra tales actos de aplicación."[60]

Destaca el autor que los actos políticos siempre tienen que estar previstos de una habilitación constitucional para su disposición. Así como deja entrever que la inimpugnabilidad que se ha destacado desde su origen, como la característica fundante de estos actos políticos o de Gobierno,

[59] *Ibidem.*
[60] *Ibid.* P103.

está en entredicho en la medida en que afecte derechos subjetivos (o intereses legítimos, podría adelantarse desde ya) de los administrados.

El concepto de función política y sus diferencias con la función típicamente administrativa, así como sus implicaciones y los mecanismos doctrinarios disponibles para diferenciarlas son algunos conceptos sumamente relevantes, en relación con el Acto de Gobierno y la comprensión de este dentro de la actividad formal de la Administración Pública. Ahora bien, lo dicho encuadra planteado frente a la división tripartita materializada por los Estados post Revolución francesa, a partir de los postulados de Montesquieu y otros pensadores; lo cierto es que una democracia no solamente está compuesta por esta separación de poderes como pilar de origen al Estado Social de Derecho.

> *"También es pertinente tener presente el auge y desarrollo de la teoría de las "diferentes formas de autonomías funcionales" que existen dentro del Estado, obra de Georg Jellinek, la cual juega un rol crucial para entender a la sociedad política actual. Esta teoría postula que entre los roles o actividades que encuadran a la función gubernativa, propiamente tal, se destacan dos grupos. Por un lado, existen: a) Las funciones del Estado propiamente tales, las cuales tienen por objeto la satisfacción de los objetivos más elevados de la sociedad civil mientras que, por otro lado, existen las denominadas b) Funciones del poder, como medio para alcanzar los objetivos de aquellas funciones estatales."*[61]

Lo que se quiere dar a entender es que el Estado tiene un cúmulo de funciones que le han sido encomendadas por quienes ostentan la soberanía y, por tanto, están en capacidad de abrogar poder a un tercero mediante el empleo de la democracia representativa. Estas funciones, que le han sido encomendadas al Estado, se encuentran previstas en el orden constitucional vigente, además, la forma en la que estas estarán divididas y se relacionarán entre sí también está prevista a nivel constitucional. Se habla de las típica división tripartita de poderes, aunque ya se dejó claro que no solamente se reduce a ello el amplio margen de funciones estatales. Para materializar estas funciones, conseguir su realización y, con ello, el cumplimiento de fines públicos fijados y el desempeño de las potestades y deberes del Estado, existen funciones específicas, palpables y materiales, que no son sino mecanismos a través de los cuales el Estado como persona, a través de

[61] Garay Sims Mariana y Castro Fuenzalida Boris. Los actos de gobierno/políticos y su control jurisdiccional en el Derecho Público Chileno. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Chile. 2018. P 33.

quienes acuñan sus manifestaciones de voluntad (funcionarios), concreta la realización de tales o cuales labores concretas, tendientes a cumplir con las funciones que le han sido encomendadas. El Acto de Gobierno, en la doctrina de los autores de cita, es uno de estos mecanismos, a través de los cuales se materializa la denominada función gubernativa.

> *"De esta forma, las funciones del estado son un fin en sí mismo mientras que, las funciones del poder son el medio para alcanzar dicho fin. Por ello creemos que esas funciones del poder, como medio para lograr lo socialmente deseado, son el fundamento por medio del cual cobra existencia la teoría del acto político como medio para la consecución de un fin en sí mismo. Las funciones estatales, se diferencian de las funciones de poder, por ser aquellas que "conforman una categoría única de prestaciones y actividades públicas para alcanzar el fin de la comunidad política: el bien común". De esta forma, aquellas actividades que tengan por objeto traducir aquella imperativa necesidad de ejecutar funciones mediante las cuales la sociedad busque materializar los fines inherentes a ella, entre las cuales podemos destacar la de asegurar la paz, el orden social, fomentar la prosperidad, fortalecer la seguridad, socializar las oportunidades y proteger a la justicia, son funciones estatales o actividades inherentes al Estado."*[62]

Las funciones estatales, en el primer sentido descrito supra, tal y como se dijo son fines en sí mismo, los cuales trazan el marco general de las aspiraciones a las que debe estar encaminada la Administración Pública. Ahora bien, la actuación formal de la administración, así como otros mecanismos, son los que estarían encargados de materializar tal función:

> *"En consecuencia, todos los objetivos que trascienden a la práctica estatal han de ser fruto de una serie de mecanismos, medios o actos los cuales han de tener la particularidad de ser una especial técnica para la concreción de dichas aspiraciones. Hablamos en particular de las funciones del poder, las cuales podemos identificarlas por ser "aquellas clases de medios los cuales goza la comunidad para alcanzar sus fines socialmente deseables". Es por ello por lo que las funciones del poder se identifican con todos aquellos instrumentos que detenta la actividad estatal, traduciendo aquella actuación de poder (como mandato supremo de la comunidad al soberano) de carácter jurídico-formal -como*

[62] *Ibid.* P 34.

las vías de actuación, ya sean, gubernativa, legislativa, judicial o administrativa-, a hechos materiales, por cuyo conducto los representantes logran los fines estatales que se le asignan por el hecho de detentar el cargo. Creemos que dentro de esta especial categoría se encuentran los actos de gobierno o actos políticos, diferenciándose éstos últimos por ser ejercidos por órganos distintos al Poder Ejecutivo."[63]

Lo que se viene relatando genera un marco teórico indispensable para entender los alcances del Acto de Gobierno, en tanto este es un mecanismo puesto a disposición de materializar los fines y deberes inherentes a la función gubernativa del Estado, que en el derecho positivo está plasmado de una manera más clara en nuestro país, lo cual se verificará más adelante. En todo caso, la particularidad expuesta se podría entender como el hecho de determinar Actos de Gobierno, por parte del Ejecutivo o en algunos casos el Legislativo, en ejercicio de una facultad discrecional que le ha sido encomendada por la propia Constitución.

"En lo que nos atañe, nos limitamos al estudio de la función gubernativa, la cual sí es apreciada desde la práctica diaria podemos apreciar que se manifiesta a través de una innumerable serie de actos, dentro de los cuales se encuentran los actos políticos que tanto nos preocupan (aunque su materialización sea por medio de los decretos supremos al igual que los actos administrativos, o por medio de instrucciones, circulares u ordenanzas propias de cada órgano).[64]

Se logra entonces una enunciación del Acto de Gobierno, de sus elementos materiales y formales en tanto Acto Administrativo y se evidencia la forma específica en la que se presentan estos elementos en la emisión de un Acto de Gobierno. Es entonces el Acto de Gobierno, para una importante sección de la doctrina, una manifestación formal de la potestad gubernativa descrita, por lo cual resulta vital entender el marco conceptual y teórico que delinea dicha función, así como la forma en que esta determina el Acto de Gobierno. Más allá de la utilidad de postular una cuarta función denominada gubernativa en el derecho contemporáneo (punto que se examinará adelante), lo cierto es que un gran sector doctrinal encuadra dentro de esta al Acto de Gobierno, razón de más para verificar, aunque sea de manera sucinta, sus principales puntos.

[63] *Ibidem.*
[64] *Ibid.* P35.

Sección Tercera: Características principales del Acto de Gobierno

Del análisis, ciertamente introductorio, que se ha venido haciendo hasta este punto del Acto de Gobierno, se pueden ya entrever muchas notas características específicas de este instituto, en cuanto a su desarrollo doctrinario y normativo. Habiéndose ya hablado de los elementos del Acto Administrativo y efectuado algún desarrollo de cómo estos se materializan en el Acto de Gobierno, en tanto plasmación de la función gubernativa, resulta importante describir algunas características principales del instituto que para este momento destacan:

> *"Los actos políticos, de gobierno o institucionales, presentan las siguientes características: Ejecutan directamente una norma constitucional. - Son dictados en ejercicio de una actividad discrecional, indelegable, de los órganos ejecutivo y/o legislativo, sin límites jurídicos y por motivo de oportunidad o mérito. - Se vinculan a la propia "organización y subsistencia del Estado", y se justifican por una finalidad política vital para la seguridad, defensa y orden del Estado. No se trata de asuntos atinentes a la simple marcha de la buena administración. - En principio, no inciden directa ni inmediatamente en la esfera jurídica del administrado, "cuyo status no se altera ante la emisión del acto político, de gobierno o institucional". - Son unilaterales en su estructura y de alcance o efecto general. - Son irrevisibles, no judiciables, no justiciables o no invalidables judicialmente. Están exentos de control jurisdiccional."*[65]

Esta enumeración de características, elaborada por Roberto Dromi, ilustra de forma sustanciosa el entorno del Acto de Gobierno y sus rasgos más distintivos. Prácticamente la totalidad de las características destacables del instituto se incluyen en este desarrollo efectuado por el autor. Conviene profundizar con algún grado de detalle en varias o todas estas características, para poder con ello comprender de una manera más integral, los alcances e implicaciones del acto político.

Una de las características que destacan es la unilateralidad del acto político, sobre ello:

> *"En su estructura el acto de gobierno o político es exclusivamente unilateral, es decir, su formación o nacimiento sólo depende de la voluntad del constituyente, esto se explica*

[65] Dromi, Roberto. *Tratado de Derecho Administrativo*. Argentina: Ediciones Ciudad Argentina. 1998. P103.

dadas las finalidades que se le asignan a este tipo de actos. No hay pues, actos de gobierno o políticos "bilaterales".[66]

Una precisión que se debe hacer sobre esta característica es que, si bien en prácticamente la totalidad de los casos el acto se dicta de oficio por el propio Poder Ejecutivo, existen escenarios específicos, donde la emisión puede darse a instancia de un administrado, como podría ser el ejemplo de un indulto, empero, ello no altera el carácter unilateral de la disposición.

El sujeto, como elemento del Acto de Gobierno, también cuenta con particularidades específicas, que se desprenden de la función a la que responde el Acto de Gobierno como manifestación formal de voluntad de la Administración:

> *"El llamado acto de "gobierno" o "político" sólo puede ser emitido por el órgano jerarca –Presidente de la República o Gobernador de Provincia-, y no por los órganos inferiores, pues éstos "administran" pero no "gobiernan", esa diversa "competencia" para emitir actos políticos o de gobierno y actos administrativos, no implica un rasgo que caracterice un "régimen jurídico", sino una mera modalidad como la que, incluso, puede existir respecto a ciertos actos administrativos, ya que, según de qué Acto Administrativo se trate, así será la "competencia" necesaria para emitirlo."*[67]

Posteriormente se discutirá la posibilidad de que órganos diferentes al Ejecutivo puedan emitir actos de este tipo, lo cual podría ser el caso de algún sector de la doctrina, e incluso de la jurisprudencia, del Legislativo. En cuanto a su justiciabilidad, que es la nota más distintiva del Acto de Gobierno como instituto, Eduardo Ortiz destaca un sometimiento exclusivo a la Constitución, marcando la pauta con el resto de la vasta tipología de Actos Administrativos existentes en el Derecho Público costarricense:

> *"El Acto de Gobierno es, como se explicará, el acto constitucional, en cuanto sometido únicamente a la Constitución y no a la ley. Esto significa que la determinación del Acto de Gobierno por el ordenamiento es más vaga e imprecisa que la del Acto Administrativo."*[68]

---

[66] Garay Sims Mariana y Castro Fuenzalida Boris. Los actos de gobierno/políticos y su control jurisdiccional en el Derecho Público Chileno. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Chile. 2018. P 27.
[67] Marienhoff, Miguel. Tratado de derecho administrativo Tomo II. Argentina: Abeledo-Perrot. 1981. P698.
[68] Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo I. Costa Rica: Stradtmann. 1998. P 50.

Esta afirmación debe ser atemperada, dejando desde ya por sentado que ese entendimiento es lo que Ortiz consideró debía ser al Acto de Gobierno, entendido como acto constitucional. En la presente investigación se afirmará que también existen parámetros legales, particularmente relacionados con el principio de acceso a la justicia y reparación integral del daño, cuyo desarrollo primordial en la normativa costarricense tiene lugar precisamente a nivel legal y son de directa aplicación a todo Acto Administrativo sin excepción. Detalla Ortiz Ortiz otra singularidad del Acto de Gobierno, en tanto en este impera el principio, denominado por el autor como de regulación mínima, atendiendo a la función a la que sirve, es decir, la gubernativa:

> *"Mientras en éste rige el principio de regulación mínima (del sujeto, del fin y del motivo o del contenido) en aquél es posible que el fin no esté determinado o lo esté en forma imprecisa. Puede afirmarse que la Administración puede actuar en materia de gobierno con igual libertad que el particular respecto de los fines a perseguir, porque le está permitido cualquiera a condición de que no sea un fin privado del funcionario."*[69]

Con lo dicho se puede ver que el Acto de Gobierno usualmente está vinculado con las condiciones mismas de existencia del Estado, en tanto propende a mantener la unidad de acción y de poder, de allí que el fin al cual se adscriba un acto específico no debe estar necesariamente determinado por la Ley, por cuanto la función gubernativa trae implícita consigo una cierta impredecibilidad con la cual el Estado debe lidiar, para mantener algunos fines generales, amplios pero de indispensable mantenimiento para el funcionamiento de todo el constructo de la Administración Pública. Por estar destinado a mantener la cohesión, e incluso los requisitos funcionales más básicos del Estado, el Acto de Gobierno cuenta con estos márgenes adicionales, no presentes en la mayoría del accionar formal de la Administración.

> *"Por regla general, es Acto de Gobierno o bien el que tiende a conservar la existencia del Estado y de sus elementos, o bien el que tiene por meta mantener su funcionamiento al más alto nivel institucional, fijándole programas y fines generales, regulando las relaciones entre los supremos poderes y entre el Estado y otros estados: la planificación central de las funciones, las relaciones internacionales, la defensa del Gobierno y de su integridad (estado de sitio, de defensa nacional, la guerra internacional), la policía interna necesaria*

[69] *Ibid.* P50.

para evitar daños irreparables a la comunidad, etc., son ejemplos clásicos del Acto de Gobierno."[70]

El autor ejemplifica algunos de los casos de Acto de Gobierno, en los cuales se manifiestan las características que está describiendo. Primero, tal y como se pudo ver, se habla de una habilitación normativa especial que debe concurrir para estos casos, así como de cara a su sometimiento al contralor judicial (habilitación y sometimiento de rango constitucional). También relata el comportamiento del fin público al que debe estar adscrito el Acto de Gobierno, el cual encuentra una relativización en tanto a su necesaria habilitación legal, en caso del resto de Actos Administrativos. Finalmente, una característica notable que destaca este autor es el tratamiento que merece el principio de legalidad, acuñado en los artículos 11 de la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, en relación con el Acto de Gobierno, en lo consecuente, el autor explica que:

"El principio de legalidad es también en este caso imperativo de una regulación mínima, que contemple el sujeto (órgano) y el motivo o el contenido del acto, siempre a condición de que no sea la ley sino la Constitución la fuente de dicho régimen. Puede estar regulado también el fin y normalmente lo está; y el fin puede ser, como normalmente lo es, uno de aquellos supremos intereses del Estado o de la comunidad. Pero puede faltar esa regulación y, sin embargo, es un Acto de Gobierno, en cuanto regulado únicamente por la Constitución."[71]

[70] *Ibid.* P 50.
[71] *Ibid.* P51.

Capítulo 3. Teoría Contemporánea del Acto de Gobierno

Sección Primera: Situación actual del Acto de Gobierno en derecho comparado (España)

Para este punto ya se han desarrollado varios de los elementos que resultan de importante comprensión de cara a entender el Acto de Gobierno o político. Comenzando por su formación y bagaje histórico, a partir de la Francia post revolucionaria en el siglo XIX, así como su desarrollo en el derecho español, que finalmente acabaría en su introducción al derecho costarricense durante el siglo XX. Así también, algunos elementos propios de la teoría del Acto Administrativo fueron desarrollados, en aras de ser usados posteriormente como parámetros para analizar específicamente el Acto de Gobierno, así como el funcionamiento de estos elementos dentro del instituto en cuestión. Ahora bien, ese desarrollo (si se quiere, introductorio) sobre el instituto jurídico que nos ocupa, permite para este punto analizar el Acto de Gobierno en su composición contemporánea, a nivel doctrinal, empero, sobre todo, a nivel normativo, en un ordenamiento jurídico como lo es el español.

Para este punto conviene preguntarse: ¿por qué España? Debe remitirse a las mismas razones expuestas en el capítulo primero, sección segunda de la presente investigación, en donde se justificó la relevancia del derecho público español para el costarricense, a la vez que se detallaron con amplitud las razones que sustentan dicha importancia y el vínculo existente entre ambos. En el análisis de la evolución histórica del instituto del Acto de Gobierno, que se hizo previamente en la sección segunda del primer capítulo de esta investigación, se arribó a la discusión que generó la LJCA de 1956. A raíz de este cuerpo normativo, que vino a regular de una manera más o menos sistemática los parámetros de la justicia administrativa en ese país, se generó una discusión en torno al Acto de Gobierno que, tal y como se describió previamente, hacía chocar dos sectores de la doctrina: uno, encabezado por Eduardo García de Enterría, que vio el Acto de Gobierno como un vestigio monárquico y de una potestad absoluta, en tanto irrevisable, lo que lo convertía en un instituto odioso de los parámetros garantistas del derecho público contemporáneo de su época; otro promovido por múltiples autores, que aseguraron la necesidad del Acto de Gobierno, para con ello

permitirle al Estado cumplir algunas de sus funciones más importantes, relacionadas con la función gubernativa. En esa disyuntiva se fraguaron las primeras décadas de la nueva legislación de 1956.

Teniendo la Ley de 1956 como punto de partida, en España tuvo lugar un desarrollo jurisprudencial tendiente a garantizar el control de legalidad sobre todos los Actos Administrativos o actuaciones materiales de la Administración Pública, a partir de los planteamientos doctrinales mencionados, que tendieron a esta perspectiva garantista del derecho público. Las posiciones que propendían a eliminar la irrecurribilidad de ciertos actos de la Administración y que, como se mencionó, fueron encabezadas por García Enterría, prosperaron en tanto encontraron asidero en la jurisprudencia de la segunda mitad del siglo XX:

> *"Los planteamientos doctrinales y el progresivo convencimiento del TS en sus posibilidades de control de la legalidad de todas las decisiones gubernativas y la efectividad de la tutela judicial llevará a la sala tercera a profundizar en la idea del control de esos actos, ofreciendo un entendimiento severamente limitado de las exclusiones ex art. 2.b). La reconsideración o el giro en su doctrina no conllevará la eliminación de la categoría, ni la admisión de la inutilidad de la misma, salvo que por ello se entienda que rechaza la existencia de actos políticos o de contenido político insusceptibles de control judicial."*[72]

El Acto de Gobierno, que ya se venía tambaleando desde la segunda mitad del siglo XX, dio al traste durante los años noventa con novedosas doctrinas garantistas de la justicia administrativa en España, los sectores tendientes al control plenario del accionar de la Administración ganaban terreno, en detrimento del concepto tradicional de Acto de Gobierno, que encarnaba uno de los principales vestigios del absolutismo, que para entonces y hasta hace muy poco tenía vigencia en España. Se debe ser claros en que no se eliminó el instituto a nivel normativo, no obstante, se delineó jurisprudencialmente el contenido del mismo, por parte de los tribunales superiores de justicia en la materia.

> *"Especial trascendencia tendrá, al respecto, la STS de 22 de enero de 1993, a. 457 (recurso contra denegación por el Gobierno de referéndum municipal), al reconocer que nuestro*

72 Díez Sánchez, J. R. El Control Jurisdiccional de los actos del gobierno y de los consejos de gobierno. Revista Jurídica de Castilla y León. N.° 26. Pp 45-76. P 57.

ordenamiento sigue acogiendo después de la constitución la existencia del acto político prevista en aquel precepto como la jurisprudencia ha reconocido (cita STS de 2 de octubre de 1987 y 25 de octubre de 1990), para advertir de inmediato que la más moderna corriente jurisprudencial y señaladamente el auto del Pleno de la sala de 15 de enero de 1993 ha dado de los actos políticos una interpretación distinta, ya que tras aprobarse la constitución, y en especial teniendo en cuenta lo previsto en los arts. 9.1 y 24, no puede admitirse en nuestro derecho que existan actos de los poderes públicos no sometidos al ordenamiento jurídico y en consecuencia actos de los mismos exentos del control judicial, lo que implica que la doctrina del acto político no pueda ser invocada como fundamento de la inadmisibilidad. Cierto que en el caso no se trataba de una relación institucional, que sí lo era el recurso que resuelve el ATS de 31 de mayo de 1993, a. 4001 (frente al real decreto sobre disolución de las cortes Generales y convocatoria de elecciones), donde ya se pone de manifiesto que la sala sí tiene atribuido el control de la potestad reglamentaria. Poco después la STS de 17 de junio de 1994 pondría de relieve la necesidad de hacer efectivo el principio de legalidad cualquiera que sea la naturaleza objetiva del acto realizado por el Gobierno.[73]

Como se puede notar, empieza a vislumbrarse en la jurisprudencia española ya entrada la década del noventa del siglo anterior, una prevalencia de los principios generales del derecho, entendidos como doctrinas que informan la correcta aplicación de la justicia administrativa. Posteriormente, en esta investigación se procederá a examinar, de manera pormenorizada, la aplicación de dichos principios, para lo cual se estudiarán a fondo sus alcances e implicaciones, así como su dinámica en conjunto con la normativa, la doctrina y la jurisprudencia pertinente. Por ahora, conviene retener la idea de que dichos principios generales, como lo sería el de legalidad, se posicionan como las bases que informan al contralor de legalidad, las cuales son de infranqueable consideración, al momento en que se realice dicho control jurisdiccional sobre el accionar de la Administración.

Un cambio determinante que se empezó a asentar con los fallos mencionados es que el instituto del Acto de Gobierno ya no puede representar una cláusula directa de inadmisibilidad, de cualquier acción judicial que pudiese ir encaminada a cuestionar uno de estos actos. Pese a todo lo expuesto, con lo que se da un vaciamiento de su contenido original, se afirma que persiste la existencia de

[73] *Ibid.* P58.

este a nivel normativo, por lo que tanto la doctrina como principalmente la jurisprudencia deben seguir lidiando con este instituto ciertamente problemático. Hacia finales de la década del noventa se profundizó aún más el desarrollo sobre ello.

> *"Estas decisiones serán las precursoras de las decisivas sentencias (13) de 28 de junio de 1994 (asunto Fiscal General del estado) y de las tres sentencias de 4 de abril de 1997 (asunto papeles del CESID), objeto de múltiples trabajos y valoraciones doctrinales sobradamente conocidos, entre ellos las que en detalle llevamos a cabo en otro momento. Baste ahora señalar que todas ellas vendrán a subrayar que incluso los actos expresión del mayor grado de discrecionalidad y oportunidad son susceptibles de fiscalización jurisdiccional por esta sala en aquellos de sus elementos que estén definidos legislativamente y tengan carácter reglado. En el primer caso, «los conceptos judicialmente asequibles guardaban relación directa con conceptos definidos legalmente, en concreto con la exigencia del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal» (art. 29.1). Era este último requisito objetivo impuesto por el legislador y descrito utilizando un lenguaje netamente jurídico-administrativo, lo que permite que la jurisdicción pueda valorar su concurrencia y, en consecuencia, someta a revisión sus elementos reglados, incluido el fin."*[74]

El control, cada vez más intenso, sobre los actos de las Administraciones Públicas se asentó entonces como la postura de cabecera. Mediante estas sentencias, los tribunales superiores españoles trataron de introducir elementos de control sobre los Actos de Gobierno, aplicando una integración hermética del ordenamiento, donde los principios generales del derecho administrativo jugaron un papel sumamente importante. La tutela judicial efectiva se utilizó como un bastión para contrariar los caracteres absolutistas que el Acto de Gobierno presenta.

> *"Con esos mismos criterios, asumirá en las otras sentencias el control de las decisiones del consejo de Ministros ejerciendo potestades de dirección política en relación con la «seguridad y defensa del Estado», en los casos que «el legislador haya definido mediante conceptos judiciales asequibles los límites o requisitos a los que deben someterse dichos actos», y el examen de la ponderación efectuada por dicho órgano en relación con los*

[74] *Ibid.* P59.

derechos e intereses constitucionales en conflicto, que considerará incorrecto, al dar prevalencia al derecho fundamental a la tutela judicial."[75]

Entonces la imposibilidad de recurrir ciertos actos de la administración, o al menos, la práctica de utilizar la figura del acto político como excusa de inadmisibilidad *ad portas*, de cara al planteamiento de acciones contra actos dictados por la Administración, se vio seriamente afectada por multiplicidad de decisiones de los más importantes estrados judiciales, que durante la década de 1990 tendieron a la dirección opuesta.

> *"Decisiones judiciales posteriores, aún bajo la vigencia de la LJCA 1956, confirmarán: por un lado, la fiscalización de actos políticos hasta ese momento inmunes al control judicial (SSTS de 15 de julio de 1997 y de 3 de diciembre de 1998), como el decreto del Presidente de la junta de Andalucía sobre convocatoria de elecciones al Parlamento andaluz, rechazando la inadmisibilidad del recurso por el tribunal a quo basada en la consideración de que se trataba de un acto político infiscalizable; pero, de otra, asimismo, la inadmisión en caso de tratarse de la potestad constitucional de iniciativa legislativa que al Gobierno corresponde (ATS de 3 de diciembre de 1998, a. 10658), al no estar en presencia de un acto de la administración Pública sujeto al derecho administrativo, en el caso el acuerdo del citado órgano que aprueba la remisión al congreso de los diputados del Proyecto de ley que crea secciones de la audiencia Provincial de Cádiz."76*

Resulta claro que, a partir de la Ley de 1956 y el desarrollo doctrinario y jurisprudencial, del que fue objeto el Acto de Gobierno (con particular intensidad en la década de los noventa), se podría resumir este periodo (el de vigencia de la Ley de 1956) como uno en el que se mantuvo y reafirmó la categoría del acto político dentro del derecho español. Dicho esto, se debe aclarar que tal figura fue despojada de su connotación originaria, en tanto la jurisprudencia entendió que en una interpretación del ordenamiento en su conjunto no cabe la inadmisibilidad *ad portas* como regla absoluta, frente a la pretensión de un administrado de que se revise un acto dictado por la Administración Pública.

[75] *Ibidem.*
[76] *Ibidem.*

"En el plano orgánico, reafirmado queda que sólo alcanza a la función política del Gobierno como consejo de Ministros, y en lo sustancial que el concepto de acto político no impedía sino al contrario imponía a los órganos judiciales rechazar la inadmisibilidad de los recursos, aunque esto resultaba procedente para algunas de las decisiones enmarcadas como propias del título V de la CE. Los conceptos judicialmente asequibles, entendidos como elementos reglados y como requisitos objetivos, deparan una justiciabilidad parcial de los actos políticos, por lo que procede no la inadmisión del recurso directo contra ellos (como pretenden habitualmente los abogados del estado o los letrados autonómicos), sino su admisión para verificar si tales elementos reglados existen y han sido respetados. Ahora bien, no se queda exclusivamente en esa aparentemente clara previsión de límites o requisitos normativamente establecidos ese control, pues obvio resulta que la casuística expuesta demuestra que alcanza asimismo la valoración de la decisión gubernamental en tanto afecte a otros derechos o valores constitucionales."[77]

Durante la vigencia de la Ley de 1956 se tiene entonces que el control judicial sobre los actos políticos no es pleno, en el tanto solamente se habilita la posibilidad de controlar ciertos aspectos específicos de estos actos, en detrimento de otros. No es sencillo tampoco vislumbrar una clara línea divisoria para entender, con grado de certeza, en qué escenarios una decisión judicial sobrepasa (o no) el límite de lo que jurisdiccionalmente resulta posible, siendo que los criterios dados, como lo son la existencia o no de elementos reglados, no resultan suficientes en muchos casos.

Ahora bien, con esta recapitulación efectuada (incluyendo lo expuesto en el capítulo I, sección segunda de la presente investigación) sobre el entendimiento doctrinal y jurisprudencial que tuvo lugar en España con respecto al acto político, durante la vigencia de la LJCA de 1956, se tienen suficientes elementos para empezar a comprender la actualidad del instituto en el derecho español. Lo anterior, a partir de la promulgación de la nueva LJCA de 1998 (como no podría ser de otra manera). Este cuerpo normativo, que vino a sustituir la antigua LJCA de 1956, desde su propia

[77] *Ibid.* P60.

exposición de motivos reafirmó el papel del contralor de legalidad como bastión de defensa de los derechos e intereses de los administrados, frente a la Administración:

> *"La Jurisdicción Contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades. Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la dotó de las características que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misión que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración."*

Antes de empezar la reseña en relación con la regulación, así como del tratamiento doctrinal y jurisprudencial que recibe el Acto de Gobierno, en el derecho español contemporáneo (a partir de la promulgación en 1998, de la LJCA), es indispensable transcribir el artículo de dicho cuerpo normativo, que se encarga de regular el instituto en cuestión. Así las cosas, el artículo 2 de la LJCA española, expone:

> *"Artículo 2. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos. (...)"*

Algunos elementos de este artículo, entre ellos, la última frase que hace referencia a *"Cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos"* ha llevado a pensar que, con la LJCA de 1998, en España desapareció el acto político, en tanto la característica principal de este es su inimpugnabilidad jurisdiccional, sobre ello:

> *"La STS de 24 de julio de 2000, a. 289/2001, afirma que en la nueva ley, «siguiendo una jurisprudencia del Tribunal Supremo, se hace desaparecer legalmente la noción de acto político como causa de exclusión del control judicial de los actos del Gobierno». Así es, en efecto, y por ello hay que compartir con Muñoz Machado que la LJCA ha hecho desaparecer como concepto legal los actos políticos, aunque no como idea doctrinal,*

naturalmente, ni como concepto técnico. y como idea y concepto técnico se mantiene y en cuanto tal es una categoría que la jurisprudencia reconoce para los actos de dirección política de naturaleza distinta de los actos administrativos, que puede identificarse con los actos presididos por la máxima discrecionalidad posible, y que con independencia de la mayor libertad de intervención que en relación con algunas clases de ellos, a partir de la nueva ley, revelan las sentencias del TS, en ciertos casos implica también decididamente la exclusión del control de algunos de ellos."[78]

La doctrina más autorizada en la actualidad española sostiene que, en relación con el contenido de los artículos 9 y 24 de la Constitución Política de ese país, resultaría imposible concluir la exclusión normativa del control judicial de ninguna categoría de actos, independientemente de la naturaleza de ellos, si se adscriben a una función política o administrativa. En ese tanto, contrariando la posición doctrinal recién expuesta, la jurisprudencia constitucional respaldó la exclusión efectuada durante mucho tiempo a nivel legal, por considerar que es respetuosa de tales parámetros, pese a la enorme contrariedad presentada por algún sector de la doctrina:

"En efecto, es evidente, y no cabe sino coincidir con Santamaría Pastor, que a contra corriente de la doctrina dominante, tanto el tribunal constitucional como el TS siguieron reconociendo, tras la CE, la exención jurisdiccional de determinadas actuaciones gubernamentales, declarando que esta restricción del control contencioso era plenamente respetuosa con el texto constitucional. Pero esta jurisprudencia no desanimó a la doctrina, que continuó ejerciendo una fuerte presión en pro de la supresión de los actos políticos exentos del control jurisdiccional."[79]

A raíz de esta insatisfacción de los sectores más autorizados, de la doctrina *ius* publicista española, la LJCA de 1998 intentó resolver este tema, con una perspectiva ecléctica del asunto, lo que se contempló en el artículo segundo recién transcrito.

"Sin duda, tanto el texto del exordio legal como el texto dispositivo se nos presentan como el fruto de un compromiso forzado por las circunstancias. Lo que es posible fundamentar, aceptando que el primero justifica una tesis que ha sido calificada de radical y no

[78] *Ibid.* P61.
[79] *Ibidem.*

amparada ni por la doctrina mayoritaria ni por la jurisprudencia, enfatizando a ese fin el principio del sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del estado de derecho, del que la ley parte; en tanto el segundo, con una redacción un tanto alambicada, al incluir la expresión «cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos», trata de resolver el antiguo y arduo problema de la exclusión del control jurisdiccional, de lo que el propio legislador denomina al final como actos del Gobierno (y de los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas), no sin suscitar problemas interpretativos."[80]

Ahora bien, observando la previsión legal introducida con la LJCA de 1998, resalta inmediatamente que la misma, al menos en lo que atañe al Acto de Gobierno, preceptúa una estructura de previsión positiva. Se entiende que no es que se excluyen estos y aquellos actos de la Administración, sino que se prevé el control de un cúmulo de actos (los de Gobierno) bajo ciertos parámetros. Una redacción en positivo, que trata de contemplar la posibilidad de impugnación jurisdiccional de un sector del actuar de la Administración polémico, en tanto en muchos casos irrevisable.

"Lo que Santamaría Pastor considera un gesto de habilidad con el que somete estos actos al control judicial pero limitando éste a tres aspectos concretos. El mismo autor elogia además la claridad con la que la ley identifica el órgano del que deben provenir estos actos parcialmente exentos de control: sólo de los Gobiernos estatal y autonómicos, pero de ninguno de sus miembros aisladamente (p.ej., el Presidente o alguno de los ministros o consejeros) ni de ninguna otra autoridad político-administrativa."81

Un elemento que no debe dar pie a confusión es la expresión utilizada por el artículo segundo para definir el objeto de la disposición, en tanto con una interpretación que incluya la fundamentación del legislador, así como los parámetros doctrinales contemporáneos, se puede arribar a un entendimiento correcto del asunto. Tal objeto puede resultar ambivalente de la sola lectura del artículo, en tanto posibilita entender que todos los actos de los órganos mencionados (componente

[80] *Ibid.* P62.
[81] *Ibidem.*

orgánico/sujeto de la emisión de un Acto de Gobierno) solamente serían revisables en atención a lo dispuesto en ese ítem.

> *"Obvio será, a pesar de ello, que sólo serán objeto de inclusión en ese precepto y, por tanto, objeto del control judicial limitado los actos no administrativos de esos supremos órganos, pues los administrativos quedan comprendidos en el art. 1.1. cuáles sean es, según adelantamos, el primero de los problemas ya que, en efecto, su concreta determinación y los criterios con los que en su caso diferenciarlos de aquellos otros que se sujetan al derecho administrativo no es un tema tan sencillo como a primera vista parece. La búsqueda de criterios persiste y seguirá persistiendo, porque la ley no ofrece criterio alguno para distinguir, dentro de la actividad de los Gobiernos, qué actos pertenecen a una categoría u otra, inequívocamente."*[82]

Entonces, el componente orgánico sigue jugando un rol fundamental para el entendimiento del Acto de Gobierno y, específicamente, de su revisión jurisdiccional en función de lo dispuesto por la LJCA.

> *"No es discutible, como señala Santamaría Pastor, que se trata de los actos de los Gobiernos estatal y autonómico que sean manifestación de su poder de dirección y que se adopten en ejercicio de poderes y funciones constitucionales; esto es, cuando los Gobiernos actúen como órganos constitucionales, no como órganos administrativos. Son estos actos únicamente los que se incluyen ahora de forma expresa a través de ese precepto, con esa fórmula que «prescinde pura y simplemente de la expresión actos políticos»"*[83]

Resulta complejo de aseverar que un acto es o no político o de Gobierno. Dado que los criterios otorgados por la LJCA y la propia Constitución Española resultan cuando menos ambiguos. Muchas decisiones en este sentido, sobre todo de cara a la marcada descentralización en función del territorio presente en España (modelo de comunidades autónomas), dificultan una interpretación uniforme y sostenida, en tanto ella puede variar, de acuerdo al entendimiento que el operador efectúe sobre estos conceptos más o menos indeterminados. Cuando menos, el texto es

[82] *Ibid.* P63.
[83] *Ibid.* P64.

claro en atacar uno de los bastiones de este instituto, que a su vez encarnó durante mucho tiempo el principal rasgo despótico de este, la imposibilidad de impugnarse por estar vinculado a una cláusula de inadmisibilidad (acto no susceptible de impugnación) en relación con su supuesto carácter especial.

> *"El texto tiene la virtud de no hacer exclusiones y permitir que todos los actos, en tanto posean elementos reglados o en tanto impliquen afectación de derechos constitucionales, puedan residenciarse ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin que el pretendido carácter político de un acto pueda erigirse en causa de inadmisibilidad."*[84]

En esa previsión puede observarse una atribución otorgada al contralor de legalidad, en donde se dispone que estos actos específicos son objeto de control judicial, cuando menos en ciertos elementos específicos de este. Lo anterior representa en sí mismo un paso importante hacia el control plenario de las potestades públicas, sin excepción. Ahora bien, tal y como se pudo observar, algunos nublados del día se despejaron con la introducción de la previsión legal, contemplada en el artículo segundo de la LJCA de 1998. Pese a lo dicho, la determinación de si un acto en concreto está adscrito a esta categoría o a otra es una decisión que el operador jurídico, en este caso el contralor de legalidad, deberá tomar de manera casuística en cada caso concreto, dado que persiste la inexistencia de un parámetro absoluto y definitivo, que permita discernir los actos políticos de todas las demás especies de actos de la Administración.

> *"Según vamos a tener oportunidad de apreciar, y como manifiesta con claridad la STS de 26 de noviembre de 1999, es a la justicia a la que compete «determinar el carácter político o administrativo del acto recurrido», al menos a los efectos del control jurisdiccional «cuyo contenido suscita dificultades de entendimiento, atendiendo a su naturaleza»."*[85]

Esa determinación jurisprudencial, pendiente de realizar de manera acabada, ha sido un tema que ha ocupado la actividad de los más altos tribunales españoles, desde la aprobación de la normativa de 1998. Ciertamente, los tribunales españoles se han esforzado por realizar esa difícil empresa de delimitar los Actos de Gobierno, estableciendo criterios para determinar el carácter político (o en su defecto, administrativo) de los actos emitidos por las Administraciones Públicas. Si bien el

[84] *Ibidem.*
[85] *Ibid*. P65.

aspecto orgánico ofrece una base importante para cumplir con esta tarea, resulta insuficiente, por lo cual, de manera ineludible, se debe atender a una distinción material, en los términos mencionados.

> *"Un primer grupo de actuaciones serían las referidas a las relaciones señaladas en la STC 45/1990, en tanto en un segundo grupo estarían las relaciones políticas o institucionales ya referidas en las STC 196/1990 y 220/1991, que, en principio, podrían quedar con carácter general asimismo excluidas según esa jurisprudencia constitucional. Dejando a un lado estas últimas, entiendo que las otras están, en efecto, excluidas, como revelan los pronunciamientos judiciales posteriores a la entrada en vigor de la ley, que inadmiten los recursos frente a determinadas decisiones relativas a la iniciativa legislativa (caso del citado ATS de 3 de diciembre de 1998 y que posteriormente mantiene la STS de 26 de octubre de 1999, a. 7449), reiterando que proceda del consejo de Gobierno autonómico o del consejo de Ministros, no es el simple producto de un actuar de la administración sino el ejercicio de unas funciones específicas, por lo que se trata de una actividad política que culmina en un acto de tal naturaleza no susceptible de impugnación ante la jurisdicción."*[86]

Ciertamente, como se puede observar, la jurisprudencia de finales del siglo XX e inicios del XXI, más allá de tratar de establecer criterios a partir de los cuales se pudiese determinar un Acto de Gobierno, labor a la que sí dedicó tiempo aunque sin mucho éxito, logró establecer ejemplos concretos de actos de la Administración, que deben tenerse como Actos de Gobierno. En todo caso, con la LJCA de 1998, desde su exposición de motivos se dejó sentado el principio de sometimiento pleno de la actividad administrativa al contralor de legalidad y al imperio de la ley. Como se pudo ver, se le dieron facultades a la jurisdicción contenciosa para revisar, con mayor grado de intensidad, algunos alcances específicos de la actividad administrativa que antiguamente estuvieron vedados, como lo es el Acto de Gobierno.

> *"Así, el art. 26, tras declarar el principio de sometimiento del Gobierno «a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación» (apartado 1), establece los controles que proceden contra sus actuaciones: el de tipo político, ante las Cortes Generales (apartado 2) y el de tipo jurisdiccional, que a su vez puede ser de dos formas:*

[86] *Ibid.* P 66.

en sede contencioso administrativa (apartado 3) y en la constitucional (apartado 4), en uno y otro caso, en los términos previstos en las leyes reguladoras de las respectivas jurisdicciones. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sufrió importantes reformas mediante la Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo, que afectaron la configuración del recurso de amparo, único remedio disponible para el control en esa sede de la actividad del Gobierno que atentara contra los derechos fundamentales. Su carácter extraordinario se mantuvo, pero esta vez sometido a serios requisitos de admisibilidad. Con ello se refuerza el protagonismo – que en realidad siempre tuvo – de la jurisdicción ordinaria en el control de los actos políticos del Gobierno y que ocupará nuestro examen."[87]

En resumen, con la ambigua determinación realizada por la LJCA de 1998, se deja una apertura a la interpretación, lo que no se hizo esperar por varios sectores de la doctrina, así como por invaluables aportes jurisprudenciales, ambos descritos en líneas *supra*. Se hace entonces una inclusión del Acto de Gobierno dentro de las prerrogativas de control del juez contencioso, aunque limitado a ciertos elementos (reglados) o a supuestos específicos, como la lesión de derechos subjetivos. Pero no se logra descifrar de manera clara, a partir de la redacción de dicho artículo, que existe la posibilidad de una revisión *ad integrum* del acto en cuestión, sino bajo los límites descritos:

"En resumen, no cabe dudar de que el texto comentado, al no estar redactado en forma negativa, es decir, al no hacer exclusiones a la competencia jurisdiccional de ningún tipo de acto del Gobierno, permite que todos los actos, en tanto posean elementos reglados (y obviamente todos los poseen), o en tanto impliquen afectación de derechos fundamentales o causen algún daño que pueda generar responsabilidad patrimonial, puedan residenciarse ante la jurisdicción contencioso- administrativa, sin que el pretendido carácter político pueda esgrimirse como causa de inadmisibilidad. Sin embargo, ello deja sin resolver el problema de la existencia de la categoría del acto político del que se predique un control diferente y acaso menos intenso del que se predica de los actos administrativos. La cláusula de atribución positiva de competencia, tal como se recoge en el art. 2 a), lo único que asegura es que los actos de los Gobiernos serán susceptibles

[87] Marcheno Acuña, B. El control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno en el derecho español. Madrid, España. Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje. Vol 2, no 2 (junio 2015). P29.

siempre del control judicial en algunos de sus elementos, sin que ello signifique, en principio, que los tribunales puedan realizar un análisis un poco más intenso de la decisión política, sin sustituirla, claro está, so pena de incurrir en un manifiesto quebrantamiento del orden institucional."[88]

Entonces, claramente la revisión de los Actos de Gobierno en España, si bien es una posibilidad, es una sumamente limitada, en tanto se ejerce un control débil de dichos actos por parte del contralor de legalidad. La calificación de estos como actos constitucionales fue un elemento que colaboró nuevamente con los límites interpuestos al juez contencioso. Este razonamiento empleado por los más altos tribunales españoles hizo proliferar el abordaje constitucionalista del Acto de Gobierno (inevitable en todo caso, independientemente de la trinchera de abordaje), relativizando con ello, nuevamente, el control que el juez contencioso podría efectuar sobre este tipo de actos de la Administración:

"Recordando toda la doctrina jurisprudencial anterior a la LJCA sobre la naturaleza política de las relaciones entre el Gobierno y los demás órganos constitucionales, distinta de la administrativa, pronunciamientos judiciales posteriores a la entrada en vigor de la ley, inadmitieron recursos frente a determinadas decisiones relativas a la iniciativa legislativa. Tal es el caso del ATS de 3 de diciembre de 1998, en el que el tribunal prefirió no usar la categoría de acto político para calificar este tipo de actuación del Gobierno, sino que las rebautiza como «acto constitucional». Argumenta el auto que: «no estamos en presencia de un acto de la Administración Pública, sujeto al derecho administrativo (...) sino que es objeto de impugnación jurisdiccional un acto del Gobierno(...) que tiene sus propios mecanismos de control, sin que, en consecuencia, y por tanto, pueda ejercer ésta Jurisdicción su función....Corolario obligado de la exposición anterior, por resultar el acuerdo impugnado acto constitucional, excluido en absoluto del ámbito de nuestro conocimiento y, consecuentemente, de su verificación, sea cuales fuesen las razones aducidas para basamentar la pretensión, es la declaración de la inadmisibilidad del recurso…»"[89]

[88] *Ibid.* P33.
[89] *Ibid.* P34.

Ahora bien, siendo que coexisten variedad de Actos de Gobierno, que tradicionalmente se han concebido como ejemplos de este, dentro del accionar de las Administraciones Públicas; se debe mencionar que algunos de ellos generan mayores dudas, en cuanto a su armonía con el ordenamiento garantista de justicia administrativa plena, como lo sería el caso del polémico indulto. Este instituto se ha visto excluido históricamente de control jurisdiccional en España. No se entiende muy bien el subsumirlo dentro de la categoría de acto político, esa categorización le ha dado pie al Tribunal Supremo para justificar la exención de control sobre el instituto del indulto, particularmente de un elemento de suma relevancia dentro de cualquier acto, como lo es la motivación.

> *"En la casi totalidad de las sentencias sobre este asunto y a las que ya hemos hecho referencia, el órgano jurisdiccional enfatiza en que «el acuerdo negatorio de la concesión de indulto constituye un acto graciable, como categoría distinta de los actos discrecionales» y por tanto no le resultan de aplicación los requisitos exigidos al resto de los actos administrativos discrecionales «y entre ellos, y fundamentalmente, el de la motivación, que no es exigible en las decisiones que sobre el ejercicio del derecho de gracia se adopten por el Gobierno», por lo que el control «se encuentra limitado a los aspectos formales de su elaboración; concretamente, a si se han solicitado los informes que la Ley establece como preceptivos, informes que, por otro lado, no resultan vinculantes»"*[90]

El Tribunal Supremo no es vacilante en enunciar al indulto como un claro vestigio autoritario, del absolutismo, características que resultan transversales a toda la genealogía del Acto de Gobierno. Sobre ello fue tajante en enunciar:

> *"Más explícita resulta la posición de la jurisdicción penal del propio TS, cuando en el Auto de 16/10/2012, sin ningún tipo de sutilezas o ambages se refiere a la genealogía del indulto como «prerrogativa regia y manifestación de "justicia retenida" en su origen. Herencia del absolutismo, al fin y al cabo, de no fácil encaje, en principio, en un ordenamiento constitucional como el español vigente, presidido por el imperativo de sujeción al derecho de todos los poderes, tanto en el orden procedimental como sustancial*

[90] *Ibid.* P36.

de sus actos; y, en consecuencia, por el deber de dar pública cuenta del porqué de los mismos. Un deber especialmente reforzado en su intensidad, cuando se trata de resoluciones jurisdiccionales, más aún si de sentencias de condena; que, paradójicamente, pueden luego, como en el caso, hacerse vanas sin que conste ninguna razón estimable, en el ejercicio de una discrecionalidad política, más bien arbitrio, no vinculada e incontrolable, por tanto».”[91]

En suma, de todo lo dicho se puedan extraer varios razonamientos, que engloban el panorama del Acto de Gobierno en la actualidad del derecho español. A pesar de lo ansiado por la LJCA de 1998, expresamente planteado en su exposición de motivos, sobre la desaparición de figuras de actuaciones incontrolables al contralor de legalidad, es decir, entre ellas del acto político, esta figura se mantiene en el ordenamiento. Se mantiene el acto político bajo otras denominaciones, como lo sería el Acto de Gobierno autonómico, acto constitucional, pero en esencia es el mismo concepto de actos administrativos irrevisables. Aunque:

“Ciertamente, tanto la legislación como la propia jurisprudencia se han encargado de despojar al concepto de sus atributos originarios, esto es, el de excluir del control jurisdiccional a los actos calificables como tal, mediante la introducción del control de los elementos reglados, la protección de los derechos fundamentales y las indemnizaciones que procedan. Pero esto tampoco ha sido así en todos los casos. Si lo hubiera sido, la distinción entre actos políticos y actos administrativos discrecionales sería perfectamente inútil (como de hecho lo es en la mayoría de los casos) porque, como bien señala García de Enterría, a través del control de los elementos reglados, que es como se controlan todos los actos discrecionales, ambos conceptos tendrían la misma consideración, esto es, actos discrecionales del Poder Ejecutivo.”[92]

Sin embargo, la LJCA no logró evitar que la jurisprudencia de los más altos tribunales españoles, es decir, el derecho en su sentido más palpable, lo dispuesto por operadores jurídicos en conflictos procesados ante el judicial, deje de lado la categoría, asegurando el control de todas las actuaciones de la Administración y alejando estos elementos despóticos.

[91] *Ibid.* P37.
[92] *Ibid.* P44.

"Pero como se ha visto, aún después de la entrada en vigor de la LJCA la jurisprudencia ha seguido utilizando el Acto de Gobierno para omitir el enjuiciamiento de esos elementos reglados (o de algunos de los elementos reglados) de actos del Gobierno al menos en dos supuestos claros: El de la iniciativa legislativa, en el que el TS se desatiende claramente de la previsión del art. 2 a) de la LJCA, inadmitiendo de plano recursos contra actos que gozan de esa naturaleza política, omitir con ello el deber de fiscalizar los actos del Gobierno «cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos» y el segundo es el ejercicio del derecho de gracia, al que, por su particular tratamiento jurisprudencial, le haremos un aparte en el siguiente epígrafe"[93]

[93] *Ibidem.*

Sección Segunda: El Acto de Gobierno en Costa Rica

Imposible resulta hablar del Acto de Gobierno en Costa Rica (o en general, de cualquier instituto de derecho administrativo) sin acudir, como fuente primaria, a la doctrina de Eduardo Ortiz Ortiz. Este personaje es el precursor intelectual del derecho administrativo contemporáneo costarricense, mediante la importación de los conceptos desde el derecho continental europeo (donde se formó) hasta nuestro país. Dicha labor, ciertamente indispensable y de enorme valía, ya entrado el siglo XXI dio al traste con el inevitable deber de modernización doctrinal, que demanda el siempre cambiante derecho público; por lo cual, si bien nunca podría menospreciarse la doctrina del Lic. Ortiz, deben señalarse algunas anotaciones (lo cual se hará oportunamente), en los márgenes de lo desarrollado en la segunda mitad del siglo XX por este eminente jurista. Dicho esto, debe además enfatizarse que en la prolífica obra del Lic. Ortiz se realizó un amplio desarrollo del Acto de Gobierno. En atención a lo expuesto, por ser este jurista, el principal y unívoco precursor del derecho administrativo costarricense, así como la amplitud con la que desarrolló el instituto en cuestión (sin par en la doctrina local), este apartado se centra en su planteamiento, en tanto se postula (con las rectificaciones, precisiones y ampliaciones que se efectuaran posteriormente) como la doctrina correcta del Acto de Gobierno en Costa Rica.

Menciona Ortiz la concepción clásica del Acto de Gobierno, a partir de la cual empieza su análisis. Posteriormente, problematiza los elementos de dicha concepción clásica, para esclarecer el instituto, así como realizar un planteamiento propio, acorde con los principios más elementales del derecho administrativo de fondo y procesal. Entonces, en suma, dicha concepción clásica se destaca como la doctrina que propone:

> *"Llámese acto político o de gobierno al acto del Poder Ejecutivo, lesivo de derechos o intereses, que es inmune al contralor jurisdiccional de constitucionalidad o de legalidad, no obstante estar sometido a la Constitución y a la ley."*[94]

94 Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo I. Costa Rica: Stradtmann. 1998. P 121.

Aunque posteriormente, previo a efectuar un análisis exhaustivo del instituto, adelante que:

> "*El Acto de Gobierno es, como se explicará, el acto constitucional, en cuanto sometido únicamente a la Constitución y no a la ley. Esto significa que la determinación del Acto de Gobierno por el ordenamiento es más vaga e imprecisa que la del Acto Administrativo.*"[95]

En esa única cita, Ortiz deja entrever una serie de apreciaciones importantes de cara al Acto de Gobierno. Lo califica desde ese momento como un acto constitucional, señalamiento que no es accidental, en tanto considera que la habilitación de este es únicamente constitucional, lo que implica, a su vez, que su sometimiento existe únicamente en función de esta norma y no de otras (leyes). Esta nota característica contiene el núcleo de la propuesta de Ortiz, el Acto de Gobierno entendido eminentemente como acto constitucional.

Señala que la delimitación normativa sobre el Acto de Gobierno es mucho más rigurosa que la del Acto Administrativo, en tanto éste último se rige por el principio de regulación mínima. Este último punto implica que los elementos (sujeto, motivo y contenido) necesariamente están determinados puntualmente en el Acto Administrativo, a lo que señala que no sucede en caso del Acto de Gobierno. Con respecto al fin, como elemento del Acto Administrativo, va más allá y asevera:

> *"Puede afirmarse que la Administración puede actuar en materia de gobierno con igual libertad que el particular respecto de los fines a perseguir, porque le está permitido cualquiera a condición de que no se aun fin privado del funcionario."*[96]

Localiza Ortiz la innegable y evidente conexión entre este instituto y la función gubernativa, la estrecha relación que existe entre este y la unidad de acción y de poder estatal. Sobre este punto señala:

> *"Por regla general, es Acto de Gobierno o bien el que tiende a conservar la existencia del Estado y de sus elementos, o bien el que tiene por meta mantener su funcionamiento al más*

95 *Ibid.* P50.

[96] *Ibidem.*

alto nivel institucional, fijándole programas y fines generales, regulando las relaciones entre los supremos poderes y entre el Estado y otros estados."[97]

Señala como ejemplos de Actos de Gobierno las relaciones internacionales, con particular énfasis en lo relativo a defensa del Gobierno y su integridad. Dentro de este último rubro, para ilustrar aún más con ejemplos concretos y específicos de situaciones ante las que procede la adopción de Actos de Gobierno, resaltan el estado de sitio, defensa nacional y la guerra. Por otro lado, también se cita en su obra, como ejemplo de situaciones susceptibles de adopción de un Acto de Gobierno, la intervención mediante el poder policía, en situaciones que pudieran generar una ruptura irreparable del orden y la estabilidad de la comunidad.

Ortiz centra gran parte de su obra sobre el derecho administrativo, en los principios generales del derecho y su interacción e implicaciones con la aplicación práctica de esta rama. Ello es transversal a su obra, entendiendo (de manera acertada) que dichos principios configuran la égida a partir de la cual se despliegan todos los razonamientos que justifican y sostienen el derecho administrativo. El Acto de Gobierno no escapa de ese tamiz específico de análisis (los principios generales del derecho público), como no podría ser de otra forma dentro de ese método; Ortiz comienza por someter al instituto a un análisis de cara al principio de legalidad, sobre el cual, en relación con el Acto de Gobierno, expuso:

"El principio de legalidad es también en este caso imperativo de una regulación mínima, que contemple el sujeto (órgano) y el motivo o el contenido del acto, siempre a condición de que no sea la ley sino la Constitución la fuente de dicho régimen."[98]

En definitiva:

"Es correcto aceptar que el principio de legalidad rige también el Acto de Gobierno, si se entiende bien que en este caso la finalidad del acto no tiene que estar determinada, siempre que no esté prohibida por el ordenamiento (prohibición expresa, invasión de competencias extrañas).[99]

[97] *Ibidem.*
[98] *Ibid.,* P51.
[99] *Ibidem.*

La propuesta clásica del Acto de Gobierno, mencionada anteriormente, plantea que existe una exclusión o limitación de la jurisdicción de legalidad, e incluso de constitucionalidad, de unos actos específicos. La doctrina continental europea, particularmente la española descrita *supra*, sostuvo durante mucho tiempo la existencia de una incompetencia jurisdiccional, generada en caso de encontrarse frente a Actos de Gobierno. En suma, encarnaría una excepción al principio de que acudiendo a los tribunales todos habrán de encontrar reparación a los agravios sufridos en sus intereses o derechos (artículo 41 constitucional), sobre este último punto amplió Ortiz:

> *"Lo mismo que a la regla, todavía más importante, de que cualquier tiene potestad para obligar a los tribunales a conocer de un conflicto jurídico si demanda su actuación de conformidad con la ley (artículo 27 CP):"*[100]

Ortiz señaló que tal excepción y posible incompetencia es únicamente admisible en cuanto al contralor de legalidad, no así frente al de constitucionalidad. Ello debido a la supremacía innegable de la Constitución sobre disposiciones de cualquier otro orden. Si bien hay autores que incluyen dentro de la doctrina de Acto de Gobierno los regulados únicamente por la Constitución, lo que avalaría la imposibilidad incluso al contralor de constitucionalidad, ello da al traste con la legislación vigente en el país, particularmente en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo cual se retomará posteriormente.

Uno de los elementos que advierte Ortiz es el origen histórico del Acto de Gobierno en el Consejo de Estado francés, que derivó en la formulación de una lista de Actos Administrativos que estarían exentos de control jurisdiccional, atendiendo a los intereses en juego, no negociables con quien ostentaba el poder (germen despótico del instituto). Esa lista de actos administrativos, señala Ortiz, que actualmente en el Consejo de Estado en Francia se reduce principalmente a dos tipos de actos,

> *"A saber: los actos de relación entre Supremos Poderes y los actos de relación internacional."*[101]

Si bien ya con lo descrito puede delimitarse muchísimo la cantidad de Actos Administrativos que estarían en la categoría, siendo que incluso *supra* se otorgaron ejemplos específicos, lo cierto es que aún existen múltiples actos que podrían verse encajados en estas clasificaciones. Ortiz advierte

[100] *Ibid.* P121.
[101] *Ibid.* P124.

lo dicho y agrega otro criterio para clasificar la totalidad de esos actos en dos grandes grupos y, con ello llevar a cabo un análisis más enfocado y delimitado. Propone dividir estos actos, presuntamente exentos de control jurisdiccional, en un primer grupo de actos no lesivos de derechos o intereses de los administrados (instrucciones a servicios diplomáticos, actos de soberanía exterior) y lesivos de derechos e intereses, los cuales merecen especial énfasis. Con respecto a este último supuesto, señaló:

> *"En relación con este tipo de actos la doctrina en examen consiste en mantener la inimpugnabilidad de los mismos siempre que medien razones de estado, de tipo vario, que exijan su adopción y ejecución. Las doctrinas para determinar cuándo se da la nota característica o la razón de estado que permite dicha inimpugnabilidad son muchas y contradictorias."*[102]

El estudio de dichas doctrinas ha sido descrito anteriormente y se retomará a la postre, empero, por obedecer a un aspecto más bien procesal, su análisis procede en otro acápite diferente al actual, en el que se busca informar de la doctrina costarricense del Acto de Gobierno. En todo caso, dichas doctrinas tienen como denominador común el pretender la remoción de actos lesivos de derechos e intereses del contralor judicial, lo cual, adelanta Ortiz, es inconcebible. Sobre lo recién dicho, así como de la multiplicidad de doctrinas expuestas por Ortiz, en palabras del propio autor:

> *"Todas las anteriores doctrinas se refieren a los actos políticos que pueden ser lesivos de derechos e intereses del ciudadano; porque afecta las relaciones entre éste y el Estado. La doctrina del Acto de Gobierno es un medio de sustraer actos al contralor jurisdiccional, para conservar su vigencia en beneficio de la integridad y del funcionamiento del Estado como un todo. Tal doctrina es incompatible con la existencia de un Estado sometido al derecho."*[103]

Ciertamente, la concepción de que puede haber actos lesivos de derechos, que no sean revisables ante ninguna jurisdicción, es contraria a los principios más elementales del derecho administrativo, como el de legalidad. En efecto, los actos deben estar sometidos al ordenamiento jurídico, el cual a su vez debe estar determinado previo y, en caso de que exista una violación, debe poder ser

[102] *Ibid.* P126.
[103] *Ibid.* P132.

revisada y restituida la situación jurídica preexistente y afectada del administrado. Todo acto antijurídico debe poder ser anulado, aunque se debe aclarar: el que está facultado por la constitución directamente, el cual solo podría ser invalidado por el contralor de constitucionalidad. Sobre este último extremo, Ortiz enunció:

> *"En el caso de los actos lesivos de derechos e intereses sometidos únicamente a la Constitución, el único contralor posible es el de constitucionalidad; los mismos están sustraídos al de legalidad, por versar es último exclusivamente sobre actos supeditados también a la ley. Pero el contralor de constitucionalidad es, entonces igualmente necesario que el de legalidad para los actos comunes del Estado. No hay, entonces, acto alguno del Estado que deba sustraerse al contralor jurisdiccional de legitimidad, dentro de un régimen de derecho, siempre y cuando lesione derechos o intereses."*[104]

Ortiz refiere que esta posición negativa de la existencia del Acto de Gobierno resulta la imperante en Costa Rica. La Constitución Política, según Ortiz, en su carácter de norma suprema del ordenamiento, garantiza su vigencia a través de la determinación de una serie de jurisdicciones que lo procuren, entre las que menciona la de *habeas corpus*, la de amparo, la contenciosa y la de constitucionalidad. En atención de ello es insostenible la total imposibilidad de revisar jurisdiccionalmente un acto de la Administración.

Efectuó Ortiz una aclaración en relación con la propia Constitución Política vigente en nuestro país. Lo dicho, en tanto ese cuerpo normativo pareciera abrir un espacio interpretativo que respaldaría la tesis de la inimpugnabilidad absoluta de ciertos actos de la Administración. Sobre ello enunció:

> *"Es cierto que el artículo 10 párrafo primero de la Constitución sustrae de la jurisdicción de constitucionalidad los actos "que determine la ley". Esto pareciera inmunizar contra esa jurisdicción los actos que exime de ella cualquier ley, sea anterior a la Constitución de 11 de noviembre de 1949."*[105]

De inmediato, el autor se repone de dicho contrapié dentro de la perspectiva garantista de la justicia administrativa que se venía haciendo. Para ese efecto, realiza un análisis interpretativo sumamente

[104] *Ibid.* P133.
[105] *Ibidem.*

interesante, en el que agrupa sistemas de interpretación que pasan por lo teleológico, hasta un análisis complementario del resto de la propia Constitución. Centra su atención en el artículo 10 constitucional, de cara a la imposible exclusión de una parcela del accionar de la Administración, de todo contralor jurisdiccional existente. Ello es inviable incluso en un análisis de legalidad, pero más aún lo es de cara al contralor de constitucionalidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Carta Magna, que prevé:

> *"ARTÍCULO 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley."*

Pareciera entonces realizarse una posible exclusión de esta vía, de ciertos actos específicos de la Administración, siempre y cuando se cumpla con la cláusula de (aparente) excepción establecida por el artículo *ibidem*, es decir, que sea determinado por la Ley. Antes de realizar semejante aseveración, se debe realizar una labor interpretativa plenaria, que agrupe no solamente el texto de la norma (así sea la Constitución misma) sino que se armonice con los principios vectores del derecho público, así como con el resto de las normas (incluso la propia Constitución) que complementan el análisis. Sobre lo dicho expuso Ortiz:

> *"Tal interpretación del artículo 10 de la CP choca con el espíritu tutelar de la jurisdicción de constitucionalidad que, según el artículo 75 de la ley respectiva, puede ser no sólo directa o principal (sin apoyo en juicio antecedente) sino también incidental para cuya resolución es necesario despejar prejudicialmente la cuestión de constitucionalidad del indefenso de los derechos o intereses que se consideren lesionados. Es decir se trata de una jurisdicción subjetiva dirigida no sólo a la depuración del ordenamiento y a la garantía de la supremacía de la Constitución, sino, además de un instrumento de tutela de los derechos e intereses ofendidos o invocados como tales, que sirven de sustento a otro juicio principal."*[106]

[106] *Ibid.* P133.

Tal y como se puede ver, toma en cuenta para verter este criterio la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional. Es evidente la riqueza de la interpretación de Ortiz Ortiz, que considera las doctrinas más autorizadas del derecho continental europeo de su época, la ruta trazada por los principios generales del derecho, así como una interpretación normativa de gran valía. De lo expuesto, así como de las demás razones explicadas al inicio del capítulo, que se tome el desarrollo efectuado por este autor como la base de la explicación relativa al Acto de Gobierno en Costa Rica. Ello, aunado a la poca regulación directa que existe sobre el instituto, pero principalmente la escaza (casi inexistente) jurisprudencia, lo que no sorprende, partiendo de que la nota distintiva tradicionalmente abrogada al instituto, sea su inimpugnabilidad jurisdiccional.

No podría faltar, en un análisis normativo del Acto de Gobierno, una mención de lo planteado en el artículo 49 de la Constitución Política, es decir, el establecimiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda. El artículo mencionado dispone:

> *ARTÍCULO 49.- Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.*
>
> *La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.*
>
> *La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.*

No es antojadiza la razón por la que se tratan seguidos, los artículos 10 y 49 (correspondientemente) de la Constitución Política, en relación con el instituto que nos ocupa. Lo anterior, en el tanto la presunta exclusión efectuada por el artículo 10 arroja a dos conclusiones necesarias: por un lado, dicha exclusión debería efectuarse por una Ley posterior a la Constitución, por otro lado, se trataría además de un acto que no esté tampoco sujeto a la jurisdicción contenciosa administrativa de legalidad. Este último supuesto estaría a contrapelo de lo recientemente

plasmado en relación con el artículo 49 de la Constitución Política, dado que en ese artículo, tal y como se pudo observar, no se contiene ninguna excepción. Tal y como expuso Ortiz:

> *"Más bien impone a dicha jurisdicción el deber de tutelar, al menos, los derechos subjetivos e intereses legítimos del individuo, de acuerdo con la ley, lo que es posible cuando el Acto de Gobierno los lesiona, con violación única-mente de ésta."*[107]

Hasta este punto, Ortiz efectuó una serie de consideraciones de suma importancia para la doctrina del Acto de Gobierno en Costa Rica, para lo cual echó mano, principalmente, de las normas constitucionales y legales que regulan los extremos más importantes del instituto, así como un análisis doctrinal (con criterios propios, así como de otros autores) del concepto. Pese a lo recientemente expuesto, hasta este punto el autor no ha enunciado su posición particular con respecto al instituto en cuestión.

La perspectiva de Eduardo Ortiz sobre el Acto de Gobierno en Costa Rica tiene como marco teórico la doctrina de la función constitucional que, según lo destaca el propio autor, ha sido sostenida en Italia por Rannelletti y en Alemania por Forsthoff, entre otros, así como lo ha hecho en Latinoamérica el tratadista Miguel Marienhoff, a cuya perspectiva se adscribe el autor en este tanto. En palabras del propio Ortiz:

> *"La función constitucional es la que se expresa en actos autorizados por la Constitución, normalmente discrecionales, que afectan la organización y la existencia del Estado, sin tocar la esfera jurídica de los particulares. Su expresión más clara está en los actos internacionales y en los de relación entre los Supremos Poderes."*[108]

La función constitucional descrita, a su vez, se materializa en la emisión de actos constitucionales, los cuales deben estar autorizados directamente por la Constitución, es decir, una competencia constitucional generada en favor del Poder Ejecutivo. Además de ello, Ortiz contempla un argumento existente en parte de la doctrina base de esta perspectiva, como lo es el hecho de que las leyes que especifiquen los márgenes de dichos actos constitucionales no pueden establecer disposiciones que rocen con lo establecido a nivel constitucional. Ortiz no se adscribe por completo

[107] *Ibid.* P134.
[108] *Ibid.* P136.

a esta última posición, en tanto considera que sí hay actos constitucionales que deben ser detallados por la ley, para lo cual cita como ejemplos la determinación del estado de defensa nacional y la suspensión de garantías.

Un aspecto importante, con respecto al acto constitucional señalado por Ortiz, es que normalmente tiene cuenta con una amplia discrecionalidad, elemento indispensable para tenerse como tal. Incluso señaló el autor:

> *"Puede aludirse a la discrecionalidad del acto constitucional como a una forma nueva y distinta de la discrecionalidad administrativa. Esta se definió como la libertad de elección de la conducta necesaria para el cumplimiento de un fin público, indicado por el ordenamiento, fundamentalmente por la ley o por la jurisprudencia. La esencia de la discrecionalidad consiste en el doble juego de una libertad en cuanto a motivo y contenido del acto y de una vinculación legal en cuanto al fin del mismo"*[109]

En suma, entonces, esta nueva especie de discrecionalidad, llamada política o constitucional, yace en la posibilidad de que un acto sea regulado únicamente en lo relativo al sujeto competente, no así en el fin, cuya necesaria regulación legal pesa sobre los demás actos administrativos. Es entonces el acto constitucional, uno con discrecionalidad en cuanto a motivo, contenido y fin.

Señaló Ortiz una última nota diferenciadora del llamado acto constitucional que, sobre la base de la doctrina de la función constitucional descrita, consideró el autor la doctrina correcta del Acto de Gobierno; es decir, el único cuya existencia resulta válida en contraste con un análisis hermético del ordenamiento. Dicha (tercera) característica sería su relación directa con la organización y existencia del Estado, además de que este no puede afectar los derechos o intereses de los administrados. Esta última valoración se debe atemperar con el hecho de que excepcionalmente puede afectar a un individuo determinado, como sucede en el escenario del nombramiento de un ministro, aunque en tales supuestos existe un interés simultáneo de la comunidad y el Estado en el funcionamiento de este último, que justifica dicha acción.

Normalmente, el acto constitucional es general, lo que implica que está dirigido a toda la comunidad, aunque se debe aclarar que en los casos en que ello no sea así, tiene por objeto integrar

[109] *Ibid.* P 138.

los órganos constitucionales indispensables para el funcionamiento del Estado. En atención a lo anterior, se podría afirmar que:

> *"es siempre un acto de máximo interés para el resto de los órganos y para el público."*[110]

Como se ha adelantado en repetidas ocasiones, cuyos efectos serán explorados posteriormente en esta investigación, resulta imposible la admisión, dentro de un Estado garantista, la existencia de Actos Administrativos lesivos de derechos e intereses, completamente abstraídos de todo contralor jurisdiccional. Por ello, en la doctrina admisible del Acto de Gobierno, señaló Ortiz:

> *"A resultas de su alcance general y de su destinatario el acto constitucional no es capaz de lesionar por sí derechos ni intereses en forma directa o inmediata. Es normalmente un presupuesto o antecedente de los actos administrativos comunes que producen ese efecto lesivo. Ello tiene como consecuencia que el acto constitucional no es impugnable en el momento en que se produce, sino después de que se da el Acto Administrativo en el mismo fundado y con efecto lesivo en la esfera jurídica del particular. Si el primero es inconstitucional o ilegal su invalidez produce la de los actos subsiguientes y puede revelarse después de estos últimos"*[111]

Este último enunciado, expuesto por el autor, merece una consideración, en tanto prevé que en el caso de acto constitucional (que ya se dijo, no es impugnable en sí mismo), que sea contrario a la Constitución o a la Ley y, posteriormente, sea materializado o desarrollado por otros actos separados de este pero subsiguientes, en tanto tienen como base previa el acto constitucional, estos últimos actos, en tanto lesivos de derechos o intereses de los administrados, sí serían impugnables por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad. En suma:

> *"En consecuencia, la impugnación del acto constitucional resulta inadmisible por falta de interés o derechos subjetivos violados, así como de legitimación procesal. La razón de la no impugnabilidad del acto constitucional es su irrelevancia jurídica para el particular, que genera una falta de legitimación en éste para establecer el juicio consiguiente."*[112]

---

[110] *Ibid.* P140.
[111] *Ibidem.*
[112] *Ibidem.*

Es clara entonces la posición de Eduardo Ortiz, en tanto que el Acto de Gobierno resulta insostenible en su configuración clásica (no impugnabilidad sin excepción, incluso en caso de generar daños a derechos o intereses legítimos). Al menos es insostenible de cara a los principios elementales del acceso a la justicia, así como del bloque de juridicidad en su conjunto. Solamente es viable sostener la existencia de un acto de tales características, en el supuesto del acto constitucional descrito anteriormente. La doctrina del Acto de Gobierno que lo postula como un acto lesivo de derechos e intereses no debe existir. Señaló Ortiz de forma tajante que:

> *"No hay necesidad de recurrir a una teoría especial del Acto de Gobierno, fundada en razones varias de Estado y principalmente en el carácter unitario o totalitario del fin del acto, a efecto de explicar su inmunidad jurisdiccional."*[113]

Entonces, la postura adecuada, ya no solo en términos del ilustre Eduardo Ortiz, sino compartida para efectos de la presente investigación, es la que destaca que el Acto de Gobierno en su concepción clásica y con su nota distintiva de inimpugnabilidad jurisdiccional, no solamente es un instituto que no supera la revisión contrastada con el bloque de juridicidad existente en Costa Rica, sino que es insostenible doctrinalmente, de cara a los principales parámetros de la justicia administrativa y del derecho público. Tal y como expuso Ortiz:

> *"El acto del Poder Ejecutivo, regulado por la Constitución y por la ley, normalmente discrecional y no lesivo de derechos ni intereses, por ser atinentes en forma inmediata y directa a la organización y existencia del Estado, es el acto constitucional o institucional (Marienhoff) y representa la única forma admisible de acto no impugnable, por obvias razones de legitimación procesal."*[114]

La función jurisdiccional del Estado se expresa a través de estos actos, con rango y fuerza formal de ley, ello en tanto subordinados en primer grado a la Constitución. La expresión de dicha función se efectúa mediante la determinación de actos constitucionales, que solo en ciertas ocasiones y ciertos extremos se encuentran sometidos a la ley, aunque se diferencian de esta por la función que

[113] *Ibid.* P141.
[114] *Ibidem.*

les es encomendada, que no tiene nada que ver con la función normativa propia de la ley, pese a ser generales. En definitiva, de la mano de Ortiz y, a su vez, de Marienhoff, puede asegurarse que:

> *"Es la conclusión definitiva a que cabe arribar: el Acto de Gobierno concebido como el acto constitucional, o institucional no desaparecerá. "El Acto de Gobierno, ha dicho Forsthoff, como tal no perderá su importancia en el futuro. Las tendencias, hoy muy fuertes, de poner al Estado en la medida de lo posible bajo el control de los tribunales tendrán que rendirse ante este hecho" (MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, pág. 686)."*[115]

No es admisible, por ninguna razón, que una especie concreta del Acto Administrativo esté absuelta en su totalidad de ser revisada por un contralor jurisdiccional. Los principios más elementales del derecho público serían violentados bajo tal tesis. La mera concepción histórica del Acto de Gobierno, que aun actualmente persiste en no pocos ordenamientos, no puede tener cabida en un orden garantista, es decir, en un Estado Social de Derecho. Contradicciones de orden constitucional, legal y doctrinario se evidencian cuando se busca perpetuar el concepto clásico del Acto de Gobierno en el ordenamiento jurídico costarricense. La forma y los parámetros según los cuales deben ser controlados los actos, que tradicionalmente se han señalado como de Gobierno, será el tema de desarrollo de los siguientes títulos.

[115] *Ibid.* P142.

Título II: Control jurisdiccional de los Actos Administrativos

Contenido

Capítulo 1. Evolución de la jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda

Sección Primera: Origen en el Derecho francés

Sección Segunda: Desarrollo histórico en Costa Rica

Capítulo 2. Control jurisdiccional de los Actos Administrativos

Sección Primera: Principios rectores

Sección Segunda: Mecanismos de control en la normativa costarricense

Sección Tercera: Límites del control jurisdiccional

Capítulo 1. Evolución de la jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda

Sección Primera: Origen en el Derecho francés

En el primer capítulo y primera sección de esta investigación se trazó un desarrollo histórico de la figura del Acto de Gobierno, desde sus orígenes en el Consejo de Estado francés y, de manera subsiguiente (en acápites posteriores) hasta su actualidad en el derecho costarricense. Tal y como se dejó constatado en tal sección, el bagaje histórico de la jurisdicción contenciosa, como tema específico, sería desarrollado en este título segundo, siendo imperativo retomar algunas premisas ya expuestas, en aras de mantener el hilo argumentativo, sin caer por ello en reiteraciones o tautologías.

El primer punto importante que se debe retomar, como conector para entrar en la presente sección, es que, hasta las posteridades de la Revolución francesa, los gobiernos europeos eran monarquías absolutistas. Si bien habían entregado mucho de su poder legislativo a cortes y parlamentos de diversa índole que llevaban siglos funcionando, no estaban sujetos a ningún contralor de legalidad. Pese a que el legalismo propiciado por los intelectuales y filósofos ilustrados (Montesquieu, Rousseau, Locke, entre otros) ya se había arraigado en la conciencia y hasta en algunas manifestaciones normativas de Europa, no se había desarrollado una autoridad judicial o de especie similar, con potestades suficientes para controlar el funcionamiento del aparato Estatal.

Controlar el funcionamiento del aparato estatal (más acertadamente, de las Administraciones Públicas), mediante la implementación de un sistema procesal específico y especializado, es lo que se entiende como derecho procesal contencioso. Resulta evidente, que para llegar a tal hito hace falta retomar una serie de premisas, que a su vez fueron condición de posibilidad para la generación de tal sistema procesal específico y, con ello, el control judicial de la Administración Pública.

Por lo recientemente expuesto, antes de cualquier análisis (histórico o de cualquier otro tipo) de la justicia contenciosa administrativa, se debe entender quién es el sujeto pasivo de dicho control para determinar los alcances y preceptos fundamentales de tal dinámica contralora. Con motivo de lo planteado, se debe coincidir con lo señalado por Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, siendo que, en su acepción más básica, el derecho administrativo es el Derecho de la Administración Pública. Se tiene que:

> *"la primera y fundamental pregunta a resolver es qué cosa sea la Administración Pública para el Derecho Administrativo."*[116]

Si la Administración Pública será el objeto pasivo del contralor de legalidad, se debe situar la generación de tal concepto como el inicio y la condición necesaria de cualquier noción de control jurisdiccional. Es la Administración Pública, sin duda, un sujeto de derecho, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pasivo y activo de acciones (no únicamente) jurisdiccionales. Esta personificación de la Administración Pública no solamente es el hito fundador del derecho administrativo en el siglo XIX, sino también el cimiento del control desarrollado ante las manifestaciones de voluntad de esta persona (actos administrativos). Retomando lo que se viene desarrollando:

> *"A partir de la Revolución francesa, momento en el que nace del Derecho Administrativo, y durante la primera mitad del siglo pasado, la Administración Pública se identifica con el Poder Ejecutivo, en el marco constitucional del principio de división de poderes. El derecho Administrativo venía a ser entonces el régimen jurídico especial del Poder Ejecutivo."*[117]

Ese paso final, hacia la personificación de la Administración Pública (en un inicio, únicamente en la figura del Ejecutivo), se efectúa a partir de la importación del concepto de la persona jurídica, desarrollado por la pandectística alemana:

> *"Hacia mediados del siglo XIX, los esfuerzos dirigidos a garantizar la autonomía del nuevo Derecho Público, con la necesidad de abandonar las explicaciones personalistas y*

[116] García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás Ramón. *Curso de Derecho Administrativo.* España: Civitas. 1980. P21.

[117] *Ibid.* P22.

místicas del feudalismo y el absolutismo, cristalizan en Alemania en una aportación capital sin duda tomada en préstamo del pandectismo iusprivatista: el reconocimiento del Estado como persona jurídica (ALBRECHT, GERBER; LABAND, JELLINEK). El Estado sería, ante todo, una persona jurídica, y esta constatación elemental permite iniciar, justificar y sostener la magna construcción de su comportamiento ante el Derecho. La personificación jurídica del Estado se erige así –dice GERBER- en el presupuesto de toda construcción jurídica del Derecho Público."[118]

Este elemento específico al que se viene haciendo referencia, es decir, la personificación del Estado (posteriormente de las Administraciones Públicas), es la génesis de la pasividad de la Administración para ser sujeto de escrutinio jurisdiccional. Esta posición yace por encima de los intentos de objetivizar al Estado, ya sea de forma funcional o material. Las insistencias en relación con ese punto de distintas escuelas *ius* publicistas a través de la historia, han terminado inevitablemente en el fracaso.

"Las funciones y actividades a realizar por la Administración son algo puramente contingente e históricamente variable, que depende esencialmente de una demanda social, distinta para cada órbita cultura y diferente también en función del contexto socioeconómico en el que se produce".[119]

De previo a tal concepto de Administración Pública, sí que hubo en Europa intentos de controlar a quien detentaba el poder de imperio (el monarca), pese a que ello no será objeto de análisis del presente acápite (por exceder las pretensiones de explicación histórica del presente proyecto) es importante destacar que, anterior a la concepción del Estado como un ente jurídico ficticio (persona jurídica), así como el establecimiento de fueros de control, la dinámica era absolutista por completo:

"El sistema de relaciones entre la Administración y la Justicia, que ha quedado sumariamente expuesto, hunde sus raíces en el Antiguo Régimen. Cuando el Monarca actúa en los asuntos administrativos no necesita, en efecto, el respaldo de los Tribunales

[118] *Ibidem.*
[119] *Ibid.* P23.

y éstos a su vez no tienen frente a los órganos administrativos estrictos el mismo poder directo que frente a los súbditos.[120]

Tribunales de justicia existieron desde muchos siglos antes del surgimiento del derecho administrativo, incluso desde la antigüedad (por ejemplo, en la Roma republicana), no obstante, como se puede derivar de la cita recién transcrita, en la Europa monárquica previa a la Revolución francesa, tales Tribunales no tenían fuero sobre el monarca (con la excepción, quizá, del caso anglosajón, que no se abordará por resultar ajeno a nuestro sistema de derecho). Es así que:

> *"Encontramos, por ello, preceptos explícitos en favor de la ejecutoriedad de los actos administrativos (las cláusulas intimatorias finales de las cédulas o rescriptos lo expresan con fórmulas de imperio: "lo guardéis y cumpláis y ejecutéis", dirigidas a todas las autoridades bajo sanción penal; igualmente las previsiones o cartas de los ´órganos inferiores, que actúan como un poder delegado del Rey."*[121]

Existía una clara confusión entre las funciones estatales, posteriormente divididas en la clásica conformación tripartita, pero para entonces mezcladas en la figura de una sola autoridad, es decir, el monarca:

> *"El fundamento de estas reglas parece obvio: Administración y Justicia son las dos meras emanaciones de un mismo sujeto, el Monarca; son manifestaciones del mismo poder, con idéntico rango y fuerza. No tendría sentido, por ello, que la Administración regia estuviese sometida a los Tribunales regios como cualquier sujeto particular."*[122]

De lo dicho se extrae la conclusión de que ya no solamente la personificación de la Administración Pública (para entonces, el Ejecutivo y más específicamente el Estado) sea requisito para la revisión jurisdiccional de manifestaciones de poder de imperio. Sino, además, incluso como requisito previo a ello, debe existir una división de poderes que garantice la autonomía de quien imparte justicia, lo que posteriormente se entenderá como poder judicial y, a nivel procesal, tribunales con jurisdicción y competencia.

---

[120] *Ibid.* P410.
[121] *Ibidem.*
[122] *Ibid.* P411.

Como se mencionó someramente, el sistema anglosajón sí que extrajo la labor judicial del monarca, sometiendo a este al imperio de quien judica de manera tajante. Esa aportación capital tuvo una recepción tibia en el constituyente francés post revolucionario, que no recibió la separación de poderes de forma directa, entendiendo, claro, que tal y como se adelantó en secciones anteriores, la transición del poder monárquico al republicano durante la revolución francesa no fue directa ni mucho menos pacífica, en tanto diversos grupos aún defensores (beneficiarios) del régimen monárquico y, con poder suficiente para ello, opusieron férrea resistencia a dicha transición que, posteriormente y de manera inevitable, se terminaría completando. En atención a lo expuesto, la implantación de una separación de poderes clara, más específicamente (para el tema que nos ocupa) una separación del aparato judicial capaz de enjuiciar las actuaciones del Ejecutivo, fue un proceso gradual en la Francia post revolucionaria.

> *"En efecto, en el momento en que la Revolución francesa impuso la adopción del principio de división de los poderes, confesadamente tomada del modelo inglés, pudo parecer que la opción implicaba un abandono de las técnicas a que había llegado en su última fase la Administración absolutista del Antiguo Régimen, que ya hemos descrito, y que implicaban una autosuficiencia de la gestión cumplida por los Agentes públicos no necesitada de asistencia del juez, aun operando directamente sobre las libertades de los súbditos, e incluso eximida de la fiscalización de los Tribunales, la cual se suple por un sistema de recursos puramente gubernativos."*[123]

Como es común en el derecho, particularmente en el derecho público (que es el derecho de las administraciones públicas), las interpretaciones de los no escasos conceptos jurídicos indeterminados obedecen en muchas ocasiones a factores de poder y no a mecanismos interpretativos científicos. En la conformación de la Francia post revolucionaria es evidente la timidez con la que los constituyentes abarcaron el tema del control estatal, claro está, también es entendible en tanto se venían nuevos imperios y monarquías, hasta la consolidación de una República Democrática en los términos que la entendemos actualmente, ya bien adelantado el siglo XIX. Los agentes encargados de ordenar la legalidad y constitucionalidad, es decir, el esquema normativo de la nueva república, no podía darse el lujo de efectuar intromisiones directas y tajantes en el accionar de quien ejercía la labor ejecutiva, ora por no contrariar la figura del caudillo al

[123] *Ibid.* Pp 419-420.

mando (Napoleón), los breves resurgimientos monárquicos posteriores (como el de los Borbones) e incluso porque la propia burguesía u otros agentes de la sociedad no aceptarían tal intromisión democratizante, entendiendo que quien ostentara el poder ejecutivo debía conservar ciertos rasgos de ejercicio de poder, ahora podría decirse despóticos. Por todo lo dicho, tuvo lugar una interpretación de la división de poderes, tendiente a preservar la imposibilidad de interferir vía judicial el accionar del poder Ejecutivo:

> *"En primer término, fue determinante el famoso principio de "separación" entre Administración y Justicia, que es la interpretación "heterodoxa" con que la Asamblea Constituyente recibió el principio de división de los poderes. Este implicaba para los jueces la mera independencia del Ejecutivo, sobre la cual justamente en el modelo inglés originario, puede los jueces afirmar su competencia general sobre los agentes de este último poder, que no personifican nada que esté por encima de los otros poderes, sino sólo la ejecución de previsiones legales explícitas según hemos visto. La Asamblea, sin embargo, interpretó la "separación" en el sentido de que quedaba vedado a los jueces interferir en absoluto el funcionamiento de la Administración, en una palabra, enjuiciarla."*[124]

Entonces, pese a que la Revolución de alguna manera destronó el viejo régimen, por completo monárquico y absolutista, mantuvo la premisa de que quienes ejercían la labor jurisdiccional no podrían en principio entrometerse, controlar o fiscalizar a quien ostentara la función ejecutiva y, por tanto, el despliegue de las potestades de imperio:

> *"La Ley de 16-24 de agosto de 1790 (que tiene antecedentes en otra de 22 de diciembre de 1789) dispuso, en efecto: "Las funciones judiciales son y han de permanecer siempre separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de prevaricación, perturbar de cualquier manera (troubler de quelque maniére que ce soit) las operaciones de los cuerpos administrativos, ni emplazar ante ellos a los administrados por razón de sus funciones."*[125]

[124] *Ibidem.*
[125] *Ibidem.*

Ahora bien, pueden señalarse varios motivos coyunturales que llevaron a los artífices de la Francia post revolucionaria a negar el ejercicio pleno de la autoridad jurisdiccional sobre las acciones del Ejecutivo, dentro de las que se pueden destacar: una afinidad particularmente intensa con los parlamentos y cortes, por ser estos los precursores y de alguna forma responsables reales de la Revolución, a partir de la cual se entendió que eran estos, y no los tribunales, los encargados de democratizar el poder mediante la emisión de leyes en demérito del accionar judicial; una mala experiencia con lo que se conoció como gobierno de los jueces, en tanto los tribunales de justicia franceses se habían comportado en no pocas ocasiones con más sadismo y despotismo que el propio monarca. Este último elemento impregnó de un recelo general de los constituyentes hacia los tribunales de justicia, que contribuyó de manera determinante a empotrar la labor de controlar el accionar del Ejecutivo dentro de la propia Administración (lo que posteriormente generaría el Consejo de Estado). Los condicionamientos judiciales sobre el poder ejecutivo eran vistos más bien con malos ojos, en tanto el resultado de dicha práctica en la experiencia reciente de los franceses era catastrófica, en definitiva dirigida a reafirmar el poder nobiliario y no el común.

> *"Pero independientemente de ese principio básico de separación, aunque corroborando su misma dirección y sobre los mismos motivos de fondo, frente a un intento prematuro de crear una verdadera jurisdicción especializada en asuntos administrativos (Tribunal d´administration, proyecto THOURET, 1789), el criterio contrario a las jurisdicciones especiales, la conciencia de la ineptitud en la materia administrativa de los Tribunales ordinarios, y, en último término, los argumentos de que la Administración democrática se legitima en el pueblo (lo que lo haría tan independiente e imparcial como los jueces, también elegidos) y que la misma puede actuar avec dégagement de tout appareil de chicane (enmienda PEZOUS: "Con independencia de todo aparato leguyelesco"), concluyen por remitir a la propia Administración activa la decisión de las diferencias que frente a ella misma suscitasen los ciudadanos, lo que se anuncia ya formalmente desde la Ley de 7-11 de septiembre de 1799 en material local, seguida por otra serie de Leyes inmediatas en asuntos de la Administración Central."*[126]

Hasta el último tercio del siglo XIX, podría decirse a raíz de este desarrollo de García Enterría, se mantiene el principio de que juzgar a la Administración sigue siendo administrar. En razón de lo

[126] *Ibid.* P 421.

cual, el sistema posteriormente denominado como contencioso administrativo sería delegado en órganos ciertamente administrativos, como lo será el Consejo de Estado.

> *"La consideración del contencioso-administrativo no como un control jurisdiccional, sino como un autocontrol administrativo, unido al básico principio de separación entre Administración y Justicia, con la prohibición a ésta de trouble de las autónomas operaciones administrativas, configuran y sancionan los formidables privilegios que a la Administración como persona se le reconocen por comparación con los demás sujetos en cuanto a su posición con los Tribunales."*[127]

De todas formas, será inevitable en Francia la conformación de una jurisdicción especializada y en alguna medida autónoma con respecto a la Administración activa. Pese a ello, los vestigios de absolutismo y de los enormes privilegios concedidos a la Administración (como persona de derecho) no desaparecerán por completo del actuar del Consejo de Estado. Avanzado el siglo XIX, se empieza a vislumbrar la permanencia de una relación desequilibrada entre el control del actuar de la Administración por parte de los Tribunales, respecto del que se realiza a los particulares, nota diferenciadora de dicha jurisdicción.

> *"Estos privilegios se perfilarán más tarde al final del siglo XIX, cuando se produce una verdadera jurisdiccionalización de los órganos encargados de conocer lso recursos contencioso-administrativos (sistema de la "jurisdicción delegada", o de separación entre jurisdicción administrativa y Administración activa, en Francia; encuadramiento de dichos órganos dentro del poder judicial en otros países)."*[128]

Existe entonces un giro (una mejoría, se diría) en la concepción de esta jurisdicción, en el tanto:

> *"Juzgar a la Administración no se considerará ya una pertenencia de la misma función de administrar, sino el contenido de una verdadera jurisdicción"*[129]

[127] *Ibid.* P422.
[128] *Ibidem.*
[129] *Ibidem.*

No obstante, tal y como se mencionó recientemente, se mantendrían los vestigios favorables a la Administración Pública en la dinámica del control jurisdiccional:

> *"la inserción de esta jurisdicción en el comportamiento del sujeto Administración habrá quedado fijada por la experiencia precedente: la jurisdicción contencioso-administrativa no tendrá en absoluto sobre la Administración los poderes comunes de los Tribunales sobre los sujetos sometidos a ellos, sino que se limitará al enjuiciamiento ex post de las actuaciones administrativas, las cuales pueden producirse por propia autoridad, sin la previa declaración judicial de pertenencia, tanto en el ámbito declarativo como en el ejecutivo, y ese enjuiciamiento a posteriori habrá quedado configurado sobre la técnica impugnatoria analítica de actos o de Reglamentos, que, además, no suspende la ejecución de los mismos. En el ámbito de esa actuación administrativa autónoma, o no necesitada de Tribunales, éstos continuarán teniendo vedado penetrar y perturbar de cualquier manera su funcionamiento, en servicio de lo cual el sistema de conflictos que permite paralizar las injerencias judiciales prohibidas, sigue funcionando eficazmente."*[130]

Es entonces, a partir de la Ley 16-24 de 1790, que nace el modelo de justicia retenida, es decir, la interpretación de la división de poderes de forma estricta (a diferencia de la originalmente planteada por Montesquieu y en el modelo anglosajón), que no permitía a los jueces controlar el accionar de la Administración, sino solamente a un órgano de la propia Administración, el Consejo de Estado adscrito dentro de esta.

> *"Los dirigentes revolucionarios desconfiaban de un Poder Judicial independiente, ya que históricamente los tribunales habían constituido un reducto de la aristocracia en los años inmediatamente anteriores a la Revolución habían llegado a obstaculizar la aplicación de reformas económicas y sociales imprescindibles, acordadas por los Ministros del Rey. En consecuencia interpretaron la división de poderes no como un sistema de equilibrios de poder y controles recíprocos, tal y como lo había teorizado Montesquieu sobre la base del sistema constitucional inglés, sino como estricta separación de poderes. De ahí que mediante leyes de 16 y 24 de agosto de 1790 prohibieran terminantemente a los jueces*

[130] *Ibidem.*

inmiscuirse en las actividades administrativas y enjuiciar o controlar a los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones."[131]

Tal y como se puede prever, la interpretación efectuada por los constituyentes franceses y finalmente plasmada en la, ya mencionada, Ley de 1790, dejaba mucho que desear en tanto a un control plenario de la Administración, que garantizase la prevalencia de los derechos del ciudadano de cara al control del accionar del aparato público. Dicho vacío se fue solventando de manera gradual, en una transición pronunciada hacia la justicia delegada, es decir, hacia una más externa y plenaria, que permitiera a terceros imparciales, y sobre todo independientes de la propia administración, controlar la prevalencia de la legalidad, como principio vector del nuevo derecho administrativo, en demérito de las posiciones absolutistas del antiguo régimen. La solución para resolver esa precaria seguridad jurídica, otorgada por el modelo de justicia retenida:

"consistió en un recurso jerárquico que el ciudadano perjudicado podía formular ante el superior del funcionario que había adoptado la decisión que considerase ilegal, recursos que en última instancia resolvía el Ministro (el Ministro-Juez, según la expresión de la época) o el Gobierno. La Constitución del año VIII atribuyó definitivamente la tramitación de los recursos a un órgano especializado, el Consejo de Estado, compuesto de altos funcionarios y que ejercía también funciones consultivas del Gobierno."[132]

Véase que la propia génesis del Consejo de Estado francés estuvo claramente impregnada por esta reticencia del constituyente francés de otorgar poderes de verdadero control a los Tribunales jurisdiccionales. El ideólogo del nuevo modelo republicano optó por empotrar el nuevo contralor de legalidad dentro de la propia Administración, hecho que de alguna manera se mantiene hasta la actualidad. Se debe mencionar para este punto que, luego de la conformación inicial del Consejo

[131] Sánchez Morón, M. Derecho Administrativo Parte General. España: Tecnos. 2006. P48.

[132] *Ibid.* P49.

de Estado, se dio una regionalización de la justicia administrativa, mediante la conformación de órganos con conscripción territorial:

> *"Después se atribuyó la misma función en cada Departamento a unos Consejos de Prefectura (hoy ya sustituidos por los Tribunales Administrativos Regionales y por los Tribunales de Apelación), de semejante composición."*[133]

Para este punto resulta necesario delinear el funcionamiento de estos nuevos tribunales, encargados de ejercer la labor de control sobre la Administración activa, en aras de hacer prevalecer el llamado imperio de la ley. Lo anterior, dado que los mismos no operaban de la manera en que ahora se entiende un contralor de legalidad, es decir con potestades anulatorias, declarativas, entre otras, que le permiten ejercer su función de manera directa, modificando e incluso (en casos calificados) supliendo la labor de la Administración, que emitiese actos contrarios a la legalidad. Sobre ello:

> *"Inicialmente sus resoluciones no tenían por sí mismas fuerza decisoria sino de propuestas no vinculantes a los órganos de Gobierno (sistema de justicia retenida).*[134]

No obstante, este sistema de justicia retenida fue mutando posteriormente, por ser contrario a las ambiciones garantistas (mediante el ejercicio del control plenario del accionar administrativo) que se fue perfilando posteriormente en Francia. En las décadas posteriores a la caída del Imperio y durante la Tercera República, tuvo lugar un cambio de paradigma hacia un nuevo sistema, uno que hasta el día de hoy se mantiene y que fue conocido como de justicia delegada:

> *"Pero a partir de 1872, consolidado al régimen democrático de la III República, los arrets del Consejo de Estado y demás órganos de la denominada jurisdicción administrativa francesa tienen eficacia directa, semejante a la de una sentencia (sistema de justicia delegada). No solo eso, sino que, por tradición más que por ley, los funcionarios que ejercen esa jurisdicción (el juge administratif) suman a su especialización en Derecho administrativo una independencia de criterio escrupulosamente respetada."*[135]

A raíz de esta innovación se da un fenómeno que resulta curioso. Tal y como se adelantó, en la Francia post revolucionaria imperó un escepticismo generalizado sobre la posibilidad de que los

---

[133] *Ibidem.*
[134] *Ibidem.*
[135] *Ibidem.*

jueces pudiesen controlar de manera directa el accionar de la Administración, dada la histórica vinculación de estos con el poder nobiliario. A raíz de ello, se dio el hecho de que un órgano de la propia Administración, conformado además por magistrados de alta reputación y capacitación en derecho, fue visto con optimismo y sin mayor recelo. Fue así que los fallos del Consejo de Estado adquirieron una reputación de alta valía y no fueron atacados de manera agresiva, en tanto era la propia Administración moldeando su accionar. Es entonces que la conjunción de esas circunstancias coyunturales le permitió al Consejo de Estado, a través de su jurisprudencia, generar los principios, conceptos y técnicas que sirvieron para elaborar el andamiaje de todo un sistema de Derecho administrativo novedoso y, se podría decir, en términos relativos a la época, osado.

> *"Ese sistema de Derecho administrativo se fue elaborando poco a poco y en buena medida sobre la base de la adaptación al Derecho público de las instituciones de Derecho privado: los derechos reales, los contratos, la responsabilidad extracontractual… En realidad sólo a finales del siglo IXI aparece como un sistema jurídico maduro y así se refleja en la obra de los tratadistas franceses de la época (LAFERRIERE, M. HAURIOU, BERTHÉLEMY, entre ellos)."*[136]

[136] *Ibidem.*

Sección Segunda: Desarrollo histórico en Costa Rica

La primera ley que intentó regular una jurisdicción especializada para el control contencioso administrativo en Costa Rica tuvo lugar hasta el año 1950, a raíz de la reforma constitucional ocurrida en 1949. Pese a lo dicho, existen antecedentes dignos de mención, aunque de raigambre constitucional, con preceptos que de alguna forma tendían a mencionar esta materia.

> *"Interesa acotar, en ese sentido, que el primer antecedente en esta materia, en nuestra historia constitucional, se encuentra en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica de 1844. En su artículo 154, la Constitución de 1844, señaló como una de las atribuciones de la Corte Plena de la Suprema Corte de Justicia, conocer de "las controversias que se susciten por los contratos o negociaciones interesantes al Estado, y Ministros del Despacho cuando haya lugar a ellas".*[137]

Es importante mencionar, a raíz de este primer hito, que desde el antecedente inicial que existe de control de la Administración por parte de los Tribunales de Justicia en nuestro país, se implementó el ya explicado sistema de justicia delegada, en contraposición al de justicia retenida, también explicado. Es decir, se delegó en un órgano jurisdiccional, ajeno y externo a la Administración, el control de dichos actos, aunque en este primer momento solamente se incluyeran contratos o negociaciones. La Corte Suprema de Justicia fue la encargada de revisar estas conductas específicas, aunque la primera mención de una jurisdicción contenciosa administrativa tuvo lugar muchas décadas después, en tanto:

> *"No es, sin embargo, hasta la Constitución de 1917, que en el artículo 109, se alude de forma expresa a una "Jurisdicción Contencioso Administrativa", al señalarse lo siguiente: "El Congreso queda autorizado para organizar la Jurisdicción Contencioso-Administrativa"*[138]

Ciertamente, la aplicación de estas disposiciones no fue frecuente, en gran medida debido al inexistente desarrollo legislativo que hubo respecto de ello. En ausencia de una ley que se

[137] Milano, Aldo. Evolución de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Costa Rica, Estudio retrospectivo. Costa Rica: Cejamericas. 2005. P3.
[138] *Ibidem.*

encargara de poner en práctica las disposiciones constitucionales mencionadas, el control jurisdiccional de la Administración fue prácticamente inexistente durante estas etapas iniciales.

> *"Como es sabido, estas disposiciones constitucionales tuvieron un escuálido desarrollo legislativo y muy escasa aplicación práctica. En todo caso, tal y como se vio, las menciones se dieron, a nivel constitucional, únicamente a partir de disposiciones alusivas a la competencia del Poder Judicial y no configuraron por ello, en estricto sentido, una garantía individual del ciudadano."*[139]

Realmente, el verdadero hito a partir del cual se generó una jurisdicción contenciosa administrativa, encargada de controlar de manera directa y por disposición expresa el accionar de la Administración Pública en Costa Rica, no tuvo lugar sino hasta la reforma post Guerra Civil en 1949, en cuyo texto original estableció:

> *"Establécese la jurisdicción contencioso administrativa como función del Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de sus derechos administrativos, cuando éstos fueren lesionados por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda institución autónoma o semiautónoma del Estado, actuando como personas de derecho público y en uso de facultades regladas."*

Véase que, si bien no se puede demeritar de ninguna manera, el grandísimo avance que supuso la implantación de este artículo, que significó a su vez el inicio de la jurisdicción contenciosa administrativa en Costa Rica, dicho artículo presentó sendos problemas, de cara a una justicia administrativa plenaria y actual (en relación, como no podría ser de otra forma, con la época). Si bien se genera la jurisdicción especializada, adscrita al poder judicial, en atención al principio de justicia delegada, se hace una reducción innecesaria y torpe de los sujetos pasivos de dicha jurisdicción, así como una alusión específicamente a las facultades regladas, que dejaba por fuera buena parte del accionar de la Administración en el umbral de la impunidad.

Se debe decir que en 1950 y, a raíz de la promulgación de la Ley número 1226 de ese año, se realizó algún desarrollo legislativo de la norma constitucional recién expuesta, aunque se debe adelantar que dicha norma fue sumamente laxa y, para entonces, en la legislación nacional se

[139] *Ibidem.*

carecía de otras leyes complementarias que se encargaran de desarrollar de manera más completa la materia.

> *"Antes de comenzar, debe quedar claro, que esta normativa era la única que regulaba la materia, no existía ninguna otra ley que desarrollara teorías de la Administración Pública, de sus actos, de su invalidez, entre otras cosas (solamente la jurisprudencia que surgiría a raíz de esta ley, y la jurisprudencia generada a raíz de aplicaciones de decretos y otras leyes."*[140]

Dicha Ley de 1950 contenía únicamente 11 artículos y, para efectos de la instrucción de los procedimientos, remitía al código de procedimientos civiles, por lo que no se puede hablar para entonces de una verdadera jurisdicción especializada, que contemplara los principios propios de la justicia administrativa aplicados a un procedimiento específico. Se hizo un desarrollo del artículo constitucional recién introducido el año anterior, únicamente en tanto transcribir los errores y carencias del mismo, para ello véase el artículo primero de la Ley 1226, que es una transcripción del artículo 49 constitucional. A su vez, el artículo 3 (relativo a la legitimación) estableció:

> *"Artículo 3.- La demanda contencioso-administrativa podrá interponerla toda persona cuyos derechos administrativos hubieren sido lesionados en los términos que indica el artículo primero, inclusive el Estado, las municipalidades e instituciones públicas autónomas o semi-autónomas."*

[140] Calvo García Jorge Iván. Régimen de nulidades en la legislación administrativa costarricense. Análisis a la luz del nuevo código procesal contencioso administrativo. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2009. Pp 111-112.

En el artículo 2 de dicha Ley se efectuó una exclusión de diferentes parcelas del accionar administrativo, que quedaban fuera del contralor jurisdiccional de legalidad, ello se constata en tanto dicho artículo estableció:

> *Artículo 2º.- Como consecuencia de los dispuesto (sic) en el artículo anterior, no serán materia del juicio contencioso-administrativo:*
>
> *a) Las disposiciones de carácter general que dicte la Administración Pública en ejercicio de sus facultades discrecionales, sin sujeción a leyes, reglamentos u otro precepto administrativo, a los cuales deba acomodar sus actos. Sin embargo, cabrá el recurso contra las resoluciones que se tomaren como consecuencia de una disposición de carácter general emanada de la potestad discrecional, si con ella se lesionaran derechos particulares establecidos por una ley o reglamento u otro precepto administrativo; y*
>
> *b) Las cuestiones de índole puramente civil o criminal, las cuales pertenecen a la jurisdicción ordinaria. Se considerarán de orden civil, para los efectos de este artículo, las cuestiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil y también aquellas que emanen de actos en que los organismos que indica el artículo primero hubieren obrado como persona jurídica, o sea como sujetos de derechos y obligaciones.*

Se estableció, además, en el artículo 4 de dicha Ley, un agotamiento preceptivo de la vía administrativa, previo a accionar en la vía contenciosa administrativa. El plazo de prescripción para la reclamación de un derecho en esta vía se estableció en un año, a través del artículo quinto de esta Ley. Por último, tal y como ya se adelantó, en los artículos restantes, para el trámite del procedimiento, reflejado en los actos de interposición de la demanda, contestación, entre otros, se remitió en su totalidad a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles vigente a la fecha.

Posterior a la promulgación de dicha Ley, el siguiente cambio de paradigma en la organización de la jurisdicción contenciosa administrativa en Costa Rica ocurrió a partir de la reforma al artículo 49 constitucional, que tuvo lugar mediante Ley No. 3124 de 21 de junio de 1963. Dicha reforma, aún vigente al día de hoy, introdujo varias modificaciones determinantes a la norma, con lo que se logró ampliar la competencia de la jurisdicción y con ello el objeto del proceso.

"Así, en su exposición de motivos, la iniciativa de reforma promovida por diez diputados estima, en alusión al texto original del artículo en comentario, que "El artículo 49 de la Constitución Política impide la promulgación de una ley eficiente sobre el juicio contencioso administrativo. En primer lugar, hace referencia sólo a la actividad del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas, olvidando que los otros Poderes ejercen a veces función administrativa, que debe también ser controlada en la vía del referido juicio. Después, únicamente extiende la protección jurisdiccional a los derechos subjetivos de los administrados, cuando es necesario llevarla también a los intereses, al menos los legítimos. Y, por último, limita el control al "uso de facultades discrecionales"; distinción ésta que hoy día es inaceptable a los efectos de la admisibilidad del juicio respectivo, ya que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa constituye igualmente actividad sometida a la ley." Más adelante, se señala, en relación con el control de la discrecionalidad administrativa, lo siguiente: "...al hacer uso de esa discrecionalidad puede incurrir la Administración en defectos o vicios de forma, de procedimiento o de desviación de poder, que ineludiblemente deben estar sometidos al control jurisdiccional, para que la justicia administrativa sea lo que debe ser en un Estado de Derecho como el nuestro."[141]

Para los inicios de la segunda mitad del siglo XX, el legislador costarricense empezaba a aceptar las concepciones más garantistas de la justicia administrativa, hacia lo cual se iría perfilando el derecho procesal contencioso administrativo en las siguientes décadas de dicho siglo. Esta tendencia también se afirmó dentro de la propia comisión del para entonces proyecto de ley descrito.

"En su dictamen unánime afirmativo, la Comisión hace una serie importante de afirmaciones, que ahora se procede a transcribir: "Por imperativo de los nuevos conceptos doctrinarios, ha sido rebasado ese marco jurídico con otros planteamientos que

[141] Milano, Aldo. Evolución de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Costa Rica, Estudio retrospectivo. Costa Rica: Cejamericas. 2005. P5.

ha reelaborado la secuencia jurídica, apuntándose hacia más generales y amplios senderos de protección para los administrados."[142]

Esta reforma capital, de acuerdo con lo planteado en el dictamen de la comisión aludido, dio pie a cuatro cambios de capital importancia para la jurisdicción contenciosa administrativa. Se sustituyó la expresión Poder Ejecutivo por Estado, lo cual a todas luces amplió el ámbito de control a los demás poderes de la República, en el tanto ejercieran función administrativa. Se instauró la protección de los intereses legítimos, adicionalmente a la de los derechos subjetivos ya contemplada. Como tercer punto tuvo lugar:

> *"La eliminación de la expresión "en uso de facultades regladas", con lo cual se amplió el control al ejercicio de potestades discrecionales. Se estimó, por parte de la Comisión especial, lo siguiente: "Se afirma, según las modernas corrientes del pensamiento doctrinario, que toda la actividad del estado es reglada, por cuanto cualquier acto tiene al menos su fin reglado y que lo que existe es discrecionalidad administrativa, en la que se actúa en diversos sentidos, porque la ley señala un concepto facultativo. Esos supuestos que otorgan al órgano administrador provienen de expresa disposición jurídica y no de una libre actividad, sobre o fuera de la concepción legalista; además, determinar los límites de la discrecionalidad en la actuación administrativa, es cuestión de fondo, de procedencia y no de admisibilidad del reclamo, como erróneamente está hoy día establecido en Costa Rica. En concordancia con lo expuesto, se afirma que en todo acto, por más reglado que sea, existe un poder discrecional de mayor o menor grado; y que todos los actos dictados en uso de la discrecionalidad, por más libres que se supongan, derivan de una actividad más o menos reglada"*[143]

Por último, tuvo lugar la inclusión de forma expresa del concepto de desviación de poder, como uno de los motivos que podían generar la revisión de los actos de la Administración. Lo cual devino en una inclusión de enorme importancia que se mantuvo hasta el día de hoy, además de haber sido incluido también en las legislaciones posteriores a la reforma que se encargaron de delimitar de manera específica la jurisdicción contenciosa administrativa.

---

[142] *Ibid.* P7.
[143] *Ibid.* P8.

Posterior a la reforma constitucional del año 1963, se promulgó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en el año 1966, con lo que no solamente se derogó la anterior y deficiente Ley 1226, sino que además se establecieron los cimientos de lo que sería la jurisdicción contenciosa administrativa, en buena medida hasta el día de hoy. La Ley Reguladora de 1966 es el hito a partir del cual se instaura en Costa Rica una verdadera jurisdicción contenciosa administrativa, que estuviera acorde con buena parte de los parámetros doctrinales y normativos de la vanguardia del derecho continental europeo de entonces. Siendo que la anterior Ley 1226 era tremendamente deficiente y apenas si regulaba de manera somera y equívoca la jurisdicción contenciosa costarricense, con la Ley Reguladora se articuló, prácticamente desde cero, esta jurisdicción, por lo cual se introdujo una cantidad tan gran de cambios y modificaciones que resulta imposible mencionar en este acápite, no obstante, se recapitulan algunos de los más importantes.

Desde su primer artículo, la Ley Reguladora marca la pauta con respecto de su antecesora, haciendo una clara y amplia exposición de sus fines, así como un desarrollo acorde con la reciente reforma al artículo 49 constitucional mencionado. Se detalla la naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción contenciosa administrativa, de forma tal que se amplía de manera enorme los alcances de la justicia administrativa, llevando al contralor jurisdiccional de legalidad a prácticamente todos los rincones del accionar administrativo y delimitando de manera amplia los márgenes dentro de los que desarrollará tal control, exponiendo incluso los sujetos pasivos de este:

> *"Artículo 1º.- 1. Por la presente ley se regula la Jurisdicción contencioso-administrativa establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo.*
>
> *2. Los motivos de ilegalidad comprenderán cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, y la desviación de poder.*
>
> *3. Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley.*

4. Para los efectos del párrafo 1º se entenderá por Administración Pública:
a) El Poder Ejecutivo;
b) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuantorealizan, excepcionalmente, función administrativa; y

c) Las municipalidades, instituciones autónomas y todas las demás entidades de Derecho Público."

Se incluyen, además, en el artículo 2 de esta Ley, las cuestiones relativas a la contratación administrativa, así como la responsabilidad patrimonial del Estado, con lo que se hace además una inclusión de la vía Civil de Hacienda. Tal y como se adelantó previamente, dado que la regulación existente en la norma antecedente a la Ley Reguladora era prácticamente inexistente e inútil, es decir, la Ley 1226, sería imposible detallar todos los cambios y avances introducidos por la Ley Reguladora, dado que fue pionera en prácticamente todos los aspectos que contempla. Se introdujo un proceso de conocimiento articulado, mediante la regulación amplia de las partes, a través de los presupuestos básicos relativos a ello, como lo es la capacidad procesal, para lo cual se determinó:

"Artículo 9º.- Tendrán capacidad procesal, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

a) Las personas que la ostenten con arreglo a la legislación civil; y

b) La Contraloría General de la República, para los fines de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 2º, inciso b)."

Además, se instauró la legitimación para personas, a partir únicamente de la existencia de un interés legítimo, pese a que el artículo 10 contempló:

"Si se pretende, además, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, con reparación patrimonial o sin ella, únicamente podrá promover la acción el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto o la disposición impugnados."

Se introdujo un apartado dedicado a las partes, en el que se estableció que, en caso de impugnarse conductas o actuaciones dispuestas por los poderes de la República, naturalmente el legitimado pasivamente era el Estado. También se legitimó pasivamente a las entidades públicas, en tanto dotadas de personalidad jurídica propia. Se introdujo un apartado de intervinientes en el proceso en el que se contempló la figura de la coadyuvancia, más no las tercerías.

Ahora bien, quizá el mayor aporte de la Ley Reguladora fue la articulación de un procedimiento ordinario o de conocimiento pleno y específico de los parámetros propios de la Justicia Administrativa, separándose de la necesaria implementación del procedimiento civil. Una particularidad que resulta digna de mención es el necesario agotamiento de la vía administrativa previsto en el artículo 31 de dicha Ley Reguladora. También merece mención la instauración del proceso de lesividad, previsto en el artículo 35 de dicha Ley.

Tal vez el elemento más importante, que fue casi por completo imprevisto por la Ley Reguladora (con la única excepción de la suspensión de los efectos del acto) es la instauración de un régimen de medidas cautelares amplio. No se regularon las medidas cautelares de forma tal que se facilitara al administrado las herramientas para encontrar, precisamente en la justicia cautelar, los mecanismos que le permitieran evitar daños de difícil o imposible reparación a sus derechos. Dadas las características de ejecutividad y ejecutoriedad de los Actos Administrativos, ya descritas previamente en no pocas ocasiones, la Administración Pública atropella de manera anticipada y mediante coacción dispuesta por sí, los derechos de los ciudadanos, lo cual puede palearse únicamente con un correcto régimen cautelar que permita anticiparse a esta clase de situaciones.

Dos aspectos más resultan dignos de mención, de arranque, la Ley Reguladora estableció una remisión expresa en materia de recursos a la legislación civil, lo que convirtió la casación en materia contenciosa en un recurso sumamente rígido e inaccesible. Por otro lado, ya en la fase de ejecución, se le concedieron pocas herramientas al juez ejecutor para cumplir lo dispuesto en sentencia.

Posterior a la Ley Reguladora, el régimen procesal contencioso administrativo en Costa Rica se mantuvo prácticamente inalterado, hasta la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso

Administrativo en 2008, ahora bien, el examen de la nueva justicia administrativa costarricense con la implementación del CPCA será objeto de análisis en acápites posteriores.

Capítulo 2. Control jurisdiccional de los Actos Administrativos

Sección Primera: Principios rectores

El objetivo de este capítulo es describir de forma concisa el control judicial de los Actos Administrativos en Costa Rica. De cara a describir el derecho procesal contencioso administrativo, se debe iniciar por revisar los principios generales del derecho que orientan dicha materia. Como ya se ha mencionado anteriormente en esta investigación, los principios generales del derecho son, sin lugar a dudas, la base de todo sistema normativo. Contemplan las pautas a partir de las cuales se desarrolla todo el sistema de normas que componen el derecho, demarcan las aspiraciones o la teleología del derecho, en definitiva son la causa final (en términos aristotélicos) del derecho. De todo lo dicho, se entiende que los principios generales del derecho son la fuente primaria de este, así como el método interpretativo más valioso de cara a dotar de algún hermetismo el ordenamiento jurídico.

> *"Los principios generales del Derecho constituyen la base del Ordenamiento, su fundamento mismo. Son fuentes del Derecho; pero, precisamente por su naturaleza, su función no se limita a suplir la insuficiencia de la ley o de la costumbre. Si constituyen la base del Ordenamiento nada más lógico que acudir a ellos en la labor de interpretar cada una de las normas que lo integran. Ellos indicarán en cada momento la fórmula interpretativa que se debe elegir."* [144]

En el tema específico del Acto de Gobierno, tal y como se abarcó en el primer título de esta investigación, resalta como principal característica histórica del instituto su supuesta inimpugnabilidad jurisdiccional, exceptuando con ello el control jurisdiccional plenario del accionar de la Administración Pública. El *quid* de esta investigación se encuentra en explorar dicha inimpugnabilidad, para lo cual los principios generales del derecho resultan un parámetro ineludible de contrastación. En prácticamente todas las discusiones jurídicas subyace en el fondo una presunta contradicción entre principios generales de derecho. Existe una cantidad importante

[144] González Pérez, Jesús. Manual de Derecho Procesal Administrativo. España: Civitas. 1990. P66.

de principios generales del derecho administrativo, relacionados específicamente con el derecho procesal contencioso, no obstante, en la presente investigación se desarrollará de forma primaria el de acceso a la justicia y sus acepciones, empero, no se obviará la mención de otros de enorme importancia, dentro de los que podría destacarse:

> *"Los derechos fundamentales de acceso a la justicia, al juez natural y al debido proceso, deben jugar como auténticos principios jurídicos al interpretar las normas reguladoras del proceso administrativo."*[145]

El principio de acceso a la justicia, a su vez, tiene diversas aplicaciones o alcances que lo conforman:

> *"El principio antiformalista o de interpretación más favorable al derecho de acceso a la Justicia o de in dubio prohabilitate instaciae, comporta la interpretación más restrictiva de cuantas normas supongan un obstáculo al acceso al proceso y, por el contrario, la más extensiva de las que tengan por finalidad facilitar el acceso, la subsanación de los defectos procesales y, en definitiva, el examen de la pretensión en cuanto al fondo."*[146]

Si bien los principios generales que rigen el derecho procesal contencioso son variados, para efectos de la presente investigación conviene centrarse únicamente en los más cercanos a las implicaciones materiales del Acto de Gobierno como instituto jurídico. En ese tanto, un baremo con el cual medir la validez (constitucional y legal) del Acto de Gobierno como instituto se encuentra en el principio constitucional de responsabilidad administrativa. Sobre ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado:

> *"(...)* ***IV.- PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.*** *Nuestra Constitución Política no consagra explícitamente el principio de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por las lesiones antijurídicas que, en el ejercicio de la función administrativa, le causen a los administrados. Empero, este principio se encuentra implícitamente contenido en el Derecho de la Constitución, siendo que puede ser inferido a partir de una interpretación sistemática y contextual de varios preceptos, principios y valores constitucionales. En*

[145] *Ibidem.*
[146] *Ibid.* Pp 66-67.

efecto, el artículo 9°, párrafo 1°, de la Carta Política dispone que "El Gobierno de la República es (...) responsable (...)", con lo cual se da por sentada la responsabilidad del ente público mayor o Estado y sus diversos órganos –Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. El ordinal 11°, de su parte, establece en su párrafo primero la "(...) responsabilidad penal (...)" de los funcionarios públicos y el segundo párrafo nos refiere la "(...) responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes (...)". El artículo 34 de la Constitución Política ampara los "derechos patrimoniales adquiridos" y las "situaciones jurídicas consolidadas", los cuales sólo pueden ser, efectiva y realmente, amparados con un sistema de responsabilidad administrativa de amplio espectro sin zonas inmunes o exentas cuando sean vulnerados por las administraciones públicas en el despliegue de su giro o desempeño público."[147]

Tal y como se puede observar, desde la propia Constitución Política se contempla la obligación de la Administración Pública de hacerse responsable por los daños o perjuicios que pudiese causar a los administrados que no estén en el deber de soportar tal menoscabo. Ello establece un control plenario sobre las posibles conductas de las Administraciones Públicas que pudiesen ir en detrimento de los derechos o intereses de los administrados, para lo cual resulta importante destacar que no se establecen excepciones constitucionales a dicha regla. También otros principios del derecho procesal contencioso complementan lo expuesto hasta el momento sobre el principio de responsabilidad.

(...) El principio de responsabilidad administrativa de los entes públicos y de sus funcionarios resulta complementado con la consagración constitucional del principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas (artículos 18 y 33) que impide imponerles a los administrados una carga o sacrificio singular o especial que no tienen el deber de soportar y el principio de la solidaridad social (artículo 74), de acuerdo con el cual si la función administrativa es ejercida y desplegada en beneficio de la colectividad, es ésta la que debe soportar las lesiones antijurídicas causadas a uno o varios administrados e injustamente soportadas por éstos. Finalmente, es menester tomar en consideración que la Constitución Política recoge un derecho fundamental innominado o

[147] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Inconstitucionalidad: res. 5207-2004; 18 de mayo de 2004 14:55 horas, considerando, párrafo tercero.

atípico que es el de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos, el que se infiere claramente de la relación de los numerales, interpretados, a contrario sensu, 140, inciso 8°, 139, inciso 4° y 191 de la Ley fundamental en cuanto recogen, respectivamente, los parámetros deontológicos de la función administrativa tales como el "buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas", "buena marcha del Gobierno" y "eficiencia de la administración". Este derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos le impone a los entes públicos actuar en el ejercicio de sus competencias y la prestación de los servicios públicos de forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación correlativa de reparar los daños y perjuicios causados cuando se vulnere esa garantía constitucional.[148]

El constituyente recogió de manera diáfana el principio de responsabilidad de las Administraciones Públicas, régimen de responsabilidad que posteriormente sería desarrollado a nivel legal por la Ley General de la Administración Pública, así como por la legislación procesal contenciosa, sea el Código Procesal Contencioso Administrativo. Dicho principio, de importancia capital para delinear las relaciones de los administrados con las Administraciones, debe servir a todos los poderes públicos, así como operadores del derecho, como parámetro ineludible en orden de interpretar o integrar el ordenamiento jurídico administrativo.

"Bajo esta inteligencia, un corolario fundamental del principio constitucional de la responsabilidad administrativa lo constituye la imposibilidad para el Legislador ordinario de eximir o exonerar de responsabilidad a algún ente público por alguna lesión antijurídica que le cause su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita a la esfera patrimonial y extrapatrimonial de los administrados."[149]

La fundación, a nivel normativo constitucional, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, mediante el artículo 49 de la Constitución Política de 1949, se erigió como uno de los baluartes del Estado Social y Democrático de Derecho en Costa Rica. La responsabilidad y debida tutela de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la función administrativa, es en definitiva otra clara manifestación de ese modelo estatal.

[148] *Ibidem.*
[149] *Ibidem.*

"De modo general, la responsabilidad administrativa tiene por función básica la reparación o resarcimiento de las lesiones antijurídicas causadas a un administrado (víctima o damnificado) en su esfera patrimonial o extrapatrimonial por un ente público en el ejercicio de la función administrativa. Uno de sus fines clásicos y tradicionales es servir de control o garantía para las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados que sean lesionadas por un ente público en el ejercicio de sus competencias o en la prestación de los servicios públicos expresamente asignados por la Constitución o la ley."[150]

El principio de responsabilidad al que se viene haciendo referencia no es más que una manifestación concreta respecto del derecho procesal contencioso administrativo del principio de Tutela Judicial Efectiva, contemplado a su vez en el artículo 41 de la Constitución Política:

"ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes."

Es a partir de este artículo que se garantiza el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, en favor de todos los administrados, como un derecho constitucional de todas las personas. Este principio encarna uno de los baluartes del derecho procesal en general, es decir, el acceso a las instancias judiciales para litigar sobre la afectación de algún derecho o interés legítimo. Se ha dicho que algunas de sus características son:

"Podemos aventurarnos a expresar, que las facetas más importantes del derecho a la tutela judicial efectiva, son las siguientes y a las cuales nos vamos a referir posteriormente:
a) Derecho a una resolución sobre el fondo.

b) Derecho a una resolución fundada en derecho.

c) La incongruencia.

[150] *Ibidem.*

d) La prohibición constitucional de indefensión."[151]

Sobre el primer punto, se puede plantear como acceso a la justicia en sentido estricto, en tanto consta de la posibilidad de que un tribunal con competencia definida conozca de un conflicto planteado por un sujeto que ve modificado o afectado un derecho o un interés legítimo. Se incluye dentro de este derecho la correcta determinación de la competencia en tribunales, tanto de instancia como de alzada, y el acceso a los recursos.

Sobre el derecho a una resolución fundada en derecho, remite de manera directa a la motivación de esta, a la interdicción de la arbitrariedad y el mantenimiento de un nexo lógico entre lo dispuesto en sentencia y lo tenido por cierto en el apartado de hechos.

> *Ahora bien, no significa lo anterior un derecho al acierto judicial, pues la selección de la norma aplicable en cada caso concreto es una cuestión de mera legalidad. También se quebranta este derecho, cuando un tribunal decide sobre la base de un error patente o sobre la base de una selección o interpretación de la norma aplicable arbitraria o manifiestamente irrazonable, porque en tales casos la decisión judicial no puede decirse que esté fundada en derecho.*[152]

La incongruencia es más bien un vicio procesal. Existen básicamente dos tipos de incongruencia en el derecho público, la incongruencia por exceso y la omisiva. La primera consiste en que el tribunal encargado de resolver el litigio concede más de lo que le ha sido solicitado, en cuyo caso se daría el fenómeno denominado *ultra petitum*, o también, en el escenario de que otorgue algo distinto a lo que se le ha pedido (*extra petitum*). Ahora bien, la incongruencia omisiva supone una carencia en tanto se obvian elementos de necesaria consideración en la resolución del litigio.

> *"En sentido amplio, consiste en la falta de pronunciamiento en aquellos casos en la sentencia debía de pronunciar. Sin embargo, en sentido puro, la incongruencia omisiva sólo se produce si alguna pretensión oportunamente deducida por el actor ha quedado imprejuzgada."*[153]

---

[151] Ugalde Miranda, Óscar. Derecho a la Tutela Efectiva. San José, Costa Rica. Revista de ciencias jurídicas/ Universidad de Costa Rica. No 106. (2005). P14
[152] *Ibid.* P16.
[153] *Ibid.* P17.

Por último, como elemento conformante de la tutela judicial efectiva, se debe destacar la prohibición de indefensión mencionada, que a su vez abarca el obligatorio acatamiento del debido proceso constitucional. La tutela judicial no solo debe ser efectiva, sino que, según lo señala el propio artículo 41 de la Constitución Política, dicha justicia debe ser pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El quebrantamiento de estas pautas en la ejecución del proceso judicial llevaría a un estado de indefensión a la parte.

> *"Generalmente, la constatación de que se ha producido indefensión es porque se ha infringido una norma procesal. Se dice generalmente, porque este es el único elemento del juicio de indefensión, que no es necesario en todo caso. Puede ser que se produzca indefensión de la aplicación correcta de una norma procesal, que resulte inconstitucional o bien sin ser inconstitucional, por ejemplo con los actos de comunicación con las partes."*[154]

Ahora bien, la infracción de una norma procesal no es (en principio) por sí misma una causal de indefensión, ello tiene que producir una lesión o detrimento de las oportunidades para defenderse en el contradictorio. La denegatoria de prueba o limitación de las audiencias legalmente reconocidas pueden ser ejemplos de limitaciones al ejercicio de la defensa.

> *Para que pueda apreciarse indefensión, es necesario que la privación o limitación de defensa no haya quedado ulteriormente sanada. Dicha subsanación puede producirse en un ulterior trámite, porque el justiciable tiene la posibilidad de realizar la defensa, que previamente se le impidió. Además, como ya se dijo, es obligación del justiciable poner de manifiesto ante el órgano judicial la limitación o privación padecida, porque de lo contrario se entenderá que la indefensión le es imputable a él.*[155]

Por último, en relación con este último rasgo del derecho de tutela judicial efectiva, se debe aclarar un tema específico de la carga probatoria en cuanto a la indefensión. Lo dicho, en el tanto el concepto de indefensión trasciende el ámbito formal del quebrantamiento de una norma procesal por sí misma, es un concepto más bien material, donde se debe constatar la afectación de hecho sufrida por la parte a raíz de dicho yerro.

---

[154] *Ibidem.*
[155] *Ibid.* P18.

> *"quien alegue indefensión no puede limitarse a poner de manifiesto, que ha sido privado o que se le ha limitado ilegítimamente de una oportunidad de alegación o de prueba, debe especificar de qué contenido habría dotado esos trámites de alegación y prueba. En otras palabras, la noción de indefensión es realmente material. Ello no significa, que el indefenso quede vinculado a la efectiva utilización de esos medios de defensa, pero en todo caso le convendrá ser diligente en sus intenciones, porque el juicio definitivo sobre la efectividad de la indefensión va a depender de la idoneidad de esos medios de defensa, para alterar el resultado"*[156]

La tutela judicial efectiva y el principio de responsabilidad de la Administración (véase este no como una derivación del primero), así como todas sus implicaciones y alcances (explicados ampliamente), representan la columna vertebral del proceso contencioso. Si bien existe otra serie de principios de enorme importancia para la justicia administrativa, para efectos de la presente investigación, el desarrollo de estos dos baluartes es suficiente para revisar con acuciosidad el tema en cuestión, sea el Acto de Gobierno o político.

[156] *Ibidem.*

Sección Segunda: Mecanismos de control en la normativa costarricense

Existen multiplicidad de mecanismos de control sobre los actos administrativos, muchos de ellos incluso adscritos a la sede administrativa, es decir, la modificación o extinción de un acto, cuyo proceso de revisión se lleva a cabo en el seno de la propia Administración Pública. Este régimen está contemplado en la Ley General de la Administración Pública, donde se atiende a diversos escenarios de control de los Actos Administrativos, con lo que se establecieron mecanismos específicos de control para los diferentes escenarios que pudiesen acaecer (nulidad absoluta, relativa, entre otras variables).

La presente investigación se centrará únicamente en el control jurisdiccional de los actos administrativos, específicamente sobre el Acto de Gobierno. Para lo cual, la norma que resulta de indispensable consideración es el Código Procesal Contencioso Administrativo, cuya vigencia inició en el año 2008 y cuya estructura básica fue comentada previamente. Ahora conviene revisar con mayor amplitud dicho cuerpo normativo, en tanto es la base de la justicia administrativa costarricense. De arranque, resalta de indispensable consideración el artículo 1 del código de cita, en tanto estableció:

> *" ARTÍCULO 1.-*
>
> *1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa.*
> *2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder."*

Está claro el fuero de la jurisdicción contenciosa administrativa, que abarca la actividad formal de la Administración Pública, es decir, los actos administrativos, en el ejercicio de la función

administrativa. El artículo 33 del CPCA localiza el Acto Administrativo revisable dentro del trámite recursivo del procedimiento:

"ARTÍCULO 33.-

1) Cuando se opte por el agotamiento de la vía administrativa, la demanda se dirigirá, indistintamente, contra el acto que sea objeto de los recursos ordinarios, contra el que resuelva estos recursos expresamente o por silencio administrativo o contra ambos a la vez.

2) No obstante, si el acto que decide el recurso ordinario reforma el impugnado, la demanda se deducirá contra aquel, sin necesidad de recurso alguno."

Ahora bien, el control jurisdiccional de legalidad de los actos administrativos en Costa Rica se efectúa bajo el trámite del procedimiento ordinario contemplado en el CPCA, sin necesidad de agotar la vía administrativa. Existen algunos escenarios (ciertamente excepcionales) donde se establecen requisitos previos a la demanda, para constituir el proceso de revisión de legalidad, por ejemplo el procedimiento de lesividad contemplado en el artículo 34 del CPCA, que prevé:

"ARTÍCULO 34.-

1) *Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura."*

También hay un trámite específico para la impugnación de conductas omisivas, previsto en el CPCA. Para tal efecto, el código estableció:

"ARTÍCULO 35.-

1) Cuando se impugne una conducta omisiva de la Administración Pública, el interesado podrá requerir, al órgano o el ente respectivo para que en el plazo de quince días adopte la conducta debida. Si transcurrido dicho plazo la omisión persiste, quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

2) De haberse acudido directamente a la vía jurisdiccional, el juez o el Tribunal concederá, al jerarca supremo de la entidad o el órgano competente, un plazo máximo de quince días hábiles, con suspensión del proceso, para que cumplimente la conducta debida. De hacerlo así, se dará por terminado el proceso sin especial condenatoria en costas, sin perjuicio de continuarlo para el restablecimiento pleno de la situación jurídica de la persona lesionada. Si, transcurrido dicho plazo, se mantiene total o parcialmente, la omisión, el proceso continuará su curso, sin necesidad de resolución que así lo disponga."

Pero la base de las conductas administrativas objeto del proceso está contenida en el artículo 36 del CPCA, que enumera las actuaciones materiales, actos formales, conductas, relaciones y omisiones objeto del proceso contencioso. Con respecto al Acto Administrativo específicamente, prevé en su inciso tercero:

"ARTÍCULO 36.- La pretensión administrativa será admisible respecto de lo siguiente:

(...)

c)Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con efecto propio."

Dichos actos administrativos, en tanto requieran la debida publicación como mecanismo de eficacia, serán impugnables a partir del día siguiente de esta, por disposición del artículo 37 de la LGAP. Ahora bien, el plazo de prescripción general para la interposición de un proceso contencioso administrativo será el señalado por el artículo 39 del CPCA, es decir, de un año. En caso de que el acto deba ser notificado o publicado, dicho lapso se cuenta desde el día siguiente a que se haya completado la diligencia. Ahora bien, de suma importancia en este trámite de impugnación de Actos Administrativos, que se viene describiendo, es el plazo diferenciado que contempla el artículo 41 del CPCA, con respeto al inicio de los procesos civiles de Hacienda, en tanto contempla en lo de interés:

"ARTÍCULO 41.- El plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute en los siguientes supuestos:

1) En materia civil de Hacienda."

Ahora bien, la interposición y debida diligencia de un proceso contencioso administrativo, con arreglo a las disposiciones del CPCA, culmina de manera evidente en una sentencia judicial. Para este punto resulta indispensable establecer, en relación con el tema específico que se está

desarrollando, cuáles son las posibles solicitudes que puede plantear la parte, así como las eventuales determinaciones que pueda tomar el juzgador.

De cara a lo expuesto, es indispensable revisar lo que, en interés directo de lo que se viene desarrollando, contemplan los artículos 42 y 122 del CPCA, los cuales prevén las posibles pretensiones del proceso y los posibles pronunciamientos correspondientes. Con respecto específicamente al artículo 42, se enumera una lista *numerus apertus* de causales, en la cual constan la declaración de disconformidad con el ordenamiento, la anulación total o parcial o la modificación de la conducta administrativa, en este caso, el acto en cuestión. También se contempló la posibilidad de:

> *"f) La fijación de los límites y las reglas impuestos por el ordenamiento jurídico y los hechos, para el ejercicio de la potestad administrativa."*

Las posibles resoluciones por parte del juzgador dentro del proceso contencioso administrativo y que están previstas en el artículo 122 del código en mención, permiten precisamente resolver cada uno de los presupuestos planteados en las pretensiones, explicados *supra*, así como:

> *"k) Suprimir, aun de oficio, toda conducta administrativa directamente relacionada con la sometida a proceso, cuando sea disconforme con el ordenamiento jurídico.*
>
> *l) Hacer cesar la ejecución en curso y los efectos remanentes de la conducta administrativa ilegítima.*
>
> *m) Condenar al pago de los daños y perjuicios, en los siguientes términos:"*

Tal y como se adelantó en el inicio de esta sección, existen múltiples mecanismos de control de los Actos Administrativos, muchos regulados en la Ley General de la Administración Pública y normas afines. No obstante, solo resulta de interés repasar el mecanismo de control procesal contencioso, tramitado ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda y previsto por el CPCA. Procedimiento ordinario, de conocimiento, que prevé la revisión jurisdiccional de los Actos Administrativos, con sus particularidades y alcances específicos y que, en última instancia, materializa lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política, tantas veces referido.

Título III: Control jurisdiccional de los Actos de Gobierno

Contenido:

Capítulo 1. Elementos y su impugnabilidad

Sección Primera: Control de legalidad

Sección Segunda: Daños y perjuicios patrimoniales

Sección Tercera: Afectación de derechos subjetivos e intereses legítimos

Capítulo 2. Marco normativo y jurisprudencial

Sección Primera: Regulación normativa del Acto de Gobierno en Costa Rica

Sección Segunda: Análisis de antecedentes jurisprudenciales

Capítulo 3. El Acto de Gobierno frente a los principios garantistas del Derecho Público

Sección Primera: El Acto de Gobierno y el principio de acceso a la justicia

Sección Segunda: El Acto de Gobierno y el principio de reparación integral del daño

Sección Tercera: Propuesta de un modelo garantista de control del Acto de Gobierno

Capítulo 1. Elementos y su impugnabilidad

Sección Primera: Control de legalidad

En el título anterior se exploraron las principales características y elementos del control jurisdiccional de la actividad formal de la Administración (Actos Administrativos) en la legislación costarricense. Ello, sin embargo, únicamente como preámbulo al análisis que se efectuará en este tercer y último título, en el que se someterá al Acto de Gobierno en específico a los mecanismos de control existentes en nuestro derecho. En ese orden de ideas, ya se pudo entrever a grandes rasgos el funcionamiento del proceso contencioso administrativo costarricense, así como los mecanismos de control del Acto Administrativo, aunque no dirigido de manera específica al Acto de Gobierno, tarea última de esta investigación y que arranca con este tercer título.

El baremo más evidente y que, por tanto, resalta de primero de cara a analizar el control de los Actos Administrativos, es el principio de legalidad. Lo dicho, en el tanto existe un imperativo legal y constitucional (artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública correspondientemente) de que las actuaciones formales y materiales de las Administraciones Públicas estén plenamente sometidas a las leyes vigentes. Ciertamente, se debe explorar de manera previa los alcances de tal principio, en tanto no es solamente a las leyes que los actos deben estar sometidos, así como la legalidad no es un concepto conformado única y exclusivamente por el sometimiento de los actos administrativos a normas con valor de ley.

> *"El principio de legalidad dispone que todo acto o comportamiento de la Administración que incida sobre los derechos del particular debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. Aparentemente el fin único o principal es la protección del ciudadano, que así puede anticipar la conducta de la Administración con vista de ese orden; este le indica de antemano lo que aquella puede hacer o no hacer en relación con sus derechos. Desde este ángulo, el principio de legalidad es una garantía típica del Estado Liberal de Derecho y un freno para la actividad estatal. Está permitido únicamente lo que está autorizado y está prohibido todo lo demás. Es el principio inverso de libertad del particular, que vivimos*

que permite a éste hacer todo lo que no está prohibido, aunque no esté expresamente autorizado."[157]

Tal y como lo explica Ortiz, el principio de legalidad es el contrapunto material del principio de libertad individual. Lo que quiere decir que la Administración Pública en tanto ente y, por tanto, persona de derecho, no se rige por la regla básica y general que establece que cada individuo, dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, tiene libertad para hacer todo lo que le plazca, excepto lo que esté explícitamente prohibido. La Administración Pública únicamente puede hacer lo que le esté permitido, en ese tanto el principio de legalidad no es únicamente una limitación a la actividad administrativa, sino que también establece un orden básico que garantice la eficiencia administrativa:

"Vincular al Estado a la observancia del derecho es no sólo hacer previsible para el jerarca lo que puede o debe hacer sino también asegurar un mínimo de oportunidad y conveniencia a su gestión."[158]

Esta última valoración remite precisamente al control de legalidad, entendido como un control que trasciende la previsión taxativa de requisitos legales para la conformación de un Acto Administrativo, sino que estos además deben respetar multiplicidad de parámetros expresos o implícitos, pero derivados del bloque de legalidad, como podrían ser los principios generales del derecho, la proporcionalidad de un acto, así como la oportunidad y la conveniencia.

Se debe acotar que el principio de legalidad no vincula a la Administración en los actos y actividades que sean favorables para el administrado, señalando algunas excepciones, como podría ser el incumplimiento de un fin público al que dichos actos hayan estado previamente destinados.

El ámbito del principio de legalidad es uno de los temas que se deben destacar para efectos de esta investigación, en tanto el mismo prescribe que todo acto formal o actuación material de la Administración debe estar sometida a habilitación legal previa, con la excepción de que resulte evidente que es una actividad privada de la Administración, que no obedezca al derecho público, sino al civil o mercantil. El ámbito de aplicación de dicho principio resulta además importante, dado que, tal y como se pudo observar en acápites anteriores, la teoría clásica del Acto de Gobierno

[157] Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo I. Costa Rica: Stradtmann. 1998. P41.

[158] *Ibidem.*

estableció la exclusión de este instituto del contralor de legalidad, lo que no tiene cabida en las nociones contemporáneas (incluso desde hace ya varias décadas) de dicho principio:

> *"De este modo no sólo los actos de imperio (que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones del particular frente al Estado) sino también los actos de organización y de trámite del mundo interior de la Administración (que ponen los medios necesarios para que el acto principal se realice) lo mismo que los llamados actos de gobierno (de posterior explicación) entran dentro del ámbito de aplicación del principio".*[159]

Tal y como se adelantó, el concepto de legalidad trasciende al acatamiento de las normas con rango legal en sentido estricto, sino que se compone de lo que se ha denominado bloque de legalidad, que se predica ya no solo de una serie de normas con cierto rango (legal), sino que va mucho más allá de ello e incluye normas no escritas como los principios generales del derecho, la jurisprudencia constitucional y de la Sala de Casación Contencioso Administrativa, entre otros mecanismos de integración, interpretación y normativos, que están vinculados con el derecho administrativo.

> *"El bloque de legalidad está formado, en sentido amplio, no sólo por la ley sino también por todas las normas escritas (reglamentos, decretos de facto, decretos de urgencia, leyes delegadas) y no escritas (costumbres o prácticas administrativas, jurisprudencia y principios generales de derecho) que integran aquel ordenamiento. La regla que autoriza la conducta administrativa puede ser no escrita y ser sin embargo, tan imperativa como la ley."*[160]

Lo que se quiere hacer ver es que, en la opinión de Eduardo Ortiz (compartida en esta investigación), el parámetro de legalidad para revisar la validez de una actuación formal de la Administración Pública trasciende a la norma escrita, al punto de que incluso se habla de una legalidad no escrita. Tal y como se ha mencionado previamente en esta investigación, en relación con el Acto de Gobierno existe una serie de vacíos normativos de enorme relevancia. La figura del Acto de Gobierno en Costa Rica, entendiendo este instituto como aquel acto de la Administración cuya característica principal es estar exento del contralor de legalidad, se sostiene sobre la base de un único inciso del artículo 3 del CPCA, que no es concluyente en los alcances y límites de dicha

[159] *Ibid.* P42.
[160] *Ibidem.*

exclusión, por lo que resultan indispensables la interpretación y la integración normativa, en el ejercicio del control de legalidad de este tipo de actos. Sobre la interpretación y la integración normativa en el derecho *ius* publicista, la LGAP estableció:

> *"Artículo 7º.-*
>
> *1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.*
>
> *2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.*
>
> *3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior."*

Esta interpretación, acorde con los principios generales del derecho y otras normas no escritas que integran el ordenamiento jurídico administrativo, debe tomarse como referencia para interpretar el Acto de Gobierno como instituto jurídico, antes las enormes carencias regulativas que adolece este instituto en la normativa costarricense. En la práctica, el acatamiento de la legalidad no escrita y la integración e interpretación que tome en cuenta principios generales y otros parámetros ajenos a la legalidad escrita, implica que si una ley se contrapone a un principio de mayor jerarquía (constitucional) eventualmente dicho principio podría imponerse a la prescripción legal. En concreto:

> *"La norma no escrita no puede derogar el ordenamiento escrito, salvo que se repute –por jurisprudencia o ley- de rango superior a la norma de cuya modificación se trata. Pero las reglas no escritas, sobre todo los principios generales del derecho, pueden servir no sólo para interpretar las normas escritas sino también para suplirlas. En esta hipótesis se habla de integración de la ley. Es posible concluir, entonces, que cabe la integración del ordenamiento jurídico administrativo mediante la aplicación de normas no escritas que suplen la ausencia total de norma escrita para un caso concreto."*[161]

[161] *Ibid.* P44.

Esta forma de entender el ordenamiento no escrito, como uno de los principales parámetros para interpretar y suplir la norma escrita, también se encuentra respaldado en el artículo quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo concerniente estableció:

> *"Los principios generales del derecho y la jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley."*

Lo que se quiere hacer ver es que el principio de legalidad debe comprenderse de forma amplia y no restringida. La exigencia puede provenir a una norma escrita o no escrita, pero norma al fin, que autorice los Actos Administrativos de las Administraciones Públicas, siendo ello un requisito indispensable para su validez. Se rechaza la posibilidad de que se autorice una conducta administrativa a través de una regla concreta que contemple un caso específico, siendo necesario la existencia de un mandato general. El acto debe someterse a la norma, pero esta norma no debe entenderse únicamente como leyes escritas, sino que se incluyen dentro de dicho ámbito normas no escritas de igual relevancia interpretativa e integrativa, como lo son los principios generales del derecho.

Ahora bien, debe mencionarse que el principio de legalidad tiene dos vertientes, en tanto implica (como ya se explicó) un freno negativo para el accionar de la Administración, que en principio solo puede realizar aquello para lo que está autorizada por el bloque de legalidad, pero también supone una vertiente positiva en cuanto le indica a la Administración qué hacer.

> *"Puede afirmarse, incluso, que la limitación negativa es consecuencia de la positiva, dado que esta, al imponer deberes de conducta, simultáneamente prohíbe la conducta opuesta a la debida u ordenada."*[162]

El principio de legalidad entonces supone en definitiva una sumisión del acto a la norma. Se debe ser consciente de que el acto se compone de varios elementos, ya desarrollados *supra* y a la luz de los cuales se debe determinar cuáles de ellos deben estar necesariamente determinados por norma escrita, particularidad exigida por el ordenamiento. Lo anterior, dado que todo acto no autorizado

[162] *Ibid.* P45.

es irregular. Se tiene que la competencia es un elemento que necesariamente debe estar regulado por la norma:

> *"Puede decirse, entonces, que toda conducta administrativa está regulada en cuanto al sujeto u órgano que la realice"*[163]

Agrega Eduardo Ortiz, que otro elemento que debe estar determinado por norma legal en un Acto Administrativo es el fin, aunque hace la aclaración de que dicho fin no debe estar descrito de forma precisa, sino que puede estar regulado por principios generales o por jurisprudencia, dado que lo que se necesita es que el mismo no sea contra *legem*, existe en este sentido una libertad del funcionario para elegirlo, siempre y cuando no sea privado o contrario al ordenamiento:

> *"En la hipótesis de que la norma jurisprudencial determine y precise el fin, puede hablarse con propiedad de la libertad del funcionario para determinarlo, frente a la ley. Pero tal libertad queda destruida si, en labor de aplicación de ésta, el juez sustituye al administrador y determina por su cuenta un fin diverso al escogido por este último, que será el prevaleciente y legítimo."*[164]

Ahora bien, para dictar el acto, el sujeto competente debe estar regulado, así como que el fin, también en los términos descritos, ahora se debe agregar que se necesita conocer de antemano no solamente estos dos elementos del acto en cuestión, sino la consistencia de lo determinado por el sujeto con el fin mismo, su vocación como medio al servicio de tal fin. Por lo dicho, Eduardo Ortiz explicó:

> *"El ordenamiento debe regular, además, alguno de los elementos materiales del acto, que son los que determinan la satisfacción del interés público y la manera en que se realiza. Estos elementos fundamentales son el motivo y el contenido. No es preciso que haya una ley que indique la naturaleza y alcances de esos elementos. Como antes en relación con el fin, puede decirse ahora que la fuente de regulación no está sólo en la ley sino en el ordenamiento como un todo: jurisprudencia y principios generales de derecho administrativo pueden jugar perfectamente el papel de bases jurídicas del acto"*[165]

Esto es lo que se conoce como el principio de regulación mínima del Acto Administrativo, es decir, que la conducta administrativa debe estar siempre regulada por norma preexistente escrita y no

---

[163] *Ibid.* P48.
[164] *Ibid.* P49
[165] *Ibidem.*

escrita, en cuanto a los elementos formales y materiales específicos descritos, es decir, órgano, fin y, de manera alternativa, motivo o contenido. Se tiene que entender como uno no autorizado, todo acto que no tenga, cuando menos, regulados estos elementos.

Como se ha advertido previamente en esta investigación, el adecuado entendimiento del Acto de Gobierno, en tanto se pretenda mantener su exclusión de control jurisdiccional del contralor de legalidad, lo reduce a un grupo reducido de supuestos en los que puede producirse, que están sometidos únicamente a la Constitución. Otro caso en el que es concebible que un Acto Administrativo esté exento del contralor de legalidad son los denominados actos institucionales desarrollados *supra* (Marienhoff), ya no por razones de fondo sino procesales, por cuanto no existe afectación de derechos subjetivos o intereses legítimos, y en ese tanto no existe legitimación activa. La particularidad dicha disminuye en enorme medida el parámetro de legalidad que existe para contrastar los elementos de un Acto de Gobierno, empero tiene otra consecuencia directa, evidente y de enorme importancia, que únicamente la Constitución misma puede habilitar la adopción de uno, por lo que un Acto de Gobierno cuyo fundamento se encuentre en normas (escritas o no) de rango legal, sería inválido. En suma:

> *"El principio de legalidad es también en este caso imperativo de una regulación mínima, que contemple el sujeto (órgano) y el motivo o el contenido del acto, siempre a condición de que no sea la ley sino la Constitución la fuente de dicho régimen. Puede estar regulado también el fin y normalmente lo está; y el fin puede ser, como normalmente lo es, uno de aquellos supremos intereses del Estado o de la comunidad. Pero puede faltar esa regulación y, sin embargo, es un Acto de Gobierno, en cuanto regulado únicamente por la Constitución."*[166]

De cara a estos parámetros, resulta imperioso establecer cuáles serían las vías o remedios correctivos con los que cuenta el juzgador contencioso administrativo, en el escenario de que se verifique la ilegalidad de una conducta, para lo cual conviene traer nuevamente a colación lo dispuesto por el artículo 122 del CPCA, que es sumamente amplio, otorgándole un importante y variado margen de posibilidades a dicho juzgador, dentro de las que destacan:

> *"a) Declarar la disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico y de todos los actos o actuaciones conexos.*
>
> *b) Anular, total o parcialmente, la conducta administrativa.*

[166] *Ibid.* P51.

c) Modificar o adaptar, según corresponda, la conducta administrativa a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico, de acuerdo con los hechos probados en el proceso.

d) Reconocer, restablecer o declarar cualquier situación jurídica tutelable, adoptando cuantas medidas resulten necesarias y apropiadas para ello.

e) Declarar la existencia, la inexistencia o el contenido de una relación sujeta al ordenamiento jurídico-administrativo.

f) Fijar los límites y las reglas impuestos por el ordenamiento jurídico y los hechos, para el ejercicio de la potestad administrativa, sin perjuicio del margen de discrecionalidad que conserve la Administración Pública.

g) Condenar a la Administración a realizar cualquier conducta administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico.

j) Ordenar a la Administración Pública que se abstenga de adoptar o ejecutar cualquier conducta administrativa, que pueda lesionar el interés público o las situaciones jurídicas actuales o potenciales de la persona.

k) Suprimir, aun de oficio, toda conducta administrativa directamente relacionada con la sometida a proceso, cuando sea disconforme con el ordenamiento jurídico.

l) Hacer cesar la ejecución en curso y los efectos remanentes de la conducta administrativa ilegítima."

Existe un supuesto adicional, contemplado dentro de este posible panorama resolutivo con el que cuenta el juez contencioso. Dicho supuesto será de examen en el acápite siguiente, en tanto se establece la posibilidad de:

"m) Condenar al pago de los daños y perjuicios."

Sección Segunda: Daños y perjuicios patrimoniales

Como ya se adelantó en el título segundo de la presente investigación, uno de los principios rectores de un Estado Social y Democrático de Derecho, que se debe además ver reflejado en su derecho procesal contencioso administrativo y civil de Hacienda, es el de responsabilidad. Lo dicho, en tanto las Administraciones Públicas por su condición de entes y, por tanto, sujetos de derechos y obligaciones, les resulta de plena aplicación el principio general de no dañar a nadie o *alterum non laedere*, por ello, no pueden estar exentas de ser responsables por sus actuaciones formales (Actos Administrativos) o conductas materiales. El artículo 9 de la Constitución Política prevé dicha responsabilidad, en tanto establece:

> *"ARTÍCULO 9º- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y* ***responsable****. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial."* (El resaltado es añadido).

Este artículo recién transcrito es la base constitucional de la responsabilidad de la Administración Pública con respecto a sus administrados. Se deben traer a colación los artículos 49 y 41 de la Constitución Política, que complementan lo anterior, en tanto establecen la jurisdicción contenciosa como contralor de la Administración Pública (encargada de verificar esta responsabilidad), así como el principio de tutela judicial efectiva, que proporciona un derecho fundamental a todos los administrados, de acudir a las instancias judiciales en aras de reclamar los menoscabos en derechos o intereses de los que hayan sido víctimas. En suma, sobre la responsabilidad en general del Estado, se debe afirmar que:

> *"Cuando el Estado –o cualquier otro gente público. Administra, es un sujeto de Derecho, sometido al Derecho, que trata de realizar determinados intereses, relacionándose con otros sujetos de Derecho. El Estado, entonces, es parte de relaciones jurídicas, derivadas de su actuación. Es titular de un interés en juego –el interés público- Asignado por el Derecho y conforme al Derecho. Por ello, la doctrina de la personalidad jurídica del Estado se ha planteado en su acción administrativa. Porque el Estado, en cuanto administrador, es sujeto de Derecho."*[167]

[167] González Pérez, Jesús. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. España: Civitas. 2006. Pp 54-55.

Del principio de responsabilidad, así como de una interpretación armónica de los preceptos constitucionales que establecen la responsabilidad de la Administración Pública, se constriñe a la Administración a responder por las infracciones al bloque de legalidad que en su accionar cometa. Dicha respuesta puede ser correctiva (en tanto se modifique o extinga) la conducta administrativa cuestionada, o puede ser pecuniaria, en tanto se indemnice dinerariamente los daños causados. También, dicha responsabilidad puede ventilarse incluso en sede administrativa, no obstante, por el objeto preciso de esta investigación se ahonda únicamente en la sede jurisdiccional.

> *"La problemática de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios públicos, conjuntamente con la protección administrativa y jurisdiccional de los administrados, constituye uno de los puntos esenciales del derecho administrativo. Cuando el Estado dicta un acto antijurídico, existirá la posibilidad de impugnarlo en sede administrativa (procedimiento administrativo) o judicial (derecho procesal administrativo); pero, además, será necesario indemnizar el perjuicio ocasionado, haciendo efectiva la responsabilidad pecuniaria del funcionario autor del daño y del Estado."*[168]

Ahora bien, como es sumamente conocido, la responsabilidad de la Administración Pública puede ser contractual, aspecto que no resulta de relevancia para el Acto de Gobierno en específico y cuyo análisis será obviado. Interesa la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración Pública, que puede producirse a partir de los daños o perjuicios que esta pudiese generar con sus conductas formales o actuaciones materiales. Sobre esta dicotomía, enunció González Pérez lo siguiente:

> *"Es indudable que la responsabilidad patrimonial responde a unos mismos principios jurídicos, tienen un fundamento común, y en buena parte están sometidos a regímenes jurídicos análogos (12). Pero, aun sin afectar a los principios ni al fundamento, los dos supuestos de responsabilidad presentan diferencias relevantes. «La presencia de un contrato administrativo –dice ESCOBAR- informa al contenido resarcitorio de sus principios y de su naturaleza, dándole una peculiaridad dictada de acuerdo con los intereses que juegan en su seno» (13).*[169]

[168] Gordillo, A. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires, Argentina: FDA. 2013. P537.
[169] González Pérez, Jesús. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. España: Civitas. 2006. P 194.

Como se adelantó previamente, interesa a esta investigación únicamente la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración, en tanto sería el único tipo de responsabilidad que podría generarse a raíz del dictado de un Acto de Gobierno. Ese tipo específico de responsabilidad patrimonial tiene, en el decir de González Pérez, dos características principales, a saber, el ser directa así como objetiva. Sobre la primera de estas características se ha dicho que:

> *"Las Administraciones públicas responderá directamente, cualquiera que hubiese sido el grado de culpabilidad en que pudiera haber incurrido la persona física –autoridad, funcionario, agente- en su actuación. Los afectados por el daño no tendrán que establecer disquisiciones en orden a la culpabilidad de la persona física a la que pudiera imputarse inmediatamente la actuación, sino que podrán exigir «directamente a la Administración pública las correspondientes administraciones»."*[170]

Entendiendo la relación de persona a órgano que guarda la Administración con sus funcionarios, en tanto a la disposición de actos administrativos e incluso actuaciones materiales, se sostiene que es relativamente indiferente la identificación del funcionario específico que adoptó la conducta en cuestión, en tanto el ente pasivo de responsabilidad en todo caso sería la Administración actuante. En el caso específico de Costa Rica, existe una excepción a ello, escenario en el cual la responsabilidad patrimonial la debe asumir el funcionario público que dispuso el acto específico, que es el escenario de existencia de *dolo* o culpa grave, empero, ello no es de gran relevancia para el presente trabajo.

Con respecto a la característica de ser objetiva, a lo que se refiere es que, a diferencia de otros sistemas de responsabilidad, como la disciplinaria, penal e incluso civil, donde deben mediar elementos subjetivos de culpa o *dolo* para la existencia de responsabilidad, en la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración no deben existir tales elementos vinculantes. Es decir, en tanto régimen de responsabilidad objetiva, no debe mediar una falta dolosa o culposa del funcionario que materialmente dictó el Acto Administrativo o ejecutó la conducta material, para que se genere responsabilidad patrimonial extracontractual para el Estado. Ahora bien, debe aclararse que en el caso específico de Costa Rica, hay abundante jurisprudencia de la Sala de Casación Contenciosa Administrativa (Sala Primera), que ha expuesto desde hace ya más de una

[170] *Ibid.* P201.

década que la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración es eminentemente objetiva, más no completamente objetiva. Sobre ello:

> *"Dentro de la dinámica del sistema de responsabilidad preeminentemente objetiva de la Administración, el Estado es responsable frente a un particular que haya sufrido una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y que haya sido provocada por un funcionamiento público. El ámbito de cobertura de los postulados que lo integran, incluye, además de las lesiones de naturaleza material, las de carácter extrapatrimonial. Este tipo de responsabilidad se sustenta en el daño propiamente, y no en otros elementos, como el dolo o la culpa. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 41 de la Constitución Política, que en lo que interesa, señala: "Ocurriendo a las Leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.". Así como en el canon 197 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual: "Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión proferida, respectivamente." Para este criterio de imputación no se requiere que el análisis de la conducta verse en si fue con dolo o culpa de quien causa la lesión. Ese tipo de consideraciones se tornan intrascendentes, por cuanto entran en juego otros aspectos. Es indispensable que exista un nexo causal entre la conducta o situación que motiva el daño y el que sufre la víctima, ligamen que se rompe en caso de mediar alguna eximente a saber: fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Este principio surge independientemente de la responsabilidad frente al administrado, que puedan asumir sus funcionarios o agentes."*[171]

Este sistema objetivo es una importación del derecho español, el cual, tal y como expone Jesús González Pérez, al instaurar la responsabilidad también por funcionamiento normal y conducta lícita, atiende a un régimen de responsabilidad objetiva. Lo dicho por el autor, a partir de la

[171] Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de casación: res. 00875-F-2007; 14 de diciembre de 2007 8:00 horas, considerando, párrafo primero.

legislación española, rescatable por ser el mismo caso costarricense, es sumamente claro sobre este punto:

> *"Al no limitar el derecho a indemnización a los supuestos de daños causados por el funcionamiento anormal de los servicios públicos y extenderlo también a los ocasionados por su funcionamiento normal, somete a la Administración de nuestro país a un régimen de responsabilidad extracontractual de tipo objetivo, dando así continuidad a una línea única en Europa que se iniciará el año 1954 al aprobarse la LE y continúa en 1957 con la LRJ, responsabilidad objetiva de régimen global que alcanza a todas las Administraciones Públicas españolas, con independencia de su ámbito material o territorial de actividad, lo que significa que no se requiere la existencia de culpa en el actuar administrativo."*[172]

La responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración Pública en Costa Rica está regulada en el título sétimo, capítulo primero, sección primera de la Ley General de la Administración Pública, que en su artículo 190 dispone:

> *"Artículo 190.-*
>
> *1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente."*

Tal y como se puede observar de la cita recién transcrita, existen cuatro supuestos básicos en los que los Actos Administrativos pueden generar responsabilidad para la Administración Pública, que son el funcionamiento normal o en su defecto anormal, así como las conductas lícitas e ilícitas. Ahora bien, dada la claridad con la que están redactados dichos supuestos en la propia LGAP, se procede a transcribir los artículos que en lo conducente explican la concurrencia de cada uno de

[172] González Pérez, Jesús. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. España: Civitas. 2006. P203.

esos supuestos. En sus artículos 191 y 192, con respecto a la responsabilidad por funcionamiento anormal y conducta ilícita (correspondientemente), la LGAP expone:

> *"Artículo 191.-La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión."*
>
> *"Artículo 192.-La Administración será también responsable en las anteriores condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para ello."*

Por otro lado, lo relativo a la responsabilidad patrimonial de la Administración, en relación con el funcionamiento normal y la conducta lícita, se contempla en el artículo 193, y una precisión de enorme relevancia en el artículo 194, en cuanto a la necesaria concurrencia de un daño especial con características específicas:

> *"Artículo 194.-*
>
> *1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión.*
>
> *2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante.*
>
> *3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo."*
>
> *"Artículo 195.-Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso."*

El actuar de la Administración Pública, bajo los parámetros desarrollados por los artículos 190 y siguientes de la LGAP, es capaz de generar responsabilidad pecuniaria desde cualquiera de las funciones que existen en la Administración. Por supuesto, administrando (función ejecutiva o de

administración), pero también el Estado en sus funciones de legislador y de juez puede generar responsabilidad, incluso desde luego, se puede afirmar que desde el ejercicio de la función gubernativa, explicada en el título primero de esta investigación, lo dicho en tanto la norma que tipifica los supuestos generadores de responsabilidad para la Administración Pública costarricense. La Sala Constitucional sobre la responsabilidad de la Administración ha expuesto:

> *"De modo general, la responsabilidad administrativa tiene por función básica la reparación o resarcimiento de las lesiones antijurídicas causadas a un administrado (víctima o damnificado) en su esfera patrimonial o extrapatrimonial por un ente público en el ejercicio de la función administrativa. Uno de sus fines clásicos y tradicionales es servir de control o garantía para las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados que sean lesionadas por un ente público en el ejercicio de sus competencias o en la prestación de los servicios públicos expresamente asignados por la Constitución o la ley."*[173]

Dicho daño, producido por una conducta formal o material de la Administración Pública resulta, como se pudo ver, del funcionamiento normal o anormal, así como de las conductas lícitas o ilícitas de las Administraciones Públicas. Se genera un vínculo obligacional entre dos partes (sujeto pasivo y activo del daño), que en el caso en concreto, la Administración como sujeto activo del daño tiene el deber de resarcir, de acuerdo al principio de reparación integral del daño comentado. Sobre ello ha dicho González Pérez:

> *"Surge una vez producido el evento, como consecuencia de las reglas impuestas por la convivencia en aplicación del principio alterum non laedere y aunque no constituye un prius como en la culpa contractual, sino un posterius, su configuración se atiene al esquema de toda relación obligatoria: un acreedor, un deudor y una exigencia de prestación. Y –comenta LÓPEZ JACOISTE- ese esquema se esboza y delinea mediante la imputación, cuya índole es, por lo mismo, eminentemente jurídica."*[174]

Una vez producida la conducta dañosa y si esta cumple con los requisitos previstos por la ley para ser sujeto de indemnización, es decir, ser efectivo, evaluable económicamente e individualizable, la Administración Pública, autora de la conducta, no tiene otra alternativa que indemnizar al

[173] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: res. 5207-2004; 18 de mayo de 2004 2:55 horas, considerando, párrafo octavo.
[174] González Pérez, Jesús. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. España: Civitas. 2006. P 313.

afectado que no esté en la obligación legal de soportar tal daño. Lo descrito debe ser materializado por ambas jurisdicciones, Contencioso Administrativa (en caso de que se deba revisar la legalidad de una conducta formal) así como Civil de Hacienda, que en el caso costarricense fueron unificadas en una sola. Lo anterior, en cumplimiento de los principios generales del derecho tratados, como el de responsabilidad de la Administración, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y reparación integral del daño, entre otros. En atención a lo preceptuado desde un nivel constitucional, en los artículos 9, 49 y 41 principalmente, de la Constitución Política. Este proceder es lo que finalmente materializa o encarna el principio de reparación integral el daño, según el cual los administrados pueden ver indemnizados los menoscabos en sus derechos subjetivos e intereses legítimos que sean contrarios a derecho, echando mano de la jurisdicción establecida en el artículo 49 constitucional.

> *"En el procedimiento de responsabilidad patrimonial ha de determinarse la indemnización. Demostrada la concurrencia de los requisitos exigidos para que nazca la responsabilidad de la Administración Pública, deberán acreditarse los daños indemnizables, cuantificándose la reparación.*
>
> *Es obvio que para que se respete el principio de igualdad ante las cargas públicas que constituye el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, la reparación ha de ser integral. El patrimonio del administrado deberá resultar inalterado, procediendo una indemnización que equivalga al daño sufrido."*[175]

Ahora bien, dicho daño debe de cumplir con ciertos requisitos específicos para ser indemnizable en los términos descritos. Como ya se mencionó, la lesión debe ser una lesión efectiva, evaluable económicamente e individualizada con relación a un sujeto específico. Pero además de ello, resulta necesaria la existencia de un nexo causal, entre la lesión y el daño producido y que se solicita indemnizar. La Administración estaría obligada a indemnizar lesiones patrimoniales únicamente en el caso de que el hecho o acto determinante de la lesión sea imputable a esta.

> *La responsabilidad patrimonial de la Administración exige que « exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultad dañoso erigiéndose el nexo*

[175] *Ibid.* P314.

causal en elemento fundamental y requisito sine qua non para poder declarar procedente la responsabilidad ».[176]

En el caso en concreto y para efectos del Acto de Gobierno en específico, interesa especialmente la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración Pública generada a partir de la adopción de actos administrativos, en tanto ese sería el supuesto específico de responsabilidad patrimonial en el que se encuadraría el Acto de Gobierno. Hoy en día es indiscutida la procedencia de indemnizar los daños patrimoniales causados por Actos Administrativos, incluso en el escenario en el que estos sean conformes al ordenamiento administrativo, según se vio del régimen de responsabilidad existente en los artículos 190 y siguientes de la LGAP. Entonces, siempre y cuando el administrado no tenga el deber legal de soportar el daño producido, tendrá derecho a indemnización, en caso de que se le produzca una afectación en su esfera jurídica resarcible, independientemente de si su origen yace en un acto válido o inválido.

"siempre que se produzca un daño producido como consecuencia de una función administrativa que el administrado no tenga el deber de soportar nace el derecho a indemnización aunque el acto que origine el daño sea conforme al ordenamiento jurídico."[177]

[176] *Ibid.* P509.
[177] *Ibid.* P393.

Capítulo 2. Marco normativo y jurisprudencial

Sección Primera: Regulación normativa del Acto de Gobierno en Costa Rica

Tal y como se ha venido exponiendo en el presente trabajo de investigación, la doctrina clásica del Acto de Gobierno, que durante mucho tiempo conformó el núcleo de significación y de implicaciones materiales de ese instituto, postulaba una exclusión jurisdiccional sobre dicho tipo específico de acto con respecto al contralor de legalidad, es decir, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda. En Costa Rica, así como en muchas otras latitudes donde el derecho continental europeo (particularmente el francés) tiene enorme vigencia, esta doctrina se afincó durante mucho tiempo y aún ahora persiste, aunque de manera reducida, esa doctrina clásica que, como se expondrá de manera contundente a la postre, es completamente contraria al bloque de legalidad. La supuesta exclusión se ha entendido contenida dentro del artículo 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo de 2008, que prescribe:

> *"ARTÍCULO 3.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda no conocerá las pretensiones siguientes:*
>
> *(...)*
>
> *b) Las concernientes a los actos de relación entre los Poderes del Estado o con motivo de las relaciones internacionales, sin perjuicio de las indemnizaciones procedentes, cuya determinación corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."*

Para este punto resulta indispensable aclarar que no se tiene intención de negar la existencia de una exclusión jurisdiccional, que de forma tajante y explícita está contemplada en un artículo vigente de la legislación procesal. La exclusión existe y es diáfana, lo que se pretende hacer en esta investigación es delimitar de manera correcta dicha exclusión, de forma tal que únicamente los Actos Administrativos, bajo el correcto entendimiento de lo que debe ser el Acto de Gobierno, puedan estar excluidos y, sobre todo, que en ningún escenario sin excepción alguna, un acto productor de un daño en los derechos subjetivos o intereses legítimos de un administrado pueda

ser excluido de ser revisado jurisdiccionalmente, tanto en la validez del acto mismo como en lo tocante a la posible generación de una lesión resarcible. El Acto de Gobierno correctamente entendido, del cual ya se ha hablado en acápites anteriores, es únicamente el acto constitucional, que no transgrede derechos subjetivos o intereses de administrados. En ese tanto, la normación de este instituto es también eminentemente constitucional, donde cobran particular relevancia los artículos 10 y 49 de la Constitución Política:

> *"El acto político o de gobierno se perfila fundamentalmente como una limitación o exclusión de la jurisdicción de constitucionalidad (acción de inconstitucionalidad), regulado por los artículos 10 de la CP y artículos 73 y siguientes de la LJC, y, sobre todo, como una exclusión de la jurisdicción de legalidad o contenciosa administrativa, ordenada por los artículos 49 de la Constitución y por la LRJCA."*[178]

Ahora bien, se reitera que, en ningún caso, un acto generador de una lesión, independientemente de su validez, pero particularmente si es totalmente inválido, no puede bajo ninguna circunstancia quedar completamente abstraído de la esfera del contralor de legalidad y de la consecuente acción jurisdiccional que posibilita el artículo 49 de la Constitución. De lo anterior se colige que también conforma la regulación del acto en cuestión, al menos en este extremo específico, lo contemplado en los artículos 41 y 27 de la Constitución Política. Según Eduardo Ortiz:

> *"Se trata de una excepción al principio de que, acudiendo a los tribunales, todo reclamante podrá encontrar reparación al agravio sufrido en sus intereses morales o económicos (artículo 41 de la CP), lo mismo que a la regla, todavía más importante, de que cualquiera tiene potestad para obligar a los tribunales a conocer de un conflicto jurídico si demanda su actuación de conformidad con la ley."*[179]

Es claro entonces que el Acto de Gobierno está únicamente sometido a la Constitución en Costa Rica, debido a la exclusión contemplada en el artículo 3 del CPCA. Lo dicho, siempre y cuando se entienda correctamente dicho instituto, como acto constitucional, cuyos pormenores ya se

[178] Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo I. Costa Rica: Stradtmann. 1998. P121.

[179] Ídem.

expusieron en esta investigación (título primero, capítulo tercero, sección segunda) y que es el encargado de materializar función gubernativa.

Sección Segunda: Análisis de antecedentes jurisprudenciales

En este acápite se pretende efectuar un estudio del Acto de Gobierno, a partir de la jurisprudencia de más alto rango del país, es decir de las Salas de Casación y el Tribunal Constitucional. Ello implica un análisis eminentemente procesal e incluso, podría decirse, formal, del asunto. Dado que la discusión alrededor del Acto de Gobierno en los pocos fallos en los que se desarrolla en alguna medida está centrada en los mecanismos para delimitar cuando se está ante uno y por tanto procede la exclusión del artículo 3 inciso B del CPCA, así como la consecuente excepción de acto no susceptible de impugnación. Lo que se pretende decir es que, como no podría ser de otra manera, no existen fallos que entren a conocer lo relativo a la validez o posible responsabilidad patrimonial de un Acto de Gobierno por el fondo, dado que en el momento en que se determina como tal se reputa inimpugnable. Lo que se ha fraguado, en la escaza jurisprudencia disponible, son algunos criterios para determinar si un acto específico es o no de Gobierno y, por tanto, es objeto de dicha exclusión. Esa zona fronteriza, entre un Acto de Gobierno y uno al que se llamará meramente administrativo, es el objeto de discusión en la práctica procesal con razón del instituto de cita.

Las jurisdicciones en donde se ha ventilado lo relativo al Acto de Gobierno son dos, la constitucional por la vía del amparo y de la acción de inconstitucionalidad, así como la Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, por la vía del recurso de casación, conocido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En lo que atiende a la vía constitucional, el principal asunto (más no el único) en discusión, es si el Acto de Gobierno está o no sometido a dicha jurisdicción, es decir, si la exclusión jurisdiccional del Acto de Gobierno tiene la potencia suficiente para excluirlo también del contralor de constitucionalidad, todo ello de cara al principio de supremacía de la Constitución. Ya en una sección anterior se desarrolló la perspectiva de Eduardo Ortiz con respeto a este tema en cuestión, y que es compartida en esta investigación; es decir, la aseveración de que cualquier conducta formal de la Administración, independientemente de su nomenclatura, así como de cualquier disposición legal que tendiere a excluirla del contralor de constitucionalidad, está indefectiblemente sometida al derecho de la Constitución, así como al contralor de constitucionalidad.

Un fallo de suma relevancia para el tema competencial, con respecto al contralor de constitucionalidad y el Acto de Gobierno, es la sentencia 9992-2004 de la Sala Constitucional. En

esta acción de inconstitucionalidad se solicitó que se declare la inconstitucionalidad del documento suscrito el diecinueve de marzo de dos mil tres por el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, en el cual el gobierno expresa la posición del Estado en relación con el conflicto armado en Iraq. En dicho fallo se estableció lo relativo a la competencia constitucional para conocer Actos de Gobierno, sobre ello la propia Sala Constitucional, cuyas sentencias tienen efectos de carácter *erga omnes*, expuso:

> *"Uno tiene que ver con la naturaleza propia del acto, en tanto se trata de uno de los llamados actos de gobierno que tradicional e históricamente estuvieron excluidos del escrutinio de los tribunales de justicia. No obstante, y como se señala en los diferentes intervenciones de las partes, en el actual desarrollo jurídico costarricense no existe disenso alguno sobre la posibilidad de que el contralor de constitucionalidad revise este tipo de actos emanados por el Poder Ejecutivo, cualquiera que sea su denominación o caracterización, pues –por principio- tales actos están sometidos a la Constitución Política, o, para precisarlo mejor, al llamado Derecho de la Constitución de modo que deben desenvolverse dentro del marco fijado por sus previsiones, amplias en diferente grado y muchas veces recogidas en normas y principios constitucionales que sirven como guías generales de actuación. Y justamente para velar porque ello sea así, se ha creado en nuestro ordenamiento la Sala Constitucional, como instrumento apropiado para esa tarea, de modo que también bajo esas razones lo procedente es entrar a conocer el fondo del asunto."*[180]

Lo más importante de destacar, con respecto a esta sentencia en específico, es que en la valoración de la Sala esta reconoce el carácter de Acto de Gobierno del acto impugnado en la vía constitucional, lo cual lo menciona explícitamente, empero, reafirma de manera contundente el sometimiento de dicho tipo de actos al contralor de constitucionalidad y, más ampliamente, al derecho de la Constitución. Con ello, se zanja el tema de si el Acto de Gobierno es o no sujeto del contralor de constitucionalidad, en tanto a tono con la doctrina nacional, la propia Sala Constitucional ha establecido tal sometimiento sin excepción alguna, entre otras razones por la

[180] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Inconstitucionalidad: res. 9992-2004; 8 de septiembre de 2004 14:31 horas, considerando, párrafo primero.

naturaleza de la jurisdicción constitucional, así como el principio de supremacía de la Constitución Política.

Ahora bien, si el Acto de Gobierno es sujeto del contralor de constitucionalidad, premisa sentada para este momento, la cuestión se reduce enormemente, en tanto gira únicamente en torno al control de estos actos en instancias contencioso administrativas. Se genera la necesidad de establecer mecanismos para determinar la competencia contenciosa, así como criterios para establecer cuándo se encuentra ante un Acto de Gobierno y con ello aplicar la exclusión prevista en el artículo 3 del CPCA. La Sala Constitucional ha tratado lo relativo a los alcances competenciales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, en tanto en una acción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 3 inciso a) del CPCA, donde se discutía la constitucionalidad de sustraer las relaciones de empleo público de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; la Sala Constitucional expuso:

> *"**REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LA ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DE UNA COMPETENCIA**. El constituyente originario y el poder reformador se ocuparon de definir la competencia material y, por consiguiente, la extensión y alcances de dos jurisdicciones esenciales para el Estado Social y Democrático de Derecho. En efecto, en los ordinales 10 y 48 se establece la competencia material de la jurisdicción constitucional y, en el numeral 49, la de la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo anterior deja patente, en la voluntad del constituyente originario y del poder reformador, la trascendencia tanto del control de constitucionalidad como de legalidad de los poderes públicos en aras de garantizar el goce y ejercicio efectivos de los derechos fundamentales y humanos consagrados, respectivamente, en el texto constitucional y los instrumentos del Derecho Internacional Público. Sin duda alguna, tales preceptos constitucionales encarnan lo que la doctrina ha denominado la cláusula regia del Estado Constitucional de Derecho"*[181]

En este mismo fallo, la Sala Constitucional establece dos criterios específicos para determinar la competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para el caso en que se generen

[181] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Inconstitucionalidad: res. 9928-2010; 9 de junio de 2010 15:09 horas, considerando, párrafo séptimo.

escenarios de disputa entre esta y otras jurisdicciones (en el caso concreto que se estaba discutiendo, la laboral).

> *"Este Tribunal Constitucional, estima que los criterios determinantes para deslindar el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso-administrativa de otros órdenes jurisdiccionales especializados –que, en adelante, deben tenerse en consideración por la jurisdicción ordinaria- serán, entonces, los siguientes: 1°) El contenido material o sustancial de la pretensión y 2°) el régimen jurídico aplicable; de modo que si se discute la conformidad o disconformidad sustancial de una manifestación específica de la función administrativa con el bloque de legalidad, el conflicto de interés, será, necesariamente, de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa."*[182]

Recabando lo recientemente expuesto, se dice entonces que la competencia material de una jurisdicción, en específico de la Contencioso Administrativa, se define tanto por los sujetos que intervienen en el proceso como por las pretensiones materiales específicas, deducidas particularmente por el actor. El primer punto mencionado refiere a la presencia de una Administración Pública o, en su defecto, de un funcionario público (e incluso un *munera pubblica*) en partes del proceso.

Lo segundo remite directamente a las pretensiones que, por su contenido material, se atribuyan exclusivamente a una jurisdicción distinta de la Contencioso Administrativa, en tanto el asunto compete a otra materia ordinaria. También opera cuando se solicita la inconstitucionalidad de una conducta pública, que por excelencia corresponde a la Jurisdicción Constitucional en exclusiva.

Un caso en el que la Sala de Casación de lo Contencioso Administrativo valoró el tema al que se viene haciendo referencia, fue la resolución 326-F-S1-2012. Dicha resolución es el antecedente reciente donde se ha ventilado el Acto de Gobierno de manera más amplia. En el proceso, se solicitó la anulación del acto mediante el cual la Asamblea Legislativa removió al Contralor General de la República, sea la moción de orden aprobada en la sesión ordinaria N.° 115, celebrada el 13 de diciembre de 2004. La defensa del Estado, en ese caso, alegó ante el casacionista (entre otros motivos) un quebranto del artículo 3, inciso segundo del CPCA, tantas veces mencionado anteriormente, así como la excepción procesal correspondiente, contemplada en el artículo 66,

[182] *Ibid.* Párrafo 12.

inciso primero, punto g), también del CPCA. Este último numeral estipula la excepción de incompetencia por acto no susceptible de impugnación. En lo conducente:

> *"ARTÍCULO 66.-*
>
> *1) En la contestación de la demanda o contrademanda, podrán alegarse todas las excepciones de fondo, así como las siguientes defensas previas:*
>
> *(...)*
>
> *g) Que la pretensión se deduzca contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación."*

Interpuesta esta excepción por la representación demandada (estatal) y alegada ante el casacionista la no impugnabilidad del acto, la Sala, resolviendo sobre el fondo, en este caso específico dispuso:

> *"El acto de remoción de quienes ostenten los cargos de Contralor o Subcontralor Generales de la República, es una competencia constitucional reservada exclusivamente a la Asamblea Legislativa, por ende, uno de ejecución directa de la Constitución que, en los términos de la norma suprema, puede adoptarse "...mediante votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos.". Siendo clara la voluntad del constituyente en tal sentido, la inobservancia de los supuestos que posibilitan su adopción, implica un quebranto directo del mandato constitucional que los establece, en consecuencia, su anulación no podría serlo por un contralor de legalidad (la norma violada no es infraconstitucional) sino del contralor de constitucionalidad. Resulta lógico (en virtud de los supuestos en que se estatuye) y natural (por la función que cumple) que tal acto (no sometido a la ley común), resulte no impugnable ante la jurisdicción contencioso administrativa, establecida para controlar la legalidad de la relación que surja entre la Administración con los administrados."*[183]

Ahora bien, más allá de la forma en la que la Sala de casación resolvió el caso en concreto, en función de las pretensiones de una u otra parte, lo que interesa eminentemente de la resolución son

[183] Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de casación: res. 326-F-S1-2012; 8 de marzo de 2012 8:40 horas, considerando IX, párrafo primero.

algunas consideraciones concretas que la Sala efectúa con respecto del Acto de Gobierno en Costa Rica. Ciertamente, la Sala Primera basa en gran medida su resolución en la consideración de que, si es una norma de rango constitucional la que autoriza expresamente la emisión de la conducta formal de una Administración, ello implicaría que es entonces únicamente el contralor de constitucionalidad el que podría verificarla, ya no bajo un parámetro de legalidad, sino que uno de constitucionalidad. En concreto determinó:

> *"En tal sentido, para esta Sala, no cabe, al menos en este asunto, interpretación distinta en cuanto la inimpugnabilidad de dicho acto en la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud de la competencia exclusiva y excluyente ejercitada por el Tribunal Constitucional."*[184]

El hecho de que la norma violada sea infraconstitucional no puede, de ninguna manera, ser el único criterio a tener en consideración para determinar la exclusión del contralor de legalidad de una conducta formal de una Administración. Ello no solo sería obviar los parámetros establecidos por la propia Sala Constitucional, con respecto a los alcances del contralor de legalidad, sino que el problema radica mucho más allá de ello, en tanto supone una contradicción directa con los principios generales del derecho y su correcta interpretación dentro del bloque de juridicidad. Este único ejemplo, con el que se cuenta en la jurisprudencia reciente, de una conducta formal de la Administración que es declarada por la Sala Primera de casación como Acto de Gobierno y, por tanto, sujeta a la excepción del artículo 66 g) del CPCA, deja un enorme sinsabor en la interpretación que dicho órgano realiza del Acto de Gobierno. Ya no solo la legalidad de dicha conducta debería poder evaluarse ante el contralor de legalidad, sino que, atendiendo al párrafo segundo del propio artículo 3, inciso b) del CPCA (donde se establece la excepción), al menos los daños y perjuicios patrimoniales que de tal conducta se pudieran generar, deben ineludiblemente poder ser revisados y declarados por el propio contralor de legalidad.

[184] *Ibid.* Párrafo 10.

Capítulo 3. El Acto de Gobierno frente a los principios garantistas del Derecho Público

Sección Primera: El Acto de Gobierno y el principio de acceso a la justicia

El principio de acceso a la justicia es una derivación del principio de tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 41 de la Constitución Política. El acceso a la justicia, o de forma más técnica, a la jurisdicción, es una garantía derivada del Estado Social y Democrático de Derecho, mediante la cual todo administrado se garantiza que, en tanto se lesionen sus derechos o intereses, puede acudir a una instancia judicial a reclamar la restitución de su situación jurídica o la indemnización correspondiente según corresponda.

Como ya se examinó en un acápite anterior, el derecho de tutela judicial efectiva tiene principalmente cuatro componentes básicos: derecho a una resolución sobre el fondo, derecho a una resolución fundada en derecho, la congruencia y la prohibición constitucional de indefensión. Para efectos de la presente sección, resulta de particular relevancia el primero de los mencionados, el principio de acceso a la justicia en sentido estricto, es decir, el acceso a la jurisdicción; la posibilidad de instar ante un órgano jurisdiccional la tutela de un derecho subjetivo o un interés legítimo que se considere violentado y obtener una resolución sobre el fondo del reclamo.

Como se ha expuesto anteriormente, de un análisis comprensivo de los artículos 9, 49, 41 y 45 de la Constitución Política, así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en delimitación del principio de tutela judicial efectiva y su manifestación como acceso a la justicia, se ha entendido que existe un imperativo constitucional de sometimiento pleno de la Administración Pública al contralor jurisdiccional, de legalidad o constitucionalidad, según sea el caso. Como se puede ver de la evolución histórica de la justicia administrativa, el ámbito de cobertura de esta solamente ha crecido (se ha expandido) con los años, en una tensión no siempre pacífica con las fuerzas (eminentemente de tendencia autoritaria y absolutista), que buscan limitar dicho alcance. El Acto de Gobierno, en tanto pretensión de exclusión del contralor jurisdiccional de la actividad de la Administración Pública, en este sentido, es claramente un vestigio directo y pérfido del

modelo monárquico de dirigir la cosa pública. En diferentes latitudes se ha entendido esta perspectiva del avance de la justicia administrativa, en tanto:

> *"No obstante esas ampliaciones, la ley mantiene las zonas exentas del control judicial entre las que se cuentan los actos políticos y una lista de actos excluidos por el artículo 40 (policía sobre prensa, radio, cinematografía y teatro, ascensos y recompensas militares, expedientes gubernativos militares), precepto, a su vez, que deja abierta la puerta a otras exclusiones por leyes especiales. Pues bien, estas últimas barreras a un enjuiciamiento pleno de la actividad administrativa son las que hace saltar la Constitución con los artículos 24, que consagra el derecho a la garantía judicial efectiva, y 106, que somete, sin excepción alguna, a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. La consecuencia de esta regulación constitucional es obvia: han quedado invalidadas por inconstitucionalidad sobrevenida las materias que el artículo 40 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa exceptuaba del control contencioso- administrativo; y a partir de aquí ya no es posible establecer exención alguna, legal o reglamentaria, a dicho control."*[185]

El artículo 24 de la Constitución Española, al que refiere Ramón Parada, es el ítem encargado de regalar lo relativo a la tutela judicial efectiva y, por tanto, el acceso a la justicia en el derecho español, con lo cual se puede establecer un claro y manifiesto paralelismo con lo dispuesto en el artículo 41 de nuestra propia Constitución Política. Para ilustrar este punto, se transcribe lo dispuesto por el artículo referido, que contempla:

> *"Artículo 24.*
>
> *Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario*

[185] Parada, R. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons. 1997. Pp 747-748.

predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos."

Si se sigue la línea de pensamiento del autor antes expuesto, podría afirmarse que en Costa Rica sucede lo mismo que en el ordenamiento jurídico español. Se reafirma que el desarrollo de la justicia administrativa de nuestro país se ha caracterizado por una clara dirección, orientada al control pleno y absoluto de la actividad de las Administraciones Públicas, y no a su limitación. En ese entendimiento, las cláusulas tendientes a excluir parcelas del accionar formal de la Administración de dicho control serían contrarias a los principios, pero más aún, a las disposiciones directas del orden constitucional. De ahí que el artículo 3, inciso b) del CPCA, en tanto se entienda como una exclusión total de tales o cuales actos del contralor jurisdiccional (de constitucionalidad o de legalidad), debería entenderse como contraria al derecho de la constitución, en particular al artículo 41 de la Carta Magna.

Las justificaciones, ya sea doctrinales, jurisprudenciales o normativas que se generen para excluir un segmento del accionar de la Administración de contralor jurisdiccional no tienen cabida dentro de los parámetros contemporáneos de un Estado Social y Democrático de Derecho, tales parámetros, para efectos de esta investigación, no son otros que los principios generales del derecho previstos en la Constitución Política. Tales principios, tal y como se puede entender a partir de la amplia explicación efectuada en ese sentido, tienen rango constitucional, potencia que les permite vencer excepciones contrarias previstas en normas de rango legal.

En definitiva, el principio de tutela judicial efectiva, así como su consecuencia directa, el principio de acceso a la justicia, tienen como consecuencia inevitable una cobertura plena y universal del contralor jurisdiccional de las actividades de las Administraciones Públicas, un sometimiento pleno y absoluto de dicha actividad al contralor de legalidad o constitucionalidad, según

corresponda, siendo que el segundo es competente de manera incuestionable en todos los casos y supuestos, sobre ello:

> *"El artículo 49 constitucional establece una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal que le permite al justiciable impugnar o atacar cualquier conducta o manifestación de la función administrativa ante ese orden jurisdiccional."*[186]

Las razones por las que un Acto Administrativo específico de la Administración Pública podría quedar exento del contralor de legalidad son variadas, aunque de cara al principio constitucional de acceso a la justicia, solamente dos podrían entenderse como válidas: la derivación (del acto) directa de una norma constitucional, podría activar una competencia exclusiva y excluyente del contralor de constitucionalidad de acuerdo a los parámetros de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; en su defecto, por motivos elementales de las reglas del derecho procesal contencioso, un acto que no trastocara intereses legítimos o derechos subjetivos de ningún administrado (falta de configuración de los elementos procesales necesarios de la acción procesal).

Las posiciones doctrinales que tienden a negar el control jurisdiccional de actos de la administración no son más que letargos ideológicos de la monarquía, de perspectivas absolutistas de organización social dichosamente superadas, cuya superación no fue sencilla. No es que el Estado juez tenga que ser, a través de las pautas de la justicia administrativa, un Leviatán omnipresente que controla, limita e incluso remplaza la labor de los órganos y entidades encargadas de administrar. La contrastación de los principios generales del derecho (en especial el de acceso a la justicia) con la teoría clásica del Acto de Gobierno, en detrimento de esta última, intenta humanizar la justicia administrativa, en un giro hacia parámetros prácticos y reales, que en la práctica preserven los intereses y derechos de los administrados, cuyas aspiraciones, propiedad, integridad y, en general, esfera jurídica, resulta indispensable tutelar.

El Estado, puesto a disposición de los ciudadanos, lo que en algunas latitudes ha sido conocido como imperio de la ley, es decir, la aspiración de que el aparato jurisdiccional (en caso de que el administrativo no lo haga) se encargue de imponer los parámetros del bloque de legalidad, sobre todo accionar de la Administración Pública. Esa es la aspiración de la correcta justicia

[186] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Inconstitucionalidad: res. 9928-2010; 9 de junio de 2010 15:09 horas, considerando, párrafo décimo cuarto.

administrativa, como parte esencial de las potestades-deberes del Estado (función judicial), es un tema que ciertamente supera por completo las pautas del proceso contencioso, anclándose en los preceptos teleológicos de la Constitución Política y, en normas específicas de esta, como el tantas veces mencionado artículo 41 Constitucional.

> *"No se trata de un Estado mínimo, sino que tiene unas proporciones irreductibles, a la luz de las innumerables oportunidades que para el salvajismo que ofrece la vida moderna. Antes, al contrario, es un Estado ambicioso, construido como un instrumento para alcanzar los objetivos de la comunidad (varias doctrinas flexibles de Derecho Constitucional y Administrativo han contribuido a alumbrar y perfilar esa construcción). Los imperativos apriorísticos sobre el ámbito de lo público han sido sustituidos casi totalmente por los imperativos relativos a preocupaciones prácticas por el consenso, los recursos y la eficiencia. Somos pragmáticos, no filósofos políticos."*[187]

Tal vez la cita no ilustra los mecanismos procesales de aplicación concreta a través de los cuales se materialice lo pretendido, empero, en definitiva ilustra lo pretendido. Se traza la finalidad de la justicia administrativa, que a través del control de legalidad y constitucionalidad de la función de las Administraciones Públicas, busca y aspira a la eficiencia, la seguridad jurídica, el imperio de la ley. La disposición del artículo 3, inciso b) del CPCA solamente puede ser entendida como una exclusión del contralor de legalidad de los actos administrativos allí mencionados, en tanto dichos actos no trastoquen de ninguna manera un derecho subjetivo o un interés legítimo de un administrado, sin excepciones de ningún tipo. Excepcionar lo dicho sería violentar el principio constitucional de acceso a la justicia y, con ello, el artículo 41 de la Constitución Política.

[187] Edley, Christopher. Reconcebir el control judicial de la Administración Pública. España: Instituto Nacional de Administración Pública. 1994.

Sección Segunda: El Acto de Gobierno y el principio de reparación integral del daño

El principio de reparación integral del daño es una derivación del principio de acceso a la justicia y del principio de responsabilidad de la Administración Pública, ambos desarrollados previamente en esta investigación. En su formulación contiene los dos preceptos que califican primordialmente el proceso de determinación de la responsabilidad y su remedio dentro del derecho procesal, es decir, ante la existencia de un daño se genera un deber de reparación, que además debe ser una reparación integral.

Como se ha visto en secciones anteriores, el estar sujeto a un régimen de responsabilidad es una de las consecuencias directas e inmediatas que tiene la personificación del Estado (y de las demás Administraciones Públicas), en un sujeto de derechos y obligaciones, con personalidad y patrimonio propio. Dicho régimen de responsabilidad, en el caso específico de Costa Rica, se encuentra regulado en la Constitución Política, principalmente en los artículos: 9 (establecimiento explícito de la responsabilidad); 11 (principio de legalidad); 49 (establecimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa y civil de hacienda); 41 (principio de tutela judicial efectiva y sus derivaciones); 45 (intangibilidad patrimonial de los administrados). La jurisprudencia constitucional ha sido conteste en señalar que, en todo caso, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, debe resguardar los derechos e intereses de los administrados, sobre ello:

> *"El constituyente derivado optó por una justicia administrativa mixta, por cuanto, el párrafo primero, al definir el objeto del orden jurisdiccional contencioso-administrativo -"garantizar la legalidad de la función administrativa"-, debe complementarse, ineluctablemente, con el párrafo in fine, al preceptuar que ley brindará protección, como mínimo, a los derechos subjetivos y los intereses legítimos –sin distinguir, en cuanto a estos últimos, por lo que resulta admisible la tutela tanto de los personales como de los colectivos, sea corporativos o difusos-. Consecuentemente, la jurisdicción contencioso-administrativa, según el Derecho de la Constitución, fue instituida tanto para velar por la legalidad de la función administrativa como para la tutela efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados frente a los poderes públicos. Se conjuga, así,*

constitucionalmente, un rol objetivo y subjetivo de la jurisdicción contencioso-administrativa."[188]

La base de la responsabilidad administrativa está solidificada a nivel constitucional por pautas de imposible omisión, aunque ciertamente el régimen específico a través del cual se regula tal mecanismo está contemplado (tal y como se adelantó) en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así como en múltiples ítems del CPCA, principalmente en el artículo segundo, inciso b) de dicho cuerpo procesal, en donde se establece la Competencia Civil de Hacienda y que en lo de interés postula:

"ARTÍCULO 2.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda también conocerá lo siguiente:

(...)

b) Las cuestiones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios."

Ahora bien, en el caso específico del Acto de Gobierno, se está ante el supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración por la adopción de un Acto Administrativo. Más allá de si el Acto de Gobierno es revisable o no por el contralor de legalidad (o en su defecto, de constitucionalidad) y en qué escenarios específicos (discusión zanjada en el acápite anterior) todo Acto Administrativo que genere un daño resarcible, en sentido técnico jurídico, es susceptible de generar responsabilidad patrimonial al ente que se repute su disposición.

"No hay ningún obstáculo que impida reconocer con carácter general el derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios generados por un Acto Administrativo. Ese derecho es autónomo de la legalidad o ilegalidad del acto, y en ese sentido se afirma que la simple anulación no es determinante de forma mecánica de la responsabilidad administrativa. El acto puede ser ilegal pero su anulación no siempre genera el derecho a un resarcimiento económico. Sólo habrá ese derecho cuando se den las circunstancias generales exigidas por la Ley para generar la responsabilidad: que se haya producido una lesión en sentido técnico-jurídico (es decir, individualizada, efectiva,

[188] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Inconstitucionalidad: res. 9928-2010; 9 de junio de 2010 15:09 horas, considerando, párrafo octavo.

antijurídica y susceptible de valoración económica), causada por el Acto Administrativo e imputable a la Administración que lo dicta. Si no se dan esos requisitos el acto será ilegal pero no habrá lugar a la indemnización, en la mayoría de los casos porque el resultado de la nulidad no será antijurídico." [189]

Se parte entonces de que no hay ninguna excepción concebible al principio de que todo acto formal de la Administración puede generar responsabilidad patrimonial, esa posición se ve reflejada en el propio artículo 3, inciso b) del CPCA, que regula el Acto de Gobierno:

"ARTÍCULO 3.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda no conocerá las pretensiones siguientes:

b) Las concernientes a los actos de relación entre los Poderes del Estado o con motivo de las relaciones internacionales, sin perjuicio de las indemnizaciones procedentes, cuya determinación corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Véase que en el párrafo recién transcrito *in fine* se señala, de manera clara y contundente, que la excepción de acto no susceptible de impugnación no exime en ningún caso de las indemnizaciones patrimoniales que procedan por la disposición de ese acto. Esa cláusula final es diáfana en determinar que, incluso si no es susceptible de revisión jurisdiccional, la legalidad de los actos ahí enunciados, en todos los casos, será revisable por la propia Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, la indemnización patrimonial de los daños o perjuicios que pudiese producir tal Acto Administrativo. Esto último no es otra cosa que la puesta en práctica de los principios de responsabilidad y reparación integral del daño, en tanto se establece que, incluso los actos que (en tesis de principio) no son susceptibles de impugnación, son susceptibles de generar responsabilidad patrimonial. En otras palabras, más allá de la revisión de legalidad que se pueda (o no) efectuar sobre un Acto Administrativo específico, la antijuridicidad de este es la que genera el deber indemnizatorio en última instancia:

"Lo relevante para apreciar el derecho a percibir una indemnización no es la mayor o menor gravedad del vicio jurídico que justifica la anulación del Acto Administrativo, lo

[189] Blanquer, David. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. España: Instituto Nacional de administración Pública. 1997. P51.

importante no es el grado de ilegalidad del acto sino la antijuridicidad del resultado. En consecuencia, desde la perspectiva de la eventual antijuridicidad del resultado no cabe establecer una diferencia entre infracciones tolerables e intolerables."[190]

Desde la perspectiva expuesta, se entiende que la discusión alrededor del sometimiento del Acto de Gobierno al contralor jurisdiccional (de legalidad o constitucionalidad) se reduce únicamente a la revisión de validez o invalidez de dicho acto, en tanto todo daño o perjuicio, producido a la esfera jurídica subjetiva de un administrado, es resarcible. Si bien dicha lesión debe computar los requisitos descritos para su procedencia, siempre y sin excepción alguna, una lesión producida a un derecho o interés de un administrado, por parte de una Administración Pública, podrá ser revisada (de cara a una posible indemnización) jurisdiccionalmente.

[190] *Ibid.* Pp 51-52.

Sección Tercera: Propuesta de un modelo garantista de control jurisdiccional del Acto de Gobierno

En la presente sección se pretende esbozar un modelo garantista del instituto de cita, es decir, del ya desarrollado Acto de Gobierno. Ahora bien, resulta oportuno precisar que tal garantismo debe responder a parámetros concretos, es decir, a tales o cuales principios o dispositivos que le doten de contenido, en otras palabras, a la pregunta de: ¿qué garantiza tal modelo? La respuesta es diáfana para este momento, sobre todo a raíz de lo expuesto en el presente capítulo. El modelo debe garantizar los principios de acceso a la justicia y reparación integral del daño. Ya no solamente porque tales principios son la columna vertebral de la tutela judicial efectiva constitucional y, siendo que se está ante un tema eminentemente procesal contencioso, ese debe ser el norte de todo el sistema en cuestión. También porque el instituto desarrollado se erige en su concepción tradicional (con bastante vigencia al día de hoy, según se pudo ver) como una excepción al control jurisdiccional de la actividad de las Administraciones, lo cual encarna una frontera sumamente peligrosa con el ya mencionado principio (de tutela judicial efectiva).

Conviene ser contundente con lo siguiente: la perspectiva correcta con respecto del Acto de Gobierno en Costa Rica es su total desaparición, al menos en su concepción clásica (como cláusula de exclusión jurisdiccional). La única forma de entender, de manera adecuada, la cláusula de exclusión jurisdiccional prevista en el artículo 3, inciso b) del CPCA, supone la eliminación del Acto de Gobierno, a nivel terminológico y doctrinal, en pro de las doctrinas del acto institucional y constitucional. Como se expuso, incluso a nivel terminológico se debe resemantizar dicho instituto, en tanto el término “Gobierno” alude a una añeja doctrina de función gubernativa, que no tiene ninguna relevancia práctica, al menos en su concepción clásica, por lo que evitar esta insinuación es fundamental.

Como ya se expuso *supra*, la exclusión jurisdiccional total de un instituto de derecho público es absolutamente inadmisible, sin excepciones. Cualquier Acto Administrativo, independientemente de su calificación, en tanto manifestación de voluntad de una Administración Pública, capaz de generar derechos y obligaciones para sí y para terceros, debe inexorablemente ser susceptible de revisión jurisdiccional, al menos ante el contralor de constitucionalidad, cuando menos en tanto a su validez y las indemnizaciones que generase en caso de causar daños o perjuicios. Siendo que

para el caso específico de los daños y perjuicios sí serán siempre revisables ante la propia Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, por disposición del propio artículo 3, inciso b) del CPCA, párrafo *in fine*.

La exclusión jurisdiccional (del contralor de legalidad, en tanto, como se vio, del contralor de constitucionalidad, es absolutamente inviable en todos los supuestos) que contiene el *quid* del instituto del Acto de Gobierno, solamente se justifica en los dos supuestos ya mencionados, siguiendo las doctrinas, tanto de Eduardo Ortiz como de Miguel Marienhoff, expuestas *supra*. El primero de los supuestos mencionados se justifica en una potestad discrecional habilitada por una norma de rango constitucional expresamente, cuyo control compete únicamente a la jurisdicción constitucional (de ahí la exclusión del contralor de legalidad), este supuesto no es otro que el del acto constitucional, desarrollado por la doctrina más autorizada y, en el caso costarricense, incluso por el propio Tribunal Constitucional. El supuesto restante, siempre en concordancia con los autores mencionados, es el del acto institucional, que despliega funciones propias de la organización interna o relaciones internacionales del Estado; en tal escenario, la exclusión del contralor de legalidad se justifica ya no en la naturaleza del acto, sino en un aspecto procesal básico de legitimación, en tanto uno de los componentes intrínsecos del acto institucional yace en no afectar los derechos subjetivos o intereses legítimos de ninguna persona. En caso de que el acto institucional afectase derechos subjetivos o intereses legítimos de una persona, ocasionando un menoscabo en su esfera jurídica subjetiva, en atención a los principios de reparación integral del daño, acceso a la justicia y el artículo 3, inciso b) del CPCA, activaría inmediatamente la competencia de la Jurisdicción Civil de Hacienda.

En suma, el correcto entender de la doctrina contemporánea y garantista (en los términos expuestos) del Acto de Gobierno, de cara a los parámetros de la justicia administrativa, arroja inevitablemente la desaparición de tal tipología específica de Acto Administrativo. La exclusión jurisdiccional del artículo 3 del CPCA, que históricamente se ha entendido como el respaldo normativo del Acto de Gobierno, se ha entendido de manera errónea. Dicha exclusión únicamente es viable, entendida como exclusión de dicho contralor de legalidad de los actos constitucionales y de los actos institucionales, sin perjuicio de determinar las indemnizaciones patrimoniales producidas por estos últimos.

El Acto de Gobierno, desde sus orígenes en la incipiente jurisprudencia del Consejo de Estado francés y hasta nuestros días, no es más que un vestigio claro del método de organización social denominado monarquía, que ha persistido en el derecho administrativo continental europeo por varios siglos, alcanzando incluso el ordenamiento jurídico costarricense, por ninguna razón práctica o doctrinal aparente, nada más que por inercia. Dicha persistencia no se entiende a la luz de una justicia administrativa moderna y eficaz, que coloque al administrado como el centro de su sistema, que se informe de los principios generales del derecho, que a su vez contienen los planteamientos y mecanismos materiales de una justicia social democratizada. El Acto de Gobierno, como instituto hijo del modelo monárquico, reivindica el despotismo y el poder absoluto concentrado en tal o cual ente abstracto, es una mancha en el ordenamiento jurídico costarricense que aspira a una justicia administrativa basada en el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Excluir una parcela del accionar del Estado de todo control jurisdiccional no es otra cosa que una inversión total del principio básico de existencia del mismo: servir a las personas.

Conclusiones

La primera conclusión que resalta es que el Acto de Gobierno tiene un germen eminentemente absolutista desde su concepción. Se originó en el derecho francés post napoleónico, a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado (principalmente el Arret Prince Napoleón, de 1875) y obedeció a una medida de autoconservación del Consejo de Estado que, ante el resurgimiento de los poderes monárquicos y absolutistas que retomaron el poder, redujo su propio fuero competencial, para otorgarle un espacio de libre actuación a tales poderes y, con ello, evitar su completa desaparición. Es decir, se generó como una medida, dentro del seno del incipiente derecho administrativo, para conservar las potestades absolutistas de la monarquía, en tanto la alternativa a ello era la desaparición total de la recién creada jurisdicción contenciosa administrativa.

Se estableció que España es un conector entre el derecho francés (o de manera más amplia, el derecho continental europeo) y el costarricense. Destaca que en el derecho hispano el Acto de Gobierno fluctuó desde su creación en la Ley Santamaría Pastor y hasta la actualidad, con una clarísima tendencia a ampliar sus márgenes durante los periodos dictatoriales y reduciéndose posteriormente con el decaimiento de la dictadura. En principio, en el derecho español (modelo del costarricense durante todo el siglo XX) se vinculó la teoría del Acto de Gobierno al de los actos discrecionales, sosteniéndose que la inimpugnabilidad de aquel se debía a su naturaleza discrecional, luego, se optó por elaborar una tipología, especificando cuáles actos calificaban como de Gobierno, para finalmente reducirse a unos cuantos supuestos específicos con el auge de las doctrinas garantistas de la justicia administrativa, a finales del siglo XX. En Costa Rica, dicho concepto no arribó sino hasta la promulgación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1966, que en buena medida estuvo basada en la legislación procesal contenciosa española, por lo que el arribo del Acto de Gobierno a Costa Rica se dio en los términos en los que estaba planteado en el derecho español de la época.

La LJCA de 1956 de España fue el modelo para la redacción de la LRJCA de 1966 en Costa Rica, no obstante, en las décadas posteriores del derecho español se desarrollaron doctrinas novedosas que terminaron desembocando en una nueva LJCA en 1998. Tal regulación optó por el control plenario del accionar de la Administración Pública, empero, vía jurisprudencial se sostuvo la

existencia del Acto de Gobierno, bajo la subsunción en figuras como acto constitucional o incluso el denominado Acto de Gobierno autonómico. Ya entrado el siglo XXI, no se alcanzó en dicho país el control plenario al que se aspiró con la Ley de 1998, por lo cual tampoco hace las veces del ejemplo garantista, al que tal y como se propuso posteriormente, debe apostar Costa Rica.

Se examinó el Acto Administrativo como instituto, para dar una base a partir de la cual se pudiera comprender en cada uno de sus elementos específicos el Acto de Gobierno, estableciendo una relación de género-especie. Los principios que rigen el Acto Administrativo se destacan (principalmente el de legalidad) en tanto es discutido si son de plena aplicación también al Acto de Gobierno, siendo la nota diferenciadora su presunta inimpugnabilidad. También se revisó el concepto de función gubernativa, a partir del cual se desarrolló buena parte de la teoría del Acto de Gobierno en un sector importante de la doctrina. Dicho sector sostuvo que existía esta cuarta función dentro de la cual se encuadraban e incluso se justificaba el Acto de Gobierno como instituto específico. A partir de esta función se derivan conclusiones puntuales sobre las características del Acto de Gobierno, dentro de las cuales destacan: estar vinculado con la existencia y funcionamiento mismo del Estado; en contradicción con el Acto Administrativo no se rige por el principio de regulación mínima; que está habilitado y, por tanto, sometido únicamente a la Constitución. Este último aspecto (el estar sometido únicamente a la Constitución) también relativiza la aplicación del principio de legalidad respecto del Acto de Gobierno.

La doctrina más autorizada en el derecho administrativo costarricense es, sin duda, la de Eduardo Ortiz. Este autor postula la teoría del acto constitucional como la correcta en relación con el Acto de Gobierno. El contralor de constitucionalidad puede y debe controlar todos los actos, incluyendo esta tipología específica. Incluso el contralor de legalidad dispuesto por el artículo 49 de la CP, así como otros artículos constitucionales (10, 41) prescriben el obligatorio conocimiento por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de todos los actos de la Administración Pública, sin excepción. Concluye este autor que no existe necesidad de una teoría especial de Acto de Gobierno (posición ampliamente compartida en esta investigación), en tanto los actos que no son impugnables ante la jurisdicción contenciosa son solamente los constitucionales (cuya competencia exclusiva y excluyente compete a esa jurisdicción) y los institucionales (Marienhoff), empero, por razones de falta de legitimación, en tanto no lesionan ningún derecho subjetivo o interés legítimo.

Ahora bien, con el análisis histórico del control jurisdiccional de los actos de la Administración Pública se logra determinar el origen de dicha actividad en la personificación de la Administración Pública (lo que la convierte en sujeto de derechos y obligaciones), así como en la implantación de un régimen robusto de división de poderes, que garantice las facultades al Judicial para el ejercicio de tal función. Son ambas premisas descritas, condición de posibilidad de existencia del contralor de legalidad, de las actuaciones de la Administración Pública.

En la incipiente República francesa de finales del siglo XVIII y XIX se forjaron dos sistemas de control jurisdiccional de legalidad. Un sistema de justicia delegada donde el órgano contralor permanecía dentro de la misma Administración, el cual ofrecía un sistema de control más débil, así como un sistema de justicia delegada, en el que tal órgano estaba adscrito al poder Judicial y con ello tiene una tendencia claramente más democrática, además de que se encuentra en armonía con los parámetros del correcto entendimiento de la teoría de división de poderes. En el caso específico de Costa Rica, la primera legislación procesal contenciosa tuvo lugar con la Ley 1226 de 1950, que fue sumamente defectuosa y escueta. Hasta la vigencia de la LRJCA de 1966 se robusteció el contralor de legalidad, además de que se reguló por primera vez, de manera directa, al Acto de Gobierno.

Se determinó que los principios generales del derecho deben ser, sin lugar a dudas, la base, fundamento y justificación de todo el ordenamiento jurídico, así como el método de interpretación e integración primario para el operador jurídico. Lo anterior, en el tanto los principios generales del derecho encarnan la matriz axiológica del ordenamiento jurídico, de allí que deban ser el hilo conductivo de las manifestaciones concretas de dicho ordenamiento, así como su consideración resulta indispensable en aras de analizar cualquier instituto jurídico, en especial uno tan complejo como el Acto de Gobierno.

De cara a orientar la justicia administrativa, es decir, el Derecho Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, los principios cuya consideración resalta como de mayor relevancia, al menos de cara al Acto de Gobierno en concreto, son: *in dubio prohabilitate instaciae*, antiformalista, tutela judicial efectiva, de responsabilidad de la Administración Pública y reparación integral del daño. Dichos principios deben ser de necesaria consideración por el contralor de legalidad, cuya jurisdicción se regula en el CPCA, entrado en vigencia en 2008. Tal cuerpo normativo establece las pautas para controlar los actos de las administraciones públicas,

existiendo posibilidades diversas de revisión por parte del juzgador. Dentro de las potestades de este juzgador se encuentra la supresión de la conducta, la cesación de los efectos de la misma, el establecimiento de daños y perjuicios, entre otras.

El Acto de Gobierno, como manifestación de voluntad de la Administración Pública, está innegablemente sometido al principio de legalidad regulado en los artículos 11 de la CP y de la LGAP. El control de dicha legalidad lo ejerce el juez contencioso. Dicha legalidad, en tanto parámetro de control, no debe ser entendida únicamente como norma estricta. La doctrina contemporánea de la justicia administrativa, destaca que la legalidad la componen también normas no escritas, que pueden entenderse como componentes del bloque de legalidad ante el cual contrastar los Actos Administrativos, incluyendo desde luego el Acto de Gobierno. Esta amplia concepción del principio de legalidad, entendido más allá de la mera norma escrita de rango legal, es la concepción correcta ante la cual se debe contrastar un Acto Administrativo, en el ejercicio del control jurisdiccional de legalidad.

El control jurisdiccional de los actos administrativos no solamente puede ser de legalidad, sino también ante la Jurisdicción Civil de Hacienda, se puede examinar la procedencia de una indemnización pecuniaria, en caso de existir responsabilidad patrimonial de la Administración. En el caso del Acto de Gobierno, dicha responsabilidad es extracontractual y debe cumplir con los preceptos legales dispuestos al efecto. La responsabilidad patrimonial de la Administración en Costa Rica es predominantemente objetiva y directa y no admite excepciones, es decir, todo menoscabo de la esfera jurídico subjetiva de un administrado es pasible de generar responsabilidad patrimonial, en caso de cumplirse los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. A la Administración Pública le resulta de plena aplicación lo dispuesto por la cláusula romana *Alterum non laedere*, o el deber general de no dañar a otros, de ello, así como de otros principios generales del derecho, se concluye la imperiosa obligación de la Administración de ser responsable, en los términos que la legislación vigente lo prescribe, la cual no excepcione ninguna lesión de ser pasiva de dicha indemnización.

En el derecho costarricense, en la normativa así como en la jurisprudencia, se pudo comprobar que la discusión alrededor del Acto de Gobierno gira entorno únicamente a la exclusión de este del contralor, en tanto la competencia de la jurisdicción constitucional es absoluta e indiscutida, para conocer la constitucionalidad de cualquier acto de la Administración Pública, sin excepción.

Dentro de los más altos tribunales del país, la discusión gira en torno a delimitar la frontera entre Actos Administrativos y de Gobierno, de cara a su control de legalidad. Se ha establecido que los criterios para determinar si un acto es Administrativo y, por tanto, sometido al contralor de legalidad, son dos: los sujetos que intervienen en el proceso, así como por las pretensiones materiales específicas, deducidas particularmente por el actor.

Con respecto a la revisión de los Actos Administrativos por parte de la Jurisdicción Civil de Hacienda, se tiene que existe también un sometimiento pleno. Basándose en la propia cláusula del artículo 3, b) del CPCA, así como en el principio de reparación integral del daño, se concluye que incluso ante la presencia de un Acto de Gobierno, en caso de que se genere una lesión resarcible a un administrado, este se encuentra habilitado procesalmente para exigir su indemnización ante el contralor civil de Hacienda. Con ello, la discusión sobre el sometimiento del Acto de Gobierno al contralor jurisdiccional, se reduce única y exclusivamente a su validez, en tanto se constató que debe existir un sometimiento pleno tanto al contralor constitucional como el civil de Hacienda, en el extremo específico de daños y perjuicios producidos.

En suma, la doctrina clásica del Acto de Gobierno es un rezago arrastrado desde la monarquía hasta nuestro contemporáneo Estado Social y Democrático de Derecho. Esta categoría, en tanto exclusión jurisdiccional de los actos de la Administración, nunca puede abarcar al contralor de constitucionalidad o los supuestos en los que se generen lesiones a la esfera jurídica de un administrado que no estaba en deber de soportarlo. Ahora bien, con respecto del contralor de legalidad, tal exclusión solo es admisible bajo una propuesta de enunciación taxativa, en la que solamente se incluyen los actos constitucionales y los institucionales explicados previamente.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Blanquer, David. *La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas*. España: Instituto Nacional de administración Pública. 1997.

Dromi, Roberto. *Tratado de Derecho Administrativo*. Argentina: Ediciones Ciudad Argentina. 1998.

Edley, Christopher. *Reconcebir el control judicial de la Administración Pública*. España: Instituto Nacional de Administración Pública. 1994.

García de Enterría, Eduardo y Fernández Tomás, Ramón. *Curso de Derecho Administrativo*. España: Civitas. 1980.

Garrido Cuenca, N. *El Acto de Gobierno*. Barcelona, España: Cedecs. 1998

Garrido, F. *Tratado de Derecho Administrativo, volumen I*. Madrid, España: Instituto de Estudios Públicos. 1976.

González Pérez, Jesús. *Manual de Derecho Procesal Administrativo.* España: Civitas. 1990.

González Pérez, Jesús. *Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.* España: Civitas. 2006.

Gordillo, A. *Tratado de Derecho Administrativo.* Buenos Aires, Argentina: FDA. 2013. Recuperado de: Los actos de gobierno, Gordillo Cap 12.pdf.

Marienhoff, Miguel. *Tratado de Derecho administrativo Tomo II*. Argentina: Abeledo-Perrot. 1981.

Milano, Aldo. *Evolución de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Costa Rica, Estudio retrospectivo.* Costa Rica: Cejamericas. 2005. Recuperado de: https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/1103/dev-gateway-aldo-milano.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Montesquieu. *El espíritu de las leyes*. España: Orbis. 1984.

Ortiz, Eduardo. *Tesis de Derecho Administrativo Tomo I*. Costa Rica: Stradtmann. 1998.

Parada, R. *Derecho Administrativo*. Madrid, España: Marcial Pons. 1997.

Sánchez Morón, M. *Derecho Administrativo Parte General*. España: Tecnos. 2006.

Revistas

Díez Sánchez, J. R. *El Control Jurisdiccional de los actos del gobierno y de los consejos de gobierno.* Revista Jurídica de Castilla y León. N.° 26. Pp 45-76. Recuperado de: El control jurisdiccional de lso actos del Gobierno y los consejos de gobierno Juan José Diez Sánchez.pdf

González Pogo, David Israel. El Principio de los "Pesos y Contrapesos" en el Constitucionalismo Ecuatoriano Contemporáneo. Quito, Ecuador. Revista de la Facultad de Jurisprudencia. Vol. 1, no 2. Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/6002/600263744014/html/.

Marcheno Acuña, B. *El control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno en el derecho español.* Madrid, España. Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje. Vol. 2, no 2 (junio 2015). Recuperado de: El Control Jurisdiccional De Los Actos Politicos BENJAMIN MARCHENO.pdf.

Ugalde Miranda, Óscar. *Derecho a la Tutela Efectiva.* San José, Costa Rica. Revista de ciencias jurídicas/ Universidad de Costa Rica. No 106. Pp 12-32. (2005). Recuperado de: 13338-Texto del artículo-22444-1-10-20140204 (1).pdf

Tesis

Calvo García, Jorge Iván. *Régimen de nulidades en la legislación administrativa costarricense. Análisis a la luz del nuevo código procesal contencioso administrativo.* Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2009. Recuperado de: Régimen de nulidades de la legislación administrativa a la luz del CPCA(TFG).pdf

Garay Sims, Mariana y Castro Fuenzalida, Boris. *Los actos de gobierno/políticos y su control jurisdiccional en el Derecho Público Chileno*. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Chile. 2018. Recuperado de: Los-actos-de-gobierno-políticos-y-su-control-jurisdiccional-en-el-derecho-público-chileno.pdf.

Normas jurídicas

Constitución Política de la República de Costa Rica.

Leyes

Ley número 8508, Código Procesal Contencioso Administrativo.

Ley número 1256, Ley Sobre el Juicio Contencioso Administrativo.

Ley número 3667, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ley número 7135, Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Ley número 6227, Ley General de la Administración Pública.

Jurisprudencia

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 5207-2004.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 9992-2004.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 9928-2010.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 00875-F-2007.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 326-F-S1-2012.